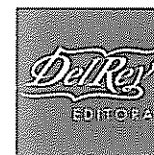


LEONARDO MACEDO POLI
Mestre em Direito Processual pela PUC Minas
Doutor em Direito Civil pela UFMG
Professor de Direito Civil da PUC Minas
Advogado

DIREITO AUTORAL

PARTE GERAL



Belo Horizonte
2008



Copyright © 2008 Editora Del Rey Ltda

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora
Impresso no Brasil | Printed in Brazil

EDITORA DEL REY LTDA
www.delreynonline.com.br

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza

Editora Assistente: Waneska Diniz

Coordenação Editorial: Leticia Meves

Diagramação: Ailton Mendes

Revisão: Alessandra Alves Valadares

Capa: Gira Design

Editora / MG

Av. Contorno 4355 – Funcionários
Belo Horizonte-MG – CEP 30110-027
Telefax: (31) 3284-5845
editora@delreynonline.com.br

Editora / SP

Rua Humaitá, 569 – Bela Vista
Telefax: (11) 3101.9775
São Paulo-SP – CEP 01321-010
editorasp@delreynonline.com.br

Conselho Editorial:

Alice de Souza Birchall
Antônio Augusto Cançado Trindade
Antonio Augusto Junho Anastasia
Ariosvaldo de Campos Pires (*In memoriam*)
Aroldo Plínio Gonçalves
Carlos Alberto Penna R. de Carvalho
Celso de Magalhães Pinto
Dulmar Pimenta
Edelberto Augusto Gomes Lima
Edésio Fernandes
Eugênio Pacelli de Oliveira
Fernando Gonzaga Jayme
Hermes Vilchez Guerrero
José Adércio Leite Sampaio
José Edgard Penna Amorim Pereira
Misabel Abreu Machado Derzi
Plínio Salgado
Renan Kfuri Lopes
Rodrigo da Cunha Pereira
Sérgio Lellis Santiago
Wille Duarte Costa

P766 Poli, Leonardo Macedo
Direito Autoral: parte geral / Leonardo Macedo Poli –
Belo Horizonte: Del Rey, 2008
192 p
ISBN 978-85-7308-974-5
1. Direito autoral I. Título.

CDD: 342.28

CDU: 347.78

Bibliotecária responsável: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB 6 / 1047

Aos meus meninos, Enzo e Luigi.

*Ao Professor César Augusto de Castro Fiuza,
à minha família, pelo estímulo e apoio incondicionais,
em especial, à Luciana.*

“De minha parte, depois de haver permanecido entre os livros algum tempo, senti a necessidade de abrir de par em par uma janela. Provavelmente esse é o segredo do pouco que pude fazer no campo da ciência. Tive sempre a sensação de que para minha sabedoria contavam mais as pessoas do que os livros.”

Carnelutti

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABDR	–	Associação Brasileira de Direitos Reprográficos
CC	–	Código Civil
CF	–	Constituição da República Federativa do Brasil
CONCINE	–	Conselho Nacional de Cinema
CPC	–	Código de Processo Civil
DDASI	–	Diretiva Européia sobre Direitos Autorais e Afins na Sociedade da Informação
ECAD	–	Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais
LDA	–	Lei de Direitos Autorais
LDS	–	Lei do <i>Software</i>
LPI	–	Lei de Propriedade Industrial
PIB	–	Produto Interno Bruto
STF	–	Supremo Tribunal Federal
STJ	–	Superior Tribunal de Justiça
UNESCO	–	Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

2.9.1 Extrapatrimonialidade	31
2.9.2 Eficácia absoluta	31
2.9.3 Indisponibilidade	31
2.9.4 Intransmissibilidade	32
2.9.5 Imprescritibilidade	33
2.9.6 Preeminência	34

CAPÍTULO III

DIREITOS PATRIMONIAIS

3.1 Direitos patrimoniais	35
3.2 Características dos direitos patrimoniais de autor	39
3.2.1 Transmissibilidade	39
3.2.1.1 Expressa manifestação de vontade e forma escrita	40
3.2.1.2 Interpretação restritiva	43
3.2.1.3 Presunção de onerosidade	46
3.2.2 Temporariedade e domínio público	50
3.2.3 Economicidade	56
3.2.3.1 O ilícito autoral	59

CAPÍTULO IV

LIMITAÇÕES AOS DIREITOS PATRIMONIAIS.....

4.1 Uso privado	67
4.2 Limitações legais	68

CAPÍTULO V

NATUREZA JURÍDICA DA TUTELA AUTURAL...

5.1 O fato jurídico gerador da tutela autoral	85
5.2 A Natureza relacional da tutela autoral	87

CAPÍTULO VI

TITULARIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS.....

6.1 Autoria e titularidade	93
6.2 Obras criadas para outrem	97
6.3 Obras anônimas, pseudônimas e póstumas	100
6.4 Criação integrada	101
6.4.1 A obra derivada	101
6.4.2 A obra coletiva	103
6.4.3 Co-autoria	104

CAPÍTULO VII

A OBRA PROTEGIDA

7.1 A criação do espírito	107
7.1.1 Criatividade	112
7.1.2 Comunicatividade	120
7.1.3 Exteriorização	122
7.1.3.1 Plágio	127
7.1.3.2 Obra e exemplar	129
7.1.3.3 Obras digitais	133

CAPÍTULO VIII

TENDÊNCIAS FUTURAS

8.1 A crise do Direito Autoral: a tripartição da propriedade intelectual	141
8.2 A ressystematização do Direito Autoral	144

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....

NOTA DO AUTOR

O principal objetivo deste trabalho é delinear uma teoria geral para o Direito Autoral. Para tanto, serão abordados os institutos jurídicos que surgem com a exteriorização da criação intelectual.

Assim, na parte geral será analisada a relação jurídica autoral, seus elementos constitutivos e sua principiologia. A Parte Especial, que extrapola à delimitação do tema ora proposto, compreende os direitos conexos, os negócios jurídicos autorais, a responsabilidade civil (pirataria) e a propriedade tecnodigital (direito autoral na rede).

O critério distintivo adotado foi o de delimitar a Parte Geral do Direito Autoral à análise da estática (situação jurídica absoluta) da relação jurídica autoral e, na Parte Especial, o estudo de seu aspecto dinâmico (situações jurídicas relativas).

A sistematização dada à Parte Geral buscou inspiração no caminho dialético trilhado pelo Direito: tese, antítese e síntese.

Assim, a obra pode ser dividida em três fases: construção, desconstrução e reconstrução. A primeira identifica-se com o primeiro capítulo. A segunda, compreende-se pelos capítulos 2 a 7. Nessa fase, verifica-se que a mesma transformação paradigmática que possibilitou a ampliação do conteúdo do aspecto existencial do Direito Autoral também delimitou seu as-

pecto patrimonial, o que gerou uma espécie de reação autoral na defesa do privilégio conquistado. A terceira fase, capítulo 8, busca a reconstrução do Direito Autoral propondo sua res-sistematização com a tripartição da propriedade intelectual, a elaboração de uma teoria geral para a propriedade intelectual, e sua reaproximação ao Direito Civil e às normas constitucionais fundamentais.

Assim, inicialmente busca-se a análise do Direito Autoral *in erba*. Sua posição dentro da propriedade industrial, as várias acepções do termo, os fundamentos e valores clássicos e sua natureza jurídica.

Posteriormente, passa-se à análise da situação jurídica autoral existencial, analisando-se a ampliação da tutela com a dilatação do conteúdo desse valor existencial pela promoção da dignidade humana.

Nessa parte serão estudados os direitos morais de autor, o direito de reivindicar a autoria da obra, o direito à autoria, o direito ao inédito, o direito à integridade da obra, o direito de modificar a obra, o direito de retirada, o direito de acesso a exemplar único e raro, bem como suas características, a extrapatrimonialidade, a eficácia absoluta, a indisponibilidade, a intransmissibilidade, a imprescritibilidade e a preeminência.

Depois, passa-se à análise da situação jurídica autoral patrimonial, a regulamentação legal em face das transformações sociais e tecnológicas e o acirramento da crise de legitimidade da legislação autoral.

Dessa forma, serão analisados os direitos patrimoniais de autor, sua transmissibilidade, onerosidade, temporariedade e economicidade, bem como será identificado o ato ilícito autoral.

Serão analisados, também o uso privado e as limitações legais aos direitos patrimoniais de autor, superando a noção de exceção e adotando a posição de elemento qualitativo do Direito Autoral.

Será estudado o fato gerador da tutela, sua natureza relacional e seus elementos estruturais: sujeito e objeto.

Assim serão analisadas as distinções entre autoria e titularidade, obras criadas para outrem, obras anônimas, pseudônimas, póstumas e psicografadas, obras derivadas, coletivas e co-autoria.

Serão estudados também a criação do espírito e os requisitos de criatividade, intercomunicatividade e exteriorização, abordando-se questões como o plágio e a obra digital.

Por fim, é adotada a tese de que a tecnologia digital gerou a necessidade da tripartição da propriedade intelectual em Direito Autoral, Propriedade Industrial e Propriedade Tecnodigital, e que sua harmonia se daria pela gravitação em torno de uma parte geral única que não apenas os aproximaria, como também reaproximaria a propriedade intelectual do restante do ordenamento jurídico.

CAPÍTULO I

DIREITO AUTORAL

1.1 DIREITO AUTORAL OBJETIVO E SUBJETIVO

O termo Direito Autoral é utilizado juridicamente em duas acepções distintas. Objetivamente é utilizado para definir o ramo do Direito que regula as situações jurídicas geradas pelas criações do espírito humano. É espécie do gênero propriedade intelectual, termo que engloba também a propriedade industrial.

Tem-se por propriedade intelectual o ramo do Direito que estuda os direitos exclusivos dos autores e inventores sobre suas obras, invenções ou descobrimentos.¹

Consideram-se direitos intelectuais aqueles incidentes sobre as criações intelectuais humanas. Segundo Bittar², dentro desse conceito englobam-se tanto as voltadas para a sensibilização e transmissão de conhecimentos, como aque-

¹ "Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". É esta a definição do art. 17 da Constituição Argentina e em linhas gerais traduz bem a idéia, apesar de não abarcar todas as situações jurídicas protegidas, como o caso do modelo de utilidade, do desenho industrial e outros

² BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 3.

las voltadas à satisfação de interesses materiais do ser humano na vida diária.

Conforme leciona Bittar³, essa bipartição da propriedade intelectual adotou como critério distintivo o caráter utilitário ou cultural da criação. Considerou-se naquele momento que nas criações de caráter utilitário haveria um maior interesse social em seu aproveitamento que nas demais, o que justificaria uma proteção mais ampla do titular no campo do Direito Autoral e mais restrita no campo da propriedade industrial.

Em um aspecto subjetivo, o termo Direito Autoral refere-se às faculdades ou liberdades juridicamente reconhecidas ao autor sobre sua criação.

Sob este prisma, o termo é habitualmente utilizado no plural, direitos autorais, fazendo-se referência à pluralidade de faculdades reconhecidas ao criador.

1.2 FUNDAMENTOS E VALORES DO DIREITO AUTURAL CLÁSSICO

Essa sistematização clássica do Direito Autoral, enquanto atribuição de direitos exclusivos ao autor da criação intelectual, é inspirada na tradição liberal em que se objetivava a proteção do direito subjetivo, enquanto elemento nuclear de garantia da liberdade individual, que não era vista, nesse momento inicial, como algo absoluto, mas limitada pela liberdade alheia⁴.

A concepção de direito subjetivo, porém, foi paulatinamente distanciando-se da noção de liberdade, de onde originariamente surgira, e aproximando-se da noção de segurança,

³ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*, p. 4.

⁴ VILANI, Maria Cristina Seixas. Cidadania moderna: fundamentos doutrinários e desdobramentos históricos. In: CADERNO de Ciências Sociais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2002, p. 50.

vindo assumir um sentido distorcido de poder absoluto ou ilimitado, em que se objetivaria sua proteção independente de sua funcionalidade⁵, o que acabou transformando um instrumento importante na luta contra o abuso de poder, em instrumento legitimador do abuso de direito.

Essa construção clássica do direito subjetivo em geral e do direito subjetivo autoral, em especial, inspirada no racionalismo-individualismo que tinha no indivíduo única causa e fim do Direito⁶, foi marcada, principalmente, segundo Amaral⁷, pelas seguintes características:

- crença no formalismo e no positivismo enquanto elementos estruturais da segurança jurídica;
- crença no Estado enquanto fonte exclusiva do Direito;
- a tecnização da ciência jurídica e a despolitização do jurista;
- a dicotomia entre público e privado ou Estado e sociedade civil;
- redução da atividade jurisdicional a um esquema mecânico de mera exegese normativa.

Nesse diapasão, a expressão Direito Autoral passa a ser vista simplesmente como poder atribuído ao autor com a finalidade exclusiva de se garantir a satisfação de seus interesses individuais.

Além disso, pode-se dizer que a crença na infalibilidade do racionalismo jurídico tenha provocado as seguintes consequências no Direito Autoral brasileiro:

⁵ BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 94.

⁶ AMARAL, Francisco. Transformação dos sistemas positivos a descodificação do direito civil brasileiro. *O Direito*, ano 129, v. I, n. II, 1997. Separata, p. 40.

⁷ AMARAL, Francisco. Transformação dos sistemas positivos a descodificação do direito civil brasileiro. *O Direito*, p. 40-41.

- a) cristalização dos valores liberais e conseqüente conservadorismo doutrinário;
- b) monismo jurídico ou idolatria legalista, considerando a legislação autoral única fonte de Direito;
- c) pretensão de plenitude do sistema jurídico autoral, que estaria isento de lacunas⁸.

Vê-se, assim, que, enquanto a evolução tecnológica caminha a passos largos, a ideologia liberal que ainda permanece entranhada no Direito Autoral brasileiro funciona como entrave ao movimento jurídico necessário de adaptação às transformações sociais, gerando um descompasso que lhe impede de dar uma solução adequada ao caso concreto.

É necessário, portanto, analisar criticamente a construção clássica do Direito Autoral, despindo-a da ideologia liberal burguesa, para identificar as questões de ordem técnica e jurídica que a ação do tempo promoveu em suas instituições tradicionais.

1.3 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AUTURAL

Várias são as teorias que tentam explicar a natureza jurídica dos direitos autorais. Segundo Lipszyc⁹, a primeira norma legal que reconheceu o direito subjetivo do autor sobre sua obra foi o Estatuto da Rainha Ana em 1710 na Inglaterra, tendo-o feito como direito de propriedade.

A autora ressalta ainda que as várias legislações autorais, surgidas no século XIX e no começo do século XX¹⁰, trata-

ram o Direito Autoral como um direito de propriedade, daí a adoção das expressões propriedade literária e artística e propriedade intelectual.¹¹

Essas expressões foram adotadas inclusive por legislações recentes, a exemplo da atual Lei do *Software* (9.609/98)¹² e julgados recentes, como na decisão do Recurso Especial n. 260.099/2000 em que, julgando questão sobre a prescrição da pretensão indenizatória pela violação de Direito Autoral, o Superior Tribunal de Justiça considerou-o como direito de propriedade, como a seguir transcrito:

Destarte, conta-se o prazo para promover a ação de reparação de danos, por ofensa a Direito Autoral, a partir da data da violação do direito de propriedade, *in casu*, no ano de 1970, [.]

Essa concepção do Direito Autoral como direito de propriedade, propriamente dito, foi alvo de vários questionamentos assim resumidos por Colombet¹³:

- a) o objeto do direito de propriedade seria um bem material, ao passo que o objeto do Direito Autoral é um bem imaterial;
- b) a propriedade é perpétua e o Direito Autoral é limitado no tempo;
- c) a obra protegida não se confunde com o suporte material em que está fixada;
- d) a aquisição do Direito Autoral não se dá pelas formas tradicionais de aquisição da propriedade, mas pela criação;

⁸ AMARAL, Francisco. Transformação dos sistemas positivos a descodificação do direito civil brasileiro. *O Direito*, p. 40-41

⁹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Zavalia, 2001, p. 19.

¹⁰ Como é o caso do Código Civil brasileiro de 1916.

¹¹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 19.

¹² Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, observado o disposto nesta Lei.

¹³ COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*. Paris: Précis Dalloz, 1976, p. 15.

- e) a transferência do Direito Autoral não extingue plenamente o vínculo existente entre autor e obra, ao contrário do que ocorre com o direito de propriedade em que a transferência rompe integralmente o vínculo existente entre o bem e o titular anterior.

Constata-se, assim, que apesar de conterem certas semelhanças, o termo propriedade não é suficiente para explicar, em sua complexidade, o Direito Autoral. Apesar disso, a Diretiva Européia sobre Direitos Autorais e Afins na Sociedade da Informação – DDASI – manteve a concepção do Direito Autoral como expressão do direito de propriedade.

Os direitos autorais têm natureza jurídica dúplice, isto é, a obra intelectual tem um aspecto pessoal e outro material. O aspecto pessoal vincula o autor à obra e o aspecto material garante-lhe sua exploração econômica. O primeiro tem natureza extrapatrimonial, o segundo, patrimonial. O primeiro visa proteger a personalidade do autor exteriorizada na obra, o segundo o bem jurídico imaterial por ela produzido¹⁴.

Como visto, a exteriorização da criação intelectual humana é, portanto, fato gerador de duas situações jurídicas, uma patrimonial, outra extrapatrimonial¹⁵. Isso porque a

¹⁴ “Por ultimo, merece ser citada la teoria dualista, que intenta conciliar las tesis anteriores, y distingue, para proteger la creacion, dos derechos diferentes, interdependientes, pero distintos uno del outro: el patrimonial, transferible, y el personal, insubrogable.” (EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*. Astrea: Buenos Aires, 1999, p. 6)

¹⁵ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 106: “De um ponto de vista objetivo, a situação é um interesse que, essencial a sua existência, constitui o seu núcleo vital e característico, interesse que pode ser ora patrimonial, ora de natureza pessoal e existencial, ora um e outro juntos, já que algumas situações patrimoniais são instrumentos para a realização de interesses existenciais ou pessoais.”

criação autoral é uma expressão da personalidade do autor que possui valor econômico¹⁶.

Assim, o Direito Autoral não pode prescindir da tutela das repercussões econômicas da criação nem sequer da tutela do aspecto da personalidade do autor exteriorizado na obra.

Ressalte-se que apesar de se originarem do mesmo fato, possuem objetos distintos. O objeto do direito patrimonial é a obra, enquanto que o do direito moral é a exteriorização da personalidade do autor que restou impressa naquela. A proteção pessoal não incide sobre a obra criada senão de forma mediata ou indireta.

A constatação da natureza dúplice do Direito Autoral gerou uma diversidade de posições doutrinárias. Segundo leciona Lipszyc¹⁷, essas posições podem ser divididas em dois grandes grupos, os dualistas, que separam o conjunto de faculdades reconhecidas aos autores em duas classes distintas de direitos que não se confundem, direitos morais e patrimoniais, e os monistas, que consideram que este desmembramento entre direito moral e patrimonial é meramente fictício, existindo um único e uniforme direito de autor que englobaria os dois aspectos.

Entre as teorias monistas merece ressalva a teoria do direito da personalidade. Essa teoria considera que o direito de autor é um direito sobre a própria pessoa, seu objeto seria o pensamento do autor enquanto elemento interno à própria pessoa. Foi criticada por não separar o pensamento do autor do objeto por ele pensado¹⁸.

¹⁶ BEVILÁQUA, Clovis. *Teoria geral do direito civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p. 317

¹⁷ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 22

¹⁸ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*. Milão: Giuffrè, 1966, p. 74. “Si cade così nell'equivoco della identificazione della cosa pensata con il pensiero: oggetto del diritto di autore no

Segundo Algardi¹⁹, cada uma das teorias monistas sobre a natureza do Direito Autoral tem sua cota de erros e acertos, pois reconhecem um dos aspectos da realidade jurídica do Direito Autoral, mas ignoram o outro.

As teorias dualistas explicam de forma mais clara a natureza jurídica do Direito Autoral. Segundo Algardi²⁰, o Direito Autoral tutela interesses de natureza diversa que derivam de um mesmo fato: a criação. Na sua origem o direito seria essencialmente pessoal. O elemento patrimonial aparece com a utilização da obra. A partir daí, acompanham-na até que ela caia em domínio público, momento em que o elemento patrimonial se esvai e o pessoal se reafirma. Nos dizeres de Savatier²¹, no aspecto patrimonial, a comunicação da obra gradativamente se transforma de exclusivo em comunhão e, ao final, em abandono.

O legislador brasileiro optou por recepcionar a teoria dualista, tratando o hibridismo autoral como dois direitos distintos e autônomos.

No primeiro caso tem-se os direitos morais de autor, a exemplo do direito à paternidade da obra, do direito à menção do nome, do direito ao inédito, do direito à integridade da obra, do direito de retirada, do direito de modificar a obra e do direito de acesso a exemplar único e raro²².

puo essere il pensiero e l'attività pensante ma è la sua estrinsecazione, il suo prodotto sensibile. Erroneamente si confonde la persona nell'atto della concezione artistica col pensiero esternato, e trasfuso nel libro, nella statua, nelle note, la persona con la cosa, il produttore col prodotto."

¹⁹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 98.

²⁰ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 117.

²¹ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*. Paris: Librairie Générale de Droit, 1953, p. 19.

²² No que se refere ao direito de acesso, trata-se de inovação trazida pelo art. 24 da LDA.

No segundo caso, tem-se o direito patrimonial de autor que consiste no direito exclusivo de usar, fruir e dispor da obra intelectual²³.

A autonomia desses direitos na nossa legislação é clara. Os direitos morais são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, enquanto que os direitos patrimoniais são temporários e passíveis de cessão. Há casos, inclusive, que os direitos patrimoniais podem pertencer, em caráter originário e exclusivo, a outrem, que não o autor, como previsto no art. 4º da Lei do *Software*.²⁴

²³ Art. 28 da LDA.

²⁴ Essa questão será objeto de análise posterior.

CAPÍTULO II

DIREITOS MORAIS

2.1 DIREITOS MORAIS

Os direitos morais de autor, segundo Emery¹, nasceram de construção jurisprudencial francesa na primeira metade do século XIX.

Segundo Savatier², o direito moral de autor é o reconhecimento da soberania do criador da obra.

O art. 24 da LDA³ prevê que são direitos morais do autor o direito de reivindicar a autoria, o direito à menção do nome, o direito ao inédito, o direito à integridade da obra,

¹ EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*, p. 5.

² SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 19.

³ Art. 24 São direitos morais do autor:

I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II – o de ter seu nome, pseudônimo, ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor na utilização de sua obra;

III – o de conservar a obra inédita;

IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra;

V – o de modificar a obra antes ou depois de utilizada;

VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

o direito de modificação da obra, o direito de retirada e o direito de acesso a exemplar único e raro.

Segundo Algardi⁴, pode-se reconhecer em cada um desses direitos dois elementos morais fundamentais: o direito à liberdade e o direito à honra. É de se acrescentar, todavia, o direito à identidade pessoal e o direito à imagem.

Ressalte-se que a Lei de Direitos Autorais brasileira não se restringiu à regra mínima⁵ fixada pela Convenção de Berna que exige dos países signatários pelo menos a proteção ao direito de reivindicar a autoria e ao direito à integridade da obra⁶.

Entretanto, tratando-se de programas de computador a proteção restringe-se à regra mínima, como se vê de seu art. 2º, § 1º:

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer

VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor; que, em todo o caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

⁴ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 120.

⁵ Como exemplo, tem-se o § 20 da lei italiana (L. 22 abril 1941 n. 633) que se atém à regra mínima fixada pela Convenção de Berna: "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possono essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione."

⁶ Art. 6 bis 1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação

tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação

Nota-se assim, à exceção dos programas de computador, que a intenção do legislador brasileiro foi de conceder ampla proteção à personalidade do autor exteriorizada na obra.

A sistematização dos direitos morais de autor, agrupando-os em um capítulo separado dos direitos patrimoniais, foi sem dúvida um acerto do legislador brasileiro, facilitando a proteção específica de cada uma das referidas faculdades⁷.

Ocorre que a técnica legislativa de enumeração de direitos morais de autor, talvez não tenha sido a melhor forma de se garantir tal proteção. Como leciona Ascensão, a tipicidade legal gera uma interpretação restritiva das faculdades reconhecidas: "Supomos que a lei especificou as faculdades de ordem pessoal que são admissíveis sobre a obra."⁸

Por outro lado, poder-se-ia dizer que a enumeração legal não retiraria o caráter genérico da tutela moral do autor de proteção a sua personalidade em toda a sua complexidade.

Segundo Cortiano Junior⁹, nos casos não englobados pela enumeração legal, aplica-se a proteção genérica.

Segundo Berti, "o conceito dos direitos da personalidade não é, em todo caso, uma noção de conteúdo fixo, imutável

⁷ Em algumas legislações ocidentais, a exemplo da Lei argentina, não houve um tratamento sistemático dos direitos morais de autor, o que lhes dificulta a proteção, uma vez que os direitos morais tem que ser apreendidos de forma assistemática e indireta na Lei

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 132.

⁹ CORTIANO JUNIOR, Eroulth. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de personalidade. In: FACHIN, Luis Edson (Coord.) *Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 47.

no espaço e no tempo, amoldando-se facilmente às estruturas de uma definição jurídica”¹⁰.

Para Tepedino¹¹, a tutela da personalidade humana é elástica, no sentido de que, por força do princípio constitucional de promoção da dignidade humana, abrange todas as situações jurídicas existenciais, estando previstas ou não em lei.

Todavia, faz-se necessária a análise de cada um dos direitos morais do autor enumerados no art. 24 da LDA.

2.2 DIREITO DE REIVINDICAR A AUTORIA DA OBRA

O direito de reivindicar a autoria é o direito do autor de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra. Segundo Algardi¹², em virtude da criação se estabelece entre o autor e sua obra um vínculo originário, perpétuo e insubstituível.

Não se confunde com o direito à autoria. O direito de reivindicar a autoria, como regra, pressupõe um ato de violação daquele¹³, como os casos de utilização da obra sem expressa menção do nome do autor ou de sua utilização sob o nome de terceiros. Em síntese, é o direito do autor de se opor à usurpação de sua paternidade sobre a obra.

Segundo Lucchesi¹⁴, o direito de reivindicar a autoria da obra corresponde ao interesse de fazer conhecer ou reconhecer o verdadeiro autor da criação.

¹⁰ BERTI, Silma Mendes. Fragilização dos direitos da personalidade. *Revista da Faculdade Mineira de Direito*, Belo Horizonte, v. 5/6, p. 238-248, 1ª e 2ª sem. 2000, p. 239.

¹¹ TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 49.

¹² ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 120.

¹³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 141.

¹⁴ LUCCHESI, Franco. *Voltaggio I beni immateriali*. Milano: Giuffrè, 1962, p. 279.

A natureza do direito de reivindicar a autoria da obra tem sofrido críticas no sentido de se tratar de um direito de natureza processual e não material¹⁵.

O direito de reivindicar a autoria da obra seria a pretensão surgida em virtude da violação do direito à autoria¹⁶. Assim, não comungaria das características inerentes aos direitos morais de autor.

Segundo esse ponto de vista, a criação da obra geraria o direito à autoria. A violação desse direito geraria o direito de reivindicá-la¹⁷.

Questiona-se, ainda, se o direito à autoria poderia ser exercido de forma negativa, nos casos de falsa imputação de autoria. A questão surgiu em 1826 quando a Corte de Paris reconheceu a pretensão dos herdeiros de um dos Ministros de Napoleão de retirar o seu nome de suas supostas memórias apócrifas¹⁸.

Não há dúvida que nesses casos o nome do autor é usado abusivamente, mas essa pretensão, não surge da violação de um Direito Autoral, mas da violação do direito ao nome, propriamente dito, direito da personalidade inato atribuído a toda e qualquer pessoa física¹⁹.

¹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 141.

¹⁶ Art. 189. “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, [...]” (Código Civil brasileiro, 2002).

¹⁷ Essa realidade dinâmica da relação jurídica é explicada pelo autor: “Isto posto, busquemos analisar a situação jurídica obrigacional na contingência variável de sua contextura dinâmica, tendo em vista que os fatos jurídicos não ocorrem num campo imaculado, virgem de soluções jurídicas anteriores, senão que esbarram muitas vezes em situações preexistentes, para configurá-las de forma nova ou para gerar, a partir delas, novas situações jurídicas. Assim, o que foi efeito da incidência de norma antecedente sobre fato anterior, passa a ser suporte fático da incidência de norma consequente, no contínuo (des)encadear-se das relações jurídicas concretas.” (COSTA JUNIOR, Olímpio. *A relação jurídica obrigacional*. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 57).

¹⁸ EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*, p. 77.

¹⁹ Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei (Código Civil brasileiro, 2002).

Nesses casos, estar-se-ia negando a própria existência do Direito Autoral. Conforme leciona Ascensão, “aquele que nega a autoria de uma obra não age como autor”²⁰.

2.3 DIREITO À AUTORIA

O direito à autoria é o direito do autor de ter o seu nome, pseudônimo, ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização da obra. É também denominado direito à paternidade da obra, ou direito à menção do nome.

Segundo De Sanctis²¹, qualquer modo inequívoco, mesmo que inusitado, de se indicar o autor é válido como indicação da paternidade.

Pseudônimo é um nome fictício que o autor se atribui como identificação pessoal em substituição ao nome civil²².

Pode-se destacar duas espécies de pseudônimo: o nome artístico e o pseudônimo-máscara.

O nome artístico não tem a intenção de esconder a identidade do autor, mas de impressionar o público adotando nome mais sonoro, promocional ou revelador de sua personalidade artística. O pseudônimo-máscara, por outro lado, tem a finalidade de esconder o autor por trás do nome fictício²³.

A LDA²⁴ prevê presunção relativa de paternidade daquele que é indicado ou anunciado como tal na utilização da obra.

²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 142.

²¹ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*. Milão: Giuffrè, 2000, p. 57.

²² DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 59.

²³ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 59.

²⁴ Art. 13 da LDA.

Segundo Debois²⁵, é a faculdade reconhecida ao criador de tornar público o ato de criação, indicando a filiação da obra e, conseqüentemente, seu próprio nome.

Para Debois²⁶, o direito à autoria de uma obra teria a mesma natureza do direito à paternidade de um filho. Tal afirmativa é, contudo, exagerada, tendo-se em vista que ao autor é permitido o anonimato, enquanto que ao filho é garantido o direito de ter sua paternidade reconhecida.

Segundo Lipszyc²⁷, este anonimato deve ser respeitado, mesmo após a morte do autor, inclusive por seus herdeiros, ressaltando-se o direito de livre investigação e crítica.

Isto é, sem o consentimento do autor seu nome não poderia ser vinculado à obra em sua comercialização, o que não impediria, por exemplo, que o nome do autor da obra anônima fosse descoberto e revelado por terceiros, mesmo assim, a divulgação da obra permaneceria anônima (sem designação do nome do autor).

O autor pode escolher se deseja que a obra seja utilizada sob seu nome, sob um pseudônimo, sob um sinal convencional, ou mesmo, sem qualquer menção de quem seja seu autor: anonimato.

É lógico que nesses casos é reservado ao autor o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra, uma vez que os direitos morais do autor são irrenunciáveis. Essa situação vem expressamente prevista na Lei italiana²⁸, bem como na brasileira²⁹.

O fato de o autor não ter vinculado seu nome à obra, não significa renúncia a tal vinculação, que pode, a qualquer

²⁵ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*. Paris: Dalloz, 1950, p. 615.

²⁶ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 616.

²⁷ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 167.

²⁸ 21 “L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.”

²⁹ Art. 52 da LDA.

tempo, ser feita por ele. Assim, enquanto o autor não reivindicar a menção de seu nome, a obra deverá ser divulgada na forma anônima, não podendo ser divulgada sob o nome de outrem, o que consistiria violação de direitos autorais³⁰, salvo se previamente autorizada, como é o caso dos *ghost writers*, em que o autor real permite que sua obra seja utilizada em nome de um autor aparente.

Nesses casos, a utilização da obra em nome de outrem não configura violação de direitos autorais, porque fora autorizada, mas, por outro lado, também não acarreta renúncia ao direito à autoria, podendo o autor real reivindicá-la a qualquer tempo, caso em que estaria sujeito às perdas e danos contratuais³¹. Dessa forma, o exercício de seus direitos acabaria por restringir sua própria liberdade, comprometendo sua opção pelo anonimato.

No que se refere aos direitos patrimoniais, a LDA garantiu ao autor a possibilidade de se manter no anonimato legitimando o responsável pela publicação da obra ao exercício dos direitos patrimoniais do autor³².

No mesmo sentido a Lei italiana legitima o responsável pela publicação para exercer os direitos do autor enquanto esse não se revelar³³.

³⁰ É o caso da sátira de costumes anônima denominada "A arte de furtar" de 1744 que por sua linguagem afiada como se vê do seguinte trecho ("E para que não engasgue algum escrupuloso nesta proposição, com a máxima de que não há ladrão que seja nobre, pois o tal ofício traz consigo extinção de todos os foros da nobreza, declaro logo que entendo o meu dito segundo o vejo exercitado em homens tidos e havidos pelos melhores do mundo, que no cabo são ladrões, sem que o exercício da arte os deslustre, nem abata um ponto do timbre de sua grandeza [...]") foi inicialmente atribuída ao Pe Antonio Vieira e posteriormente reconhecida a falsidade dessa autoria sendo atualmente divulgada como anônima. A ARTE de furtar. Porto Alegre: L&PM, 2005, p. 10.

³¹ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 61.

³² Art. 40 da LDA

³³ Art. 9 L. 633/1941.

Obra anônima não é obra sem autor, mas obra divulgada sem menção do nome do autor. A LDA equipara à obra anônima a obra de autor desconhecido³⁴.

Há que distingui-las, porém. Obra anônima é aquela que foi divulgada voluntariamente pelo autor sem a menção de seu nome, pseudônimo ou qualquer sinal convencional.

A obra de autor desconhecido é aquela que, em decorrência de sua larga utilização, ou do transcurso de um longo período de tempo, ou mesmo pelo grau de informalidade do uso, o nome do autor é esquecido, omitido ou ignorado (perde-se a memória do criador)³⁵.

2.4 DIREITO AO INÉDITO

O direito ao inédito é a faculdade de o autor conservar a obra inédita. A raiz do direito ao inédito é o direito à intimidade³⁶. Se a obra é a exteriorização de uma faceta da personalidade de seu autor, assegura-se-lhe o direito de não revelá-la, ou de não ser por ela revelado. O direito ao inédito é um direito de reserva da personalidade do autor, mesmo que possa parecer paradoxal a idéia de se exteriorizar uma

³⁴ Art. 5º, inciso VIII, alínea b.

³⁵ Por exemplo, tem-se o seguinte texto datado de 1900 e divulgado pela Internet como se fosse anônimo. Ocorre que, devido ao transcurso de longo tempo de utilização e à informalidade com que essa se revestiu, não há como se afirmar se se trata realmente de um texto anônimo ou de um texto cujo nome do autor em um dado momento de sua utilização possa ter sido esquecido ou negligenciado. "Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più in fretta del leone, o verrà uccisa. Ogni mattina, in África, un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più della gazzella, o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa se tu sei un leone o una gazzella: Sarà meglio che cominci a correre."

³⁶ SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito à intimidade e à vida privada*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 41.

obra e não divulgá-la³⁷. É a mais egoísta das faculdades atribuídas ao autor³⁸.

Contrariamente ao que ocorre na propriedade industrial, em que a ausência de exploração do objeto da patente ou sua utilização abusiva geram a licença compulsória do direito do inventor³⁹, em matéria de Direito Autoral o reconhecimento do direito ao autor não se condiciona à obrigatoriedade de seu exercício. Segundo leciona Algardi, o reconhecimento ao autor do direito de publicação da obra não o transforma em um sujeito passivo do dever de fazê-lo.

O direito ao inédito atinge não apenas a obra completa como também qualquer de suas partes.

É importante frisar que o direito ao inédito não consiste na manutenção da obra no mundo interior do autor como pensamento não exteriorizado. Conforme se verá posteriormente, se não houver exteriorização do pensamento, não haverá proteção autoral. Assim, o direito ao inédito só surge após a exteriorização da criação. Exteriorizada a obra, surge para o autor a faculdade de divulgá-la ou não. Assim, consiste na faculdade de o autor divulgar ou não a obra por ele criada.

Questão que aflora da análise do direito ao inédito é a que diz respeito à possível existência de um interesse público na divulgação da obra⁴⁰, seja por promover o desen-

³⁷ “Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. [...] Em cofre perde-se a coisa à vista

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la. [...] Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,

Por isso se declara e declama um poema:

Para guardá-lo [...]” (CICERO, Antonio Guardar In: MORICONI,

Italo. *Os cem melhores poemas brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 337)

³⁸ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 130.

³⁹ Arts 68 a 74 da Lei 9 279/1996 (Código de Propriedade Industrial).

⁴⁰ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Comercio electronico*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2001, p. 98

volvimento nacional, seja por gerar informação, educação, cultura ou ciência.

Esse interesse, que pode ser menos visível em obras artísticas e literárias, mostra-se aparente nas obras científicas, nos programas de computador, nos bancos de dados, dentre outros.

Essa é uma lacuna da Lei Autoral brasileira, que sobre põe o interesse individual do autor ao interesse social de acesso à obra. A Lei italiana se posicionou de forma diversa em seu art. 112, prevendo que os direitos autorais, à exceção do direito ao inédito durante a vida do autor, podem ser expropriados por razão de interesse público⁴¹.

Do referido artigo depreende-se que, após a morte do autor, o direito ao inédito poderá ser expropriado. Poderá, inclusive, ser objeto de renúncia por seus herdeiros, que poderão publicá-la livremente, salvo se o autor, em vida, tiver vedado expressamente a publicação da obra, mesmo após a sua morte⁴².

Questiona-se sobre a possibilidade de a obra inédita ser objeto de plágio. A resposta é afirmativa. O plágio, nesse caso, reveste-se de gravidade ainda maior já que viola não apenas a autonomia privada do autor, como também a garantia constitucional de livre manifestação do pensamento, tornando público o que o autor pretendia manter secreto⁴³.

2.5 DIREITO À INTEGRIDADE DA OBRA

O direito à integridade da obra é a faculdade do autor de se opor a qualquer modificação da obra⁴⁴ ou à prática de

⁴¹ Art. 112. “I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.” (Lei n. 633/1941)

⁴² ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 132.

⁴³ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 132.

⁴⁴ O termo modificação é interpretado em sentido amplo englobando também deformações ou mutilações da obra a teor do art. 6 bis da convenção de Berna e do § 20 da Lei italiana.

qualquer ato que, de qualquer forma, possa prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação e honra.

Note-se, ainda, que o inciso IV do art. 24 se divide em duas partes: na primeira confere proteção ao autor em relação à prática de atos que possam prejudicar sua obra, já na segunda confere proteção ao autor em relação à prática de atos que possam atingi-lo em sua reputação ou honra.

Segundo Lipszyc⁴⁵, é um direito bipolar, pois o autor tem direito a que seu pensamento não seja desnaturado, bem como a sociedade tem direito de acesso às obras em sua autêntica expressão⁴⁶.

O legislador condiciona o exercício do direito do autor à existência de graves razões morais, o que demonstra uma tentativa de equacionar o interesse do autor e os interesses de terceiros evitando, assim, que estes fiquem ao arbítrio do autor que poderia opor obstáculos excessivos e injustificados à circulação ou à utilização da obra⁴⁷.

Há casos, inclusive, em que a LDA permite expressamente a modificação da obra por terceiros. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição.

Nota-se, assim, que a legislação brasileira confere uma proteção relativa à integridade da obra, acompanhada por Itália, Portugal, Venezuela, Reino Unido, México, Marrocos, Índia, Holanda, Espanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, dentre outros.⁴⁸

⁴⁵ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 168.

⁴⁶ No mesmo sentido o direito ao repúdio de projeto arquitetônico garantido no art. 26 da LDA.

⁴⁷ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 138.

⁴⁸ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 169.

Outro grupo de países adota uma proteção absoluta, sem qualquer condicionamento, a exemplo de Argentina, Bélgica, Canadá, Cuba, França, Japão, Paraguai, Peru e Suíça⁴⁹.

A defesa de tal posição se faz pelo fato de que a modificação de uma única vírgula, ponto ou de uma única nota pode afetar a harmonia da obra, que depende de todas as suas partes⁵⁰.

Há que questionar, todavia, se a referida faculdade poderia ser utilizada pelo autor que tenha autorizado a modificação.

A Lei Autoral brasileira é silente. Por imposição da autonomia privada, contudo, a resposta mais acertada parece ser negativa⁵¹.

No mesmo sentido, a Lei italiana em seu art. 22 prevê que o autor que tiver conhecido e aceitado as modificações da própria obra não poderá agir para impedir ou suspender sua utilização.

2.6 DO DIREITO DE MODIFICAR A OBRA

O direito de modificação é a faculdade do autor de alterar a obra a qualquer tempo, antes ou depois de utilizada⁵².

Há aqui estreita ligação com o direito à integridade da obra. A faculdade de se opor a modificações da obra resulta

⁴⁹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 169.

⁵⁰ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 22.

⁵¹ É o que se apreende analogicamente do art. 20 do Código Civil: Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

⁵² O conceito de obra pronta e acabada é, contudo, relativo. Há aquelas que estão em permanente construção e a idéia de obra final, para o público, não passa de um momento transitório para o autor.

em um direito exclusivo de modificá-la. Algardi⁵³ trata-os como duas faces do mesmo direito.

Por essa razão, há os que defendem que o exercício do direito de modificar a obra também estaria condicionado à existência de graves razões morais, apesar de nossa legislação não tê-lo feito expressamente⁵⁴.

Segundo Algardi⁵⁵, o direito de modificar a obra seria pessoal e patrimonial. Enquanto a obra fosse inédita, teria um aspecto pessoal, após sua publicação se confundiria com o exclusivo de exploração econômica.

Ao que parece, o direito de modificar a obra não pode ser claramente identificado por essa acepção. Isso porque enquanto a obra ainda é inédita não se fala em exercício de direito de autor de modificação, mas em "poder geral de criação"⁵⁶.

Tampouco se confunde com o direito exclusivo de exploração econômica no que tange às várias possibilidades de transformação da obra.

Segundo Lipzyc⁵⁷, o direito de modificar a obra, cujo exercício exclusivo compete ao autor, se refere unicamente à integridade dela em sua forma originária não se confundindo com o título de sua transformação (adaptações, traduções, melhoramentos), visto que, nesse caso, a individualidade da obra originária permaneceria inalterada.

A transformação, por sua vez, cria uma obra derivada, independente da originária, que recebe proteção diversa. A

⁵³ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 135.

⁵⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 150.

⁵⁵ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 136.

⁵⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 147: "O poeta que retoca indefinidamente uma ode exerce o poder de criação."

⁵⁷ LIPZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 171.

modificação da obra originária não cria uma obra derivada, não há nova proteção, inclusive no que se refere ao decurso do prazo de proteção⁵⁸.

A transformação desmembra-se da obra originária, a modificação integra-se a ela.

Assim, o direito de transformação da obra, ao contrário do direito de modificá-la, não é exclusivo do autor, podendo ser exercido por ele, cedido a terceiros e está sujeito aos efeitos do domínio público.

Por outro lado, o exercício do direito de modificá-la pode-se confrontar com legítimos interesses de terceiros. É o caso, por exemplo, da modificação da obra aumentar os custos de edição⁵⁹ ou o caso de o pintor ou de o escultor de-sejar efetuar modificações no exemplar original da obra cuja propriedade material já não mais lhe pertence. Dessa forma, o art. 24, § 3º, da Lei brasileira prevê o pagamento de indenização prévia pelos prejuízos eventualmente causados⁶⁰.

2.7 DO DIREITO DE RETIRADA

O direito de retirada é a faculdade de o autor retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização impli-

⁵⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 148.

⁵⁹ Nesse caso, a teor do art. 66, parágrafo único, da LDA, o editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade.

⁶⁰ Ressalte-se que o fato de se exigir o pagamento de indenização pelo autor não significa que o ato por ele praticado seja ilícito, uma vez que ele age no exercício regular de um direito reconhecido. O que reforça a idéia de que nosso ordenamento adota uma concepção pluralista das fontes da responsabilidade civil, admitindo-se a responsabilidade civil proveniente da prática de atos lícitos. Essa questão já foi previamente abordada em artigo de nossa autoria na seguinte obra: FIUZA, César. *Curso avançado de direito civil*. São Paulo: Thompson, 2005, p. 298.

carem afronta à sua reputação e imagem. É uma faculdade perigosa, pois pode prejudicar terceiros de boa-fé.

No intuito de evitar o abuso desse direito por parte do autor, o que seria excessivamente danoso para o legítimo usuário da obra, a Lei brasileira, acertadamente, condiciona o seu exercício à ocorrência de afronta à reputação e imagem do autor⁶¹, bem como ressalva a prévia indenização a terceiros⁶².

Ressalte-se que o exercício regular dessa faculdade enseja a prévia indenização prevista no art. 24, § 2º (indenização por ato lícito), enquanto que seu exercício abusivo caracterizaria ato ilícito funcional, a teor do art. 187 do Código Civil (CC), cujos efeitos não se restringem ao pagamento de indenização, apesar de não a excluírem. Caracterizando-se o exercício abusivo, o legítimo possuidor poderia, inclusive, ter assegurado judicialmente seu direito de permanecer na utilização da obra.

O direito de retirada e o direito ao inédito possuem raízes comuns⁶³. No direito ao inédito, porém, a Lei não impõe tal condição, uma vez que seu exercício não implica, como regra, violação de direitos de legítimo usuário ou possuidor, pois a obra ainda encontra-se sob o domínio do autor.

Frise-se que o exercício do direito de retirada não incide, necessariamente, sobre os exemplares da obra já comercializados, mas tem a finalidade de fazer cessar a comercialização, distribuição ou divulgação anteriormente consentida. Segundo Algardi⁶⁴, o direito de retirada faz com que a obra seja

⁶¹ Art. 24, inciso VI.

⁶² Art. 24, § 3º.

⁶³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 137: "O direito de retirada é como que a outra face do direito ao inédito. Mas a relação é sucessiva, porque só após cessado o direito ao inédito surge o direito de retirada."

⁶⁴ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 134.

retirada de circulação e aqueles que permanecerem na posse de algum exemplar terão que se restringir ao uso privado.

Por essa razão a terminologia direito de retirada foi substituída em várias legislações pelas expressões direito de arrependimento ou direito de retrato.

Segundo Colombet⁶⁵, a melhor expressão seria direito de retrato, uma vez que o arrependimento se dá internamente e o retrato seria a manifestação da vontade de fazer cessar a utilização anteriormente consentida.

A expressão direito de retrato, em verdade, bem caracteriza a faculdade como exceção ao princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Segundo Lipszyc⁶⁶, ao assegurar o direito de retirada ao autor, a Lei pretende conciliar dois princípios que se apresentam contrapostos: de um lado a obrigatoriedade contratual, de outro, a liberdade de expressão (aqui exercida de forma negativa), reconhecendo a preeminência desta.

Há quem reconheça essa faculdade ao plagiário arrependido⁶⁷. É necessário, todavia, diferenciar o plágio absoluto do plágio relativo. Plágio absoluto ocorre quando houver identidade total entre a obra original e a obra plagiada. Plágio relativo ocorre quando há identidade parcial entre a obra original e a obra plagiada.

No caso de haver plágio relativo não há como se negar a existência de obra diversa da original, caracterizando-se uma situação jurídica autoral amparada pela lei, ressalvados os direitos do autor da obra plagiada. No caso de haver plágio absoluto, por outro lado, não há obra diversa, situação em que sequer se poderia falar em Direito Autoral.

⁶⁵ COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*, p. 148.

⁶⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 173.

⁶⁷ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 134.

A Lei italiana, nos arts. 142 e 143, disciplina o direito de retirada da obra, exigindo uma série de condições para seu exercício:

- a) pagamento de indenização prévia;
- b) existência de graves razões morais;
- c) exercício personalíssimo do direito;
- d) notificação da intenção do autor ao cessionários de direitos;
- e) notificação da intenção do autor ao Conselho da Propriedade Literária, Artística e Científica.

Cumpridas as formalidades conta-se o prazo de um ano, a partir da data da última notificação, para oposição dos interessados ou para habilitação para obtenção do ressarcimento dos danos.

É importante indagar sobre o destino da obra após o exercício do direito de retirada. Alguns defendem sua destruição compulsória, inclusive como meio de se coibir o exercício abusivo do direito pelo autor, outros apenas a proibição de sua recolocação no mercado⁶⁸.

Apesar da discussão acalorada, deve-se considerar que o autor não poderia ser punido pelo exercício regular de um direito assegurado na Lei. Além disso, há casos em que o autor reconhece ter cometido um erro técnico, científico ou moral na obra, situação que o motiva a retirá-la de circulação para correção, revisão ou atualização para, posteriormente, recolocá-la em circulação⁶⁹.

Nesses casos, Lipszyc⁷⁰ defende que se deveria assegurar ao contratante anterior direito de preferência na contrata-

⁶⁸ COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*, p. 150

⁶⁹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 134

⁷⁰ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 174.

ção em condições similares às originárias, a fim de se evitar o desvio de finalidade no exercício do direito do autor, que poderia forçar uma nova contratação em condições econômicas mais favoráveis.

2.8 DIREITO DE ACESSO

O direito de acesso é a faculdade do autor de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontra legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

É sempre importante lembrar que a finalidade do direito de acesso é a de preservar tanto a memória da obra como a do próprio autor.

A princípio poder-se-ia questionar se o direito de acesso não seria um abuso por parte do autor garantido pela Lei, uma vez que o terceiro seria o legítimo detentor da coisa. É justamente por essa razão que a Lei limita o exercício do direito de acesso de forma a que cause o menor inconveniente possível, sem prejuízo das indenizações cabíveis.

Além disso, é de se ressaltar que o acesso à obra só pode ser considerado como exercício dessa prerrogativa no caso de a obra se encontrar legitimamente em poder de terceiro, visto que no caso da posse do terceiro sobre a obra ser ilegítima, estar-se-ia diante de violação de direitos autorais, aplicando-se ao caso as sanções previstas no art. 101 e seguintes da Lei brasileira, situações em que o poder do autor atinge não apenas a obra em si, como também os exemplares fraudulentamente produzidos ou comercializados⁷¹.

⁷¹ A distinção entre obra e exemplar será objeto de análise posterior.

2.9 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS MORAIS DE AUTOR

Conforme já referido anteriormente, o reconhecimento dos direitos morais surge da necessidade de se proteger a personalidade do autor exteriorizada com a obra. Assim, sob uma visão pluralista, eles podem ser relacionados como direitos da personalidade expressamente protegidos na Lei⁷².

Como leciona Santilli⁷³, trata-se de uma categoria do direito à identidade pessoal e como tal visa proteger os interesses da personalidade do autor.

Os direitos da personalidade são: extrapatrimoniais, absolutos, indisponíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, necessários, vitalícios, essenciais, genéricos e preeminentes⁷⁴.

É lógico que, tratando-se de direitos morais de autor, nem todas as características serão aplicadas. Isso porque o surgimento do direito moral do autor subordina-se ao implemento de condição suspensiva: a criação. Assim, ainda que, em tese, todos os indivíduos estejam aptos a adquiri-lo, essa aquisição só se efetiva para os que exteriorizarem sua criação.

Dessa forma, não se pode dizer que sejam genéricos, por não serem concedidos a todos, tampouco necessários, uma vez que nem todo ser humano os detém, necessariamente.

Portanto, os direitos morais de autor são extrapatrimoniais, absolutos, indisponíveis, imprescritíveis, intransmissíveis e preeminentes.

⁷² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti *Tratado de direito privado*: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, v. 1, p. 8.

⁷³ SANTILLI, Marina *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*. Milão: Giuffrè, 1988, p. 243.

⁷⁴ FIUZA, César. *Direito civil*: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 163.

2.9.1 EXTRAPATRIMONIALIDADE

São extrapatrimoniais porque não podem ser traduzidos em dinheiro. Segundo Colombet⁷⁵, porque são indissociáveis de seu autor, prendendo-se a ele como a chama se prende ao fósforo.

É lógico, contudo, que a extrapatrimonialidade desses direitos não os impede de produzir repercussões econômicas, como no caso de se buscar indenização por danos materiais e morais decorrentes de sua violação⁷⁶.

2.9.2 EFICÁCIA ABSOLUTA

São absolutos porque são oponíveis *erga omnes*, isto é, o autor pode opô-los a qualquer um que ameace, tente ou efetivamente viole seus direitos morais. Segundo Perlingieri⁷⁷, o direito absoluto é aquele que não se contrapõe, inicialmente, a um centro de interesses individuado, mas contrapõe-se à generalidade dos membros da sociedade. Assim, o centro de interesses contraposto só poderia ser determinado posteriormente, quando de sua violação ou ameaça.

No mesmo sentido Costa Junior⁷⁸ leciona que o fato de existir um dever geral de respeito e abstenção contrapondo-se ao direito absoluto não impõe, automaticamente, a todos, a condição de sujeito passivo universal, por não integrarem, inicialmente, uma situação jurídica concreta.

2.9.3 INDISPONIBILIDADE

São indisponíveis, pois o autor não pode deles dispor, seja a título gratuito, seja a título oneroso. São, portanto, ina-

⁷⁵ COLOMBET, Claude *Propriété littéraire et artistique*, p. 128.

⁷⁶ LIPSZYC, Delia *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 157.

⁷⁷ PERLINGIERI, Pietro *Perfis do direito civil*: introdução ao direito civil constitucional, p. 140.

⁷⁸ COSTA JUNIOR, Olimpio *A relação jurídica obrigacional*, p. 26.

lienáveis e irrenunciáveis, como preceitua o art. 27 da LDA. Verifica-se, assim, uma limitação à autonomia privada do autor que se vê privado do pleno exercício de seu direito.

Tal privação decorre, contudo, da observância do princípio da tutela do hipossuficiente. Com a finalidade de proteger o autor evitando que ele ceda às pressões de mercado, a Lei lhe restringe a liberdade. No mesmo sentido, é considerado impenhorável⁷⁹.

É importante frisar que a indisponibilidade do direito não impõe ao autor o dever de usá-lo, cabendo-lhe a opção de se abster de seu exercício ou de sua defesa. Em linhas gerais, seria igualmente legítima cláusula contratual nesse sentido⁸⁰.

2.9.4 INTRANSMISSIBILIDADE

A intransmissibilidade não é característica que atinge todos os direitos morais na legislação brasileira. Segundo o § 1º do art. 24 da LDA, transmitem-se aos sucessores do autor o direito à autoria, o direito ao nome, o direito ao inédito e o direito à integridade da obra. Os demais são intransmissíveis.

Há, contudo, que questionar o texto legal, pois, nesse caso, não há a transmissão do Direito Autoral, mas apenas a transmissão da legitimidade para o seu exercício ou defesa. Em outras palavras, transfere-se para os herdeiros a defesa dos direitos do autor. Caso contrário a Lei estaria atribuindo Direito Autoral por herança a quem não é autor.

Nesse mesmo sentido, Lipszyc⁸¹ defende que o direito moral de autor é inerente à qualidade de autor. Da mesma

forma se posiciona Ascensão⁸² ao afirmar que o direito que o herdeiro invoca não é próprio, mas do criador intelectual da obra. Foi esse o posicionamento adotado pela Lei italiana de direitos autorais em seu art. 23⁸³. Segundo Perlingieri⁸⁴, por tratar-se de um interesse não-patrimonial a palavra transmissão é usada impropriamente.

Trata-se, na verdade, de legitimação processual extraordinária. Conforme Debois⁸⁵, após a morte do autor o direito moral permanece a serviço do autor falecido e não de seus herdeiros.

2.9.5 IMPRESCRITIBILIDADE

São imprescritíveis porque o não exercício das faculdades morais não gera sua perda pelo autor nem sua aquisição por terceiros.

É importante distinguir a imprescritibilidade do direito moral de autor da prescritibilidade de sua pretensão⁸⁶. Segundo Ieciona Emery⁸⁷, o autor nunca perderá o direito de exigir de seu editor o respeito ao texto original apresentado, contudo, a pretensão à reparação por perdas e danos pela alteração não autorizada do texto original prescreve no prazo

⁸² ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 277

⁸³ Art. 23 "Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti"

⁸⁴ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 181

⁸⁵ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 645

⁸⁶ Art. 189 Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 (Código Civil brasileiro)

⁸⁷ EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*, p. 81.

⁷⁹ AMARAL, Francisco. *Direito civil* 5 ed Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 252

⁸⁰ Em contratos de adesão, por outro lado, a cláusula seria nula, a teor do art. 424 do Código Civil

⁸¹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 157.

fixado em Lei. Como a LDA não prevê prazo prescricional para a pretensão do autor, prescreve em 3 (três) anos, como disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

2.9.6 PREEMINÊNCIA

Os direitos morais do autor são preeminentes, porque prevalecem se em conflito com as demais espécies de direito subjetivo, conforme previsto expressamente na Lei de Direitos Autorais para os casos dos direitos de acesso, de retirada e do direito de modificação da obra. O legítimo possuidor da obra não pode se opor ao exercício do direito moral do autor, cabendo-lhe apenas pleitear prévia indenização⁸⁸.

Segundo Amaral⁸⁹, os direitos da personalidade têm uma tutela “mais reforçada” que os demais.

A preeminência dos direitos morais do autor é bem ilustrada em caso célebre ocorrido em 1865 e denominado “Retrato de dama”, em que o tribunal francês reconheceu como legítima a recusa de um pintor em entregar o quadro encomendado e pago, decidindo que o direito de crédito do encomendante subjugava-se ao direito da personalidade do pintor (direito ao inédito)⁹⁰.

⁸⁸ Art. 24, § 3º, da LDA.

⁸⁹ AMARAL, Francisco. *Direito civil*, p. 251.

⁹⁰ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*, p. 2.

CAPÍTULO III

DIREITOS PATRIMONIAIS

3.1 DIREITOS PATRIMONIAIS

Diferentemente do que ocorreu com o direito moral de autor que só obteve reconhecimento formal em meados do século XIX, o reconhecimento do direito patrimonial é anterior, remontando ao Direito Romano, ainda que de forma indireta e embrionária. Segundo Dock¹, nas Instituições de Justiniano já se podia identificar proteção patrimonial para a obra literária.

Vê-se assim, que, paradoxalmente², apesar de o direito moral de autor possuir hoje uma proteção mais ampla que o direito patrimonial, as repercussões econômicas da criação alcançaram amparo jurídico muito antes de seus aspectos pessoais.

Os direitos patrimoniais de autor são assegurados no art. 5º, inciso XXVII, da Constituição da República que garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras.

¹ DOCK, Marie Claude. *Étude sur le droit d'auteur*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1963, p. 10-16.

² O direito patrimonial é considerado por muitos como mutação econômica do direito moral (SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 27).

No mesmo sentido o art. 28 da LDA prevê que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária artística e científica.

Trata-se de conceituação demasiado vaga tendo-se em vista que a exclusividade concedida ao autor restringe-se à sua exploração econômica, uma vez que um direito exclusivo ilimitado de uso possibilitaria ao autor uma ingerência contestável na vida privada alheia.

Segundo Manso³, a utilização a que se refere a Lei restringe-se ao aspecto patrimonial, e estendê-la à utilização intelectual contrariaria o propósito de incentivar a cultura que é a razão de atribuição do Direito Autoral.

Nesse sentido, foi mais precisa a definição trazida na legislação italiana que atribui ao autor o direito exclusivo de utilizar economicamente a obra⁴.

No mesmo sentido, Ascensão⁵ o define como o direito exclusivo de exploração econômica da obra, e Lipszyc⁶ como a garantia de obtenção pelo autor de um benefício econômico decorrente de sua utilização. É esse também o entendimento da Corte Suprema Argentina⁷.

A restrição se justifica porque, como leciona Savatier⁸, a finalidade do direito patrimonial de autor é propiciar ao autor um meio de vida, um sustento.

No aspecto patrimonial, referem-se às faculdades reconhecidas ao autor tanto no singular como no plural.

A expressão singular, direito patrimonial de autor, refere-se ao direito exclusivo de exploração econômica da obra,

englobando-se aí todas as modalidades de utilização, tais como reprodução, tradução, publicação, etc.

No plural, a expressão refere-se à decomposição do direito de exploração econômica em tantos direitos quantos sejam as modalidades de utilização da obra, tendo-se assim, o direito patrimonial de reprodução, de tradução, de publicação, etc.

Inicialmente, vê-se a proteção do aspecto patrimonial da criação por essa concepção pluralista. Como ressalta Debois⁹, no Direito francês a proteção foi gradual, inicialmente se protegeu o direito de representação (1791), seguido do direito de reprodução (1793). Colombet¹⁰ acrescenta à lista o direito de sequência¹¹.

É lógico que a restrita proteção inicial não é mais suficiente à garantia do exclusivo do autor, tendo-se em vista a grande variedade de modalidades de utilização da criação que se pode empreender nos dias atuais, principalmente após a revolução digital experimentada pela sociedade contemporânea.

Nesse sentido, o art. 29 da LDA prevê uma série de modalidades de utilização protegidas pelo exclusivo autoral, tais como:

- reprodução parcial ou integral;
- edição;
- adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações;
- tradução para qualquer idioma;
- inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra óptica, satélite, ondas

⁹ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 307.

¹⁰ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 250.

¹¹ O direito de sequência será objeto de análise detalhada no item 3.2.1.3.1.

³ MANSO, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*. São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 32.

⁴ Art. 12 da Lei n. 633 de 22 de abril de 1941.

⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 164.

⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 50.

⁷ EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*, p. 62.

⁸ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 25.

ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção mediante interatividade ou pagamento pelo usuário;

- representação, recitação ou declamação;
- execução musical;
- emprego de alto-falante ou sistemas análogos;
- radiodifusão sonora ou televisiva;
- captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
- sonorização ambiental;
- exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
- emprego de satélites artificiais;
- emprego de sistemas ópticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
- exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
- inclusão em bases de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero.

Apesar de extensa a enumeração legal das modalidades de utilização ela não poderia ser restritiva, sob pena de se tornar brevemente obsoleta, tendo em vista a atual velocidade do desenvolvimento tecnológico. Assim, o legislador, no inciso X do art. 29, deixa claro o caráter meramente exemplificativo da enumeração legal, considerando englobadas pelo exclusivo autoral quaisquer outras modalidades de utilização, de existência atual ou futura.

Nesse mesmo sentido repousa o entendimento de Lipszyc¹², que defende a idéia de que os direitos patrimoniais de autor

¹² LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 175.

não estão sujeitos a *numerus clausus*, sendo tantos quantas sejam as formas de utilização factíveis da obra, tanto no momento de sua criação como durante todo o tempo em que ela permanecer no domínio privado. *W. O. U. C.*

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DE AUTOR

3.2.1 TRANSMISSIBILIDADE

Diferentemente dos direitos morais, os direitos patrimoniais são transmissíveis por atos *inter vivos* ou *causa mortis*. Isso se dá porque, como já dito anteriormente, o objetivo do direito patrimonial de autor é garantir-lhe o exclusivo de exploração econômica da obra, o que não significa que ele deva ou mesmo que possa fazê-lo pessoalmente.

Assim, os direitos patrimoniais atribuem a seu titular uma faculdade de disposição, em sentido objetivo.

A faculdade de disposição pode ser vista sob dois aspectos: um subjetivo e outro objetivo. Subjetivamente se confunde com a capacidade jurídica de seu titular e objetivamente como uma característica intrínseca ao próprio direito¹³.

Na transmissão *causa mortis* será obedecida a ordem sucessória da Lei Civil¹⁴. Garante-se, assim, uma dilação do domínio privado sobre a criação para os herdeiros do autor. Caso o autor faleça sem deixar sucessores, a obra cairá, automaticamente, em domínio público¹⁵.

A transmissibilidade por ato *inter vivos* depende de autorização do autor e via de regra se faz mediante licença de uso ou cessão de direitos.

¹³ PUGLIATTI, Salvatore. *Diritto civile – saggi*. Milão: Giuffrè, 1951. p. 7.

¹⁴ Art. 41 e seguintes da LDA.

¹⁵ Art. 45, inciso I, da LDA.

O negócio jurídico autoral, além de se submeter aos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral,¹⁶ deve observar alguns requisitos específicos previstos na LDA.

3.2.1.1 Expressa manifestação de vontade e forma escrita

Segundo Pugliati¹⁷, os atos de disposição de direitos são constituídos por dois elementos: a faculdade de disposição e a manifestação de vontade.

A manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos, em regra, pode ser expressa, tácita ou presumida.

Será expressa se for feita por meio de palavras, da escrita ou de mímica. Tácita quando for deduzida do comportamento inequívoco do agente e presumida quando a Lei assim estabelecer.

O art. 29 da LDA exige a manifestação expressa de vontade para a validade do negócio jurídico autoral. Isso significa que a vontade do autor, como regra, pode ser declarada verbalmente, mimicamente ou por escrito, seja em um instrumento formal, seja por meios informais como cartas impressas ou eletrônicas (*e-mails*), mas jamais poderá ser deduzida ou presumida.

A regra do art. 29 da LDA aplica-se, todavia, exclusivamente aos negócios jurídicos que tenham por objeto apenas a licença de uso da obra. É importante ressaltar que a propriedade imaterial, assim como a propriedade material, possui em seu conteúdo várias faculdades que podem ser transferidas em conjunto ou separadamente¹⁸.

¹⁶ Art. 166 do Código Civil.

¹⁷ PUGLIATTI, Salvatore. *Diritto civile – saggi*, p. 7.

¹⁸ BEVILÁQUA, Clóvis. *Direito das coisas*. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 115.

Para Enneccerus¹⁹, essas faculdades diferem da propriedade por seu conteúdo. Aquelas permitem apenas um domínio parcial sobre o bem (determinado) enquanto que esta corresponde ao domínio máximo possível (indeterminado).

Utilizando a divisão clássica dos direitos do dono²⁰: em usar, fruir, dispor e reivindicar, nas licenças de uso o negócio jurídico incide apenas sobre o primeiro elemento.

É importante frisar, ainda, que a licença de uso não limita o Direito Autoral, uma vez que não confere direito real de uso (*ius in re*), mas simplesmente direito pessoal de uso (*ius in rem*).

Assim, nesses casos, o autor permite a terceiros a utilização da obra sem transferir-lhes a titularidade sobre ela.²¹ Nesse sentido, o julgamento da Apelação Cível n. 352.565-5 realizado em 28 de fevereiro de 2002 pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais que reconheceu que a propriedade intelectual de programa de computador não se exaure pela transferência da cópia.

Direito de uso é o direito de servir-se do bem. É lógico que, apesar de distintas as noções de usar e fruir, tem-se que o uso, mesmo limitado por seus fins econômicos e sociais, não exclui em absoluto a fruição do bem. Segundo Pontes de Miranda²², a noção de uso engloba certos frutos, uma vez que o usuário pode, em regra, usar o bem como poderia fazê-lo o proprietário.

Por outro lado, nos casos de cessão de direitos referidos na LDA, o negócio jurídico pode incidir sobre todos, alguns ou um dos elementos do domínio (usar,²³ fruir, dispor e reivin-

¹⁹ ENNECCERUS, Ludwig. *Tratado de derecho civil*. Barcelona: Bosch, 1944, v. I, t. III, p. 298.

²⁰ Os direitos autorais reputam-se bens móveis para efeitos legais.

²¹ Art. 37 da LDA.

²² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, t. XIX, p. 349.

²³ Nesses casos o direito de uso é direito real limitado.

dicar), transferindo-os a terceiros.²⁴ Dessa forma, se a transferência se der em caráter definitivo a exigência legal é de que o ato se revista da forma escrita, particular ou pública.²⁵

Essa exigência aplica-se tanto aos casos em que forem cedidos todos os direitos patrimoniais quanto aos casos em que apenas um ou alguns desses direitos forem cedidos, a teor do art. 50 da LDA.

Caso a obra tenha sido levada a registro pelo autor ou titular originário, a cessão poderá ser averbada à margem do registro respectivo ou, caso contrário, poderá ser registrada no Cartório de Títulos e Documentos.

O art. 50, § 2º, da LDA exige que conste do instrumento de cessão os seguintes elementos essenciais:

- objeto;
- prazo;
- local de exercício;
- preço.

A inobservância dessa exigência não gera, contudo, a invalidação do ato. No caso de não haver estipulação quanto ao prazo contratual, a Lei o fixa em cinco anos. No caso de não haver previsão de preço, o contrato será presumidamente oneroso aplicando-se a remuneração de mercado.²⁶ Por fim, não havendo previsão quanto ao objeto do contrato ou quanto ao local de exercício, o contrato será interpretado restritivamente.

²⁴ Há alguns países, a exemplo da Espanha, que não admitem que a transmissão do direito patrimonial importe em perda do mesmo pelo autor, gerando uma espécie de co-propriedade ou condomínio (LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 276). Há, ainda, os que sustentam sua inalienabilidade, a exemplo da Alemanha (PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 304).

²⁵ Art. 49, inciso I, da LDA.

²⁶ Art. 57 da LDA.

3.2.1.2 Interpretação restritiva

Segundo Amaral²⁷, interpretar o negócio jurídico é a busca pelo conteúdo das normas jurídicas que nascem da declaração de vontade.

O negócio jurídico é ato de regulamentação de condutas. Os participantes estabelecem normas que deverão seguir. O instrumento de que se utilizam para estabelecer o conteúdo dessas normas é a sua declaração de vontade.

A identificação do conteúdo da declaração de vontade depende de fatores lingüístico-semiológicos, sociais, históricos e pessoais, o que faz da atividade de interpretação questão importante na busca pela segurança negocial, principalmente nos casos em que há desentendimento das partes quanto ao seu conteúdo.

É importante frisar que o que se busca não é a vontade individual (subjéctiva/interna) das partes, mas a vontade negocial (objetiva/externa), que seria a fusão das vontades individuais das partes, que se encontrando, perdem cada uma a sua autonomia própria²⁸.

Apesar de a atividade de interpretação ser uma espécie de intervenção externa sobre o negócio jurídico, é importante frisar que o intérprete deve buscar a vontade das partes e não tentar impor a sua própria, tampouco sobrepor algum interesse externo ao interesse negocial²⁹. A finalidade da interpretação não é modificar o negócio jurídico, mas defini-lo.

Daí a importância de regras que conduzam a atuação do intérprete. Segundo Lisboa³⁰, as regras de interpretação con-

²⁷ AMARAL, Francisco. *Direito civil*, p. 418.

²⁸ RUGGIERO, Roberto de. *Instituições de direito civil*. Campinas: Book-seller, 1999, v. 3, p. 305.

²⁹ ROPPO, Enzo. *O contrato*. Coimbra: Almedina, 1988, p. 169-174.

³⁰ LISBOA, Roberto Senise. *Manual de direito civil* 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, v. III, p. 200-202.

tratual dividem-se em objetivas e subjetivas. As regras subjetivas ocupam-se da investigação da vontade das partes e as regras objetivas buscam esclarecer o seu sentido; as primeiras baseiam-se na teoria da responsabilidade (boa-fé subjetiva) e as demais na teoria da confiança (boa-fé objetiva).

Dentre as regras legais que buscam nortear tal interpretação tem-se a regra da prevalência da vontade real sobre a declarada, a interpretação restritiva dos contratos gratuitos, a interpretação contratual em favor do aderente, a regra de lealdade, a conservação do negócio jurídico, etc.

Há também importantes regras doutrinárias consolidadas³¹:

- os costumes locais estão subentendidos nos contratos;
- a interpretação deve ser segundo a natureza e o objeto do contrato;
- a interpretação deve ser menos onerosa para o devedor (*in dubio, pro debitore*);

Além dessas regras, aplicam-se aos negócios jurídicos autorais, gratuitos ou onerosos, a regra da interpretação restritiva³².

A atividade de interpretação, de acordo com a extensão de seus efeitos, pode ser classificada em declarativa, extensiva ou restritiva.

Na primeira, o intérprete afirma a coincidência entre a linguagem e seu sentido; na segunda, o intérprete amplia o sentido da linguagem; e na última, o diminui, constatando que a linguagem estaria mais ampla do que a vontade real das partes³³.

Assim, os negócios jurídicos autorais não se estendem de pessoa a pessoa, de coisa a coisa, nem de tempo a tempo. Não havendo especificações, o negócio estará limitado ao país e à língua em que foi firmado, às modalidades de utilização existentes à data de sua celebração e às que forem indispensáveis ao cumprimento de sua finalidade.

Um bom exemplo é o caso do *software* livre, que é muitas vezes confundido com *software* gratuito, mas não precisa necessariamente sê-lo. *Software* livre é aquele cujo código fonte é aberto, disponível ao público, de forma irrevogável, tanto em sua versão original como nas ulteriores. Para o cumprimento de sua finalidade, no silêncio da licença de uso, a interpretação restritiva deve garantir ao usuários, no mínimo, as seguintes formas de utilização:

- liberdade de execução do programa;
- liberdade de distribuição de cópias das derivações;
- liberdade de transformação, adaptação ou aperfeiçoamento do programa;
- liberdade de acesso ao código fonte das derivações realizadas³⁴.

Tratando-se de obra de artes plásticas, a alienação do objeto em que ela se materializa transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la.

Tratando-se de edição, entende-se que o contrato versa sobre uma edição, que se constitui de três mil exemplares, se não houver cláusula expressa em contrário. Por fim, a autorização concedida pelo autor para uma modalidade de utilização da obra não se estende a qualquer das demais.

³⁴ É neste ponto que o *software* livre ou aberto se distingue do domínio público. Um programa de computador em domínio público pode ser aperfeiçoado e comercializado posteriormente na forma fechada ou proprietária (sem acesso a seu código fonte). No caso do *software* livre a licença de uso dada originariamente é dotada de pós-eficácia diferida

³¹ FIUZA, César. *Direito civil: curso completo*, p. 410-411

³² Art. 4º da LDA.

³³ NADER, Paulo. *Curso de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 417

É lógico, contudo, que a regra da interpretação restritiva não tem aplicabilidade absoluta, devendo amoldar-se à regra de boa-fé³⁵, bem como à funcionalidade do Direito Autoral.

3.2.1.3 Presunção de onerosidade

Quanto à reciprocidade de prestações, os negócios jurídicos dividem-se em gratuitos e onerosos. O critério distintivo, nesse caso, é a correspondência entre prestação e contraprestação, ou seja, se ambas as partes suportam o ônus correspondente à vantagem que obtêm. A cessão de direitos patrimoniais de autor pode ser gratuita ou onerosa. Será onerosa se o autor receber remuneração pela cessão dos direitos; e será gratuita se o fizer por ato de liberalidade. A gratuidade da cessão depende de convenção nesse sentido. Caso contrário, será presumidamente onerosa.

A cobrança da remuneração do autor, habitualmente denominada de *royalties*³⁶, pode ser a preço fixo ou variável, proporcional ao número de exemplares vendidos, podendo ser feita pessoalmente pelo próprio autor, por seus herdeiros, nos casos previstos em lei, ou por seus representantes, legais ou convencionais.

Segundo o art. 98 da LDA, as associações de gestão coletiva de direitos autorais e conexos são mandatárias de seus associados para a defesa de seus direitos e para a cobrança dos *royalties*. Isso não significa que o titular não possa fazê-lo pessoalmente. Para tanto, basta comunicá-lo previamente à associação a que estiver filiado³⁷.

³⁵ GAGLIANO, Pablo Stolze. *Novo curso de direito civil* 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. I, p. 325.

³⁶ Frise-se que os *royalties* não são direitos autorais, mas direitos creditícios decorrentes do exercício do Direito Autoral aplicando-se-lhes a disciplina dos direitos de crédito em geral. Para ver mais: ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 539.

³⁷ Trata-se, assim, de legitimidade extraordinária concorrente.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 101812/SP, realizado em 16 de setembro de 2004, julgou inconstitucional a Resolução n. 136/87 do Conselho Nacional de Cinema (CONCINE), considerando-o parte ilegítima para tomar as providências legais contra os infratores de direitos autorais³⁸.

Por exigência legal, as associações mantêm um escritório central (ECAD) para a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas e da exibição de obras cinematográficas e audiovisuais que as incluam. Incluem-se aí a transmissão cinematográfica, radiofônica e televisiva, inclusive via cabo, e a retransmissão radiofônica cinematográfica e televisiva feitas por estabelecimentos comerciais como hotéis, motéis, bares, restaurantes, academias, etc.³⁹

A cobrança de direitos autorais é indevida, porém, se é o próprio autor que faz o *show*, conforme entendimento da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que em julgamento da Apelação Cível 364.599-2, realizado em 5 de setembro de 2002, considerou ilegítima a pretensão do ECAD de recolher direitos autorais do titular do estabelecimento em que se deu evento musical realizado pelo cantor e compositor Jorge Benjor, exclusivamente com músicas suas. É também indevida se houver renúncia do autor da obra musical ao recebimento do que lhe é devido, como ficou decidido pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 211621/RS, realizado em 17 de junho de 1999.

A arrecadação pelo ECAD é arbitrada com base nos seguintes critérios⁴⁰:

³⁸ Sobre CONCINE ver Decreto 93 881/1986.

³⁹ Ver Súmula 63 do STJ e Apelações Cíveis 327.469-9, 371 780-4 e 380.172-1 do TA/MG.

⁴⁰ ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. *Crêterios de arrecadação*. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <<http://www.ecad.org.br>>. Acesso em: 23 ago 2005.

- grau de importância da obra (primária ou secundária);
- atividade exercida pelo usuário⁴¹;
- periodicidade (permanente ou eventual)⁴²;
- forma de apresentação da obra (mecânica ou ao vivo)⁴³;
- obras utilizadas⁴⁴.

A cobrança poderá ser feita de duas formas, mediante percentual da receita bruta ou por parâmetro físico. Nesse caso, aplica-se unidade de valor criada pelo ECAD, a UDA.

Em linhas gerais a distribuição da arrecadação feita pelo ECAD é feita da seguinte forma: 18% do valor arrecadado é retido pelo ECAD, 7% é distribuído para as associações que o compõem e 75% dos valores são repassados para os titulares de direitos autorais (2/3) e conexos (1/3) filiados. Nesse último caso, a distribuição é feita com base no número de execuções da obra captadas (ponto autoral).

Não sendo autorizada a execução ou sendo realizada sem o pagamento dos *royalties*, os responsáveis estarão sujeitos ao pagamento de multa no valor de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago.

⁴¹ No caso de eventos beneficentes o valor da arrecadação será reduzido em até 25%.

⁴² No caso de usuário permanente, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 238226/RS, realizado em 20 de abril de 2004, considerou a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a obrigação de solver as mensuralidades caso não comprovasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito Autoral.

⁴³ Se a execução das obras for exclusivamente ao vivo haverá redução de 1/3 do valor da arrecadação, pois não haverá arrecadação de direitos conexos.

⁴⁴ Se houver execução de obras protegidas e obras não protegidas, o cálculo da arrecadação observará apenas aquelas.

3.2.1.3.1 Direito de seqüência

No caso de alienação do original de obra de arte ou manuscrito, além dos *royalties* contratados, cabe ao autor o direito de perceber no mínimo 5% sobre o aumento do preço verificável em cada revenda da obra. A valorização da obra é verificada pela diferença entre o preço da última venda e daquela imediatamente precedente.

Caso o autor ou titular não receba seu direito de seqüência no ato da revenda o vendedor ou leiloeiro, se for o caso, será considerado depositário da quantia àquele devida.

O direito de seqüência, diversamente dos demais direitos patrimoniais de autor, é inalienável e irrenunciável, sendo, por essa razão, considerado por alguns autores como um direito híbrido⁴⁵.

O direito de seqüência foi criado pelo Direito francês em 1920 com a finalidade, segundo Colombet⁴⁶, de reparar uma injustiça: os autores iniciantes e sem notoriedade normalmente vendiam suas obras a baixos preços, e a valorização da obra decorrente do reconhecimento de seu trabalho era auferida pelos comerciantes de artes. Assim, pareceu razoável que o autor também recebesse uma parte, ainda que modesta, dessas valorizações posteriores. Trata-se de um direito de participação geral que visa proteger o autor das especulações de mercado.

Na LDA adotou-se a idéia de percentual legal único. Na legislação italiana o percentual legal é variável. De início, só será devido o direito de seqüência se houver uma valorização significativa da obra, casos em que o percentual devido ao autor variará de 1% a 10%, dependendo da valorização alcançada pela obra⁴⁷.

⁴⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 236.

⁴⁶ COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*, p. 174.

⁴⁷ Art. 144 e seguintes da Lei italiana.

Os rendimentos decorrentes da exploração econômica da obra percebidos pelo autor na constância do casamento comunicam-se, independente do regime de bens⁴⁸, a teor da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF)⁴⁹. Comunicam-se também se percebidos na constância de união estável⁵⁰.

3.2.2 TEMPORARIEDADE E DOMÍNIO PÚBLICO

Não há uniformidade na legislação internacional para o prazo de proteção autoral, variando de vinte e cinco a noventa e nove anos. A maioria dos países adotou o prazo geral de cinquenta anos. No entanto, verifica-se haver uma tendência à ampliação da duração da tutela.

No Direito brasileiro essa tendência já se mostrava presente quando da edição da Lei 3.126 de 18 de abril de 1957, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek, que dilatou por um decênio o prazo para fruição dos direitos autorais das obras do Maestro Antônio Carlos Gomes, por seus herdeiros. Posteriormente, a Lei 5.558, de 11 de dezembro de 1968, sancionada pelo Presidente Costa e Silva, dilatou-o por mais cinco anos.

Dessa forma, a Comunidade Européia adotou diretiva de harmonização da proteção autoral nos países-membros pelo prazo de setenta anos⁵¹. Prazo também escolhido pelo legislador brasileiro na LDA.

Nesse ponto, verifica-se que muitas vezes o direito se mostra como um remédio inócuo e tardio. A sociedade da informação não requer mais prazos de proteção tão exten-

sos, visto que a velocidade da informação já permite que um autor se faça conhecer e ser reconhecido em tempo hábil a usufruir dos frutos da autoria. Mas, paradoxalmente, os prazos de proteção têm-se tornado cada vez mais extensos. Tem-se hoje o direito de ontem.

Via de regra, em nosso ordenamento, os direitos patrimoniais perduram por setenta anos contados do 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

O mesmo prazo aplica-se às obras póstumas, anônimas, pseudônimas, audiovisuais, fotográficas e obras criadas em co-autoria, sendo que, neste último caso, o prazo contar-se-á a partir da morte do último dos co-autores sobreviventes. Nas obras anônimas e pseudônimas a contagem do prazo inicia-se no 1º de janeiro do ano imediatamente posterior à sua publicação⁵². Nas obras audiovisuais e fotográficas o prazo contar-se-á a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.

Quanto aos programas de computador, o prazo de proteção é de cinquenta anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente a sua publicação, ou, na ausência dessa, da sua criação⁵³.

Enquanto perdura o prazo de proteção a obra está sob domínio privado. Expirado o prazo de proteção a obra cai em domínio público.

A finalidade de se limitar o prazo de proteção autoral está na necessidade de se permitir à sociedade a fruição gratuita das obras como forma de preservação e fomento cultural. A proteção autoral mostra-se, assim, como uma privação forçada e, portanto, essencialmente temporária. Essa temporariedade funcionaria como a válvula de segurança da

⁴⁸ MADALENO, Rolf. Do regime de bens entre os cônjuges. In: DIAS, Maria Berenice. *Direito de família e o novo código civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 223.

⁴⁹ Ver também art. 1.660, inciso V, e art. 1.669 do Código Civil Art. 1.725 do Código Civil.

⁵⁰ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 269.

⁵² Desde que assim permaneçam até a morte do autor. Caso contrário contar-se-á o prazo a partir de seu falecimento.

⁵³ Art. 2º, § 2º, da LDS

sociedade⁵⁴. Segundo Patterson⁵⁵, o monopólio autoral não encontra sua origem no costume, mas na censura.

Segundo Lipszyc⁵⁶, os principais argumentos em favor da limitação são:

- ao criar o autor se alimenta do patrimônio cultural coletivo, razão pela qual a obra deve, em algum momento, retornar a este patrimônio comum;
- depois de certo tempo fica praticamente impossível encontrar todos os herdeiros e mesmo obter um consenso entre suas vontades;
- a perpetuidade custa caro à coletividade, dificultando a circulação e o acesso às obras.

2 O domínio público pode ser originário ou derivado. Será originário quando a proteção sequer chegar a ser concedida. É o caso das obras ilícitas, das obras não alcançadas e das obras de autor desconhecido. Será derivado quando decorrer o prazo de proteção ou quando o autor falecer, se não deixar herdeiros.

Em relação às obras de autor desconhecido é importante fazer-se a ressalva relativa às obras folclóricas. O art. 48 da legislação autoral que precedeu a LDA previa expressamente que integravam ao domínio público as obras de autor desconhecido transmitidas pela via oral, onde soia incluir as obras folclóricas.

Realmente as obras folclóricas escapam da tutela autoral, pois com o passar do tempo, mesmo que tenham sido inicialmente criadas por um indivíduo, perdem essa individualidade e se transformam em expressão cultural coletiva.

⁵⁴ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 267.

⁵⁵ *Apud* PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 441.

⁵⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 250.

Nada impede, por outro lado, a concessão da tutela autoral às obras derivadas de obras folclóricas ou à proteção dos direitos conexos dos artistas, intérpretes e executantes. Acrescentada, também, a posição de nosso legislador na LDA no art. 45, inciso II, que substituiu o referido art. 48 que adotou a posição de considerá-las como domínio público, ressaltando a possibilidade de proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais à margem da tutela autoral.

A concretização de uma efetiva tutela legal desses conhecimentos seria uma importante medida de prevenção e repressão à pirataria cultural internacional que espolia países sul-americanos, africanos e asiáticos. É comum o registro, principalmente nos países do sistema de *copyright* da produção cultural de tribos indígenas ou grupos aborígenes sem lhes reservar qualquer espécie de remuneração⁵⁷.

A idéia de domínio público a que se refere a LDA, em seu art. 45, não é a de que a obra se tornaria um bem público. Em outras palavras, com a entrada em domínio público, a obra não passa a pertencer ao Estado, não significando que ele também não seja beneficiado com a queda do monopólio.

Segundo Savatier⁵⁸, com o domínio público a obra passa a pertencer à civilização humana, com ela se põe em comunhão.

Apesar de poética a idéia, ela faz confundir as noções de domínio público e patrimônio intelectual comum.

O patrimônio intelectual comum seria o conjunto cultural da humanidade formado por meio dos séculos e constituído pelas várias idéias, impressões, intuições e demais contribuições intelectuais dadas pelos indivíduos em todos os campos das artes e das ciências. É comum a todos e qualquer um pode livremente usá-lo⁵⁹.

⁵⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 54.

⁵⁸ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 28.

⁵⁹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 604.

Domínio público, por outro lado, é a ausência ou a perda da exclusividade de exploração econômica da obra. A partir de então qualquer um poderá fazê-lo, até mesmo os herdeiros do autor podem continuar fazendo-o, só que sem exclusividade.

A natureza jurídica do domínio público gera algumas discussões acadêmicas. Para alguns, o domínio público seria a situação normal de uso das obras intelectuais, sendo o direito exclusivo de exploração econômica nada mais que uma restrição legal de uso. Para outros a exclusividade de exploração econômica seria a situação normal de uso e o domínio público seria uma restrição legal ao direito individual⁶⁰.

O domínio público pode ser gratuito ou oneroso. No gratuito, a utilização da obra é livre e gratuita, o que significa que não depende mais de autorização do autor, nem requer o pagamento de qualquer espécie de remuneração. No domínio público oneroso, a utilização da obra é livre, mas não é gratuita, isto é, apesar de não ser mais necessária a autorização do autor, é cobrada pelo Estado.

Há também o domínio público impróprio, em que a utilização da obra pressupõe autorização e pagamento da quantia cobrada pelo Estado, o que pode ser usado como pretexto para a censura ou para o dirigismo intelectual⁶¹, não tendo guarida em nosso ordenamento jurídico⁶². Esse sistema não pode sequer ser considerado como quebra do exclusivo autoral, mas tão-somente como transferência desse exclusivo do autor para o Estado.

É importante frisar, ainda, que o domínio público atinge os direitos patrimoniais e alguns dos direitos morais de

autor, mantendo incólumes os direitos morais à autoria e à integridade da obra⁶³.

Segundo Debois⁶⁴, o objetivo deste direito moral *post mortem* é assegurar a defesa do que se poderia chamar de interesses póstumos do autor.

Segundo Lipszyc⁶⁵, no direito comparado, há três tratamentos diferentes para os direitos morais de autor após a sua morte:

- o direito moral é perpétuo;
- o direito moral tem a mesma duração do direito patrimonial;
- os direitos morais se extinguem com a morte do autor.

A LDA adotou parcialmente as três concepções. Os direitos morais de acesso, de retirada e de modificação da obra se extinguem com a morte do autor, o direito ao inédito tem a mesma duração do direito patrimonial⁶⁶ e os direitos à autoria e à integridade são perpétuos.

É importante lembrar que no exercício do direito de assegurar a integridade da obra só se justifica a oposição às modificações da obra que possam prejudicá-la ou atingir o autor em sua reputação ou honra. Assim, ressalvadas essas situações, estando a obra em domínio público, ela poderá ser livremente utilizada, o que engloba a possibilidade de modificação, adaptação ou complementação. Nesses casos, apesar de a obra originária estar em domínio público, as obras derivadas receberão a proteção autoral pelo prazo legal, sendo consideradas criadas no momento em que se der a

⁶⁰ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 265.

⁶¹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 266.

⁶² Art. 5º, inciso IX, da CF/88.

⁶³ Art. 24, § 2º, da LDA.

⁶⁴ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 650.

⁶⁵ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 260.

⁶⁶ Hermenêutica do § 1º e do § 2º do art. 24 da LDA.

derivação. O titular de direitos sobre a adaptação, tradução, arranjo ou orquestração não poderá, porém, opor-se a outra adaptação, tradução, arranjo ou orquestração, salvo se for cópia da sua.⁶⁷

3.2.3 ECONOMICIDADE

O direito patrimonial do autor é a projeção econômica da criação, isto é, a exclusividade do autor de explorar economicamente sua obra⁶⁸.

Portanto, a violação do direito patrimonial do autor e, conseqüentemente, a utilização indevida da obra intelectual implicam, necessariamente, ameaça à exclusividade do autor de obter as vantagens patrimoniais decorrentes da utilização da obra.

São, portanto, proibidas as formas de utilização que visem lucro direto ou indireto. A finalidade é impedir que haja concorrência ao autor na exploração econômica da obra⁶⁹.

Se não há prejuízo patrimonial, não há violação. Segundo leciona Ascensão⁷⁰, são livres as atividades que não incidem negativamente na exploração econômica da obra. O ato que não prejudica a exploração econômica é um ato livre.

Poder-se-ia, assim, conceituar o uso privado como a forma de utilização da obra por uma pessoa, jurídica ou natural, que não prejudique sua exploração econômica exclusiva pelo titular.

A questão é controversa quando se trata de utilização pública da obra. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 471110/DF, realizado em 20 de março de 2003, considerou legítima a cobrança de direitos autorais em evento

⁶⁷ Art. 14 da LDA

⁶⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 160

⁶⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 163

⁷⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 161.

público, mesmo que gratuito, por caracterizar lucro indireto, enquanto que a Quarta Turma, no julgamento do REsp 178313/DF, realizado em 5 de dezembro de 2002, considerou indevida a cobrança em caso semelhante.

A controvérsia tem guarida apenas nos casos em que a execução pública se der por artistas remunerados. Segundo a Súmula 386 do STF não são exigíveis direitos autorais em execução pública feita por amadores.

Por outro lado, a utilização privada é, em princípio, livre, estando sua esfera fora do círculo reservado ao autor⁷¹.

O instituto do uso privado, porém, como visto anteriormente, é limitado no Brasil tanto pela Lei Autoral quanto pela Lei do *Software*.

A LDA permite a reprodução privada apenas em caráter parcial⁷², enquanto que a LDS permite a reprodução privada integral do programa, mas apenas em um único exemplar⁷³.

A limitação legal, por outro lado, restringe apenas a faculdade do usuário de reproduzir a obra. A sua utilização privada, desde que não importe realização de cópias, é livre⁷⁴. Segundo Lipszyc⁷⁵, o uso privado não se restringe apenas aos atos de reprodução, podendo compreender também atos de transformação da obra, como a tradução e a adaptação.

Por outro lado, há que questionar se o uso privado poderia ser restringido pelo contrato de licença de uso. A existência de cláusula contratual que importe a abstenção, por parte do usuário, de determinada ou determinadas modalidades de uso privado não cria Direito Autoral.

⁷¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 161

⁷² Art. 46, inciso II, da LDA.

⁷³ Art. 6º, inciso I, da LDS.

⁷⁴ Essa diferenciação já foi objeto de exemplificação em trabalho anterior: POLI, Leonardo Macedo. *Direitos de autor e software*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 71

⁷⁵ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 222.

Segundo leciona Ascensão, “o autor tem os direitos que a lei lhe concede: não pode forjar novos direitos por declaração unilateral”⁷⁶.

Nesse caso, instalar-se-ia uma relação jurídico-obrigacional. Mais precisamente uma obrigação negativa ou obrigação de não fazer. Conforme leciona Pereira⁷⁷, na obrigação de não fazer o devedor se obriga a não praticar determinado ato, ou melhor, a dele abster-se constante e sucessivamente. Em outras palavras, o devedor está obrigado a se abster da prática de determinado ato todas às vezes em que tiver a oportunidade de praticá-lo.

Nesses casos, se o usuário vier a praticar ato, do qual deveria ter-se omitido, estará inadimplente quanto à obrigação por ele assumida, que, por sua vez, para ser exigida, deverá preencher os requisitos de validade das obrigações em geral.

Por exemplo, a prática comum nos contratos de licença de uso de *software* (usualmente contratos de adesão) é a inclusão de cláusula que restringe o armazenamento do programa em um único computador. Isso leva à idéia de que se o usuário possui vários computadores deverá adquirir várias licenças de uso do mesmo programa, uma para cada computador.

Apesar de a questão ainda não ter sido tratada com a devida relevância, a abusividade da cláusula é patente. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual/MG, em 22 de setembro de 2005, expediram nota técnica conjunta (07/2005), considerando abusiva prática comercial análoga praticada pelas operadoras de TV a cabo, de cobrança por ponto adicional (livre ou escravo) instalado na residência do assinante.

Em 4 de maio de 2006, o Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, Jaubert Carneiro Jaques, em

⁷⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 201

⁷⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1993, v. II, p. 47

brilhante decisão proferida em Ação Civil Coletiva de Proteção ao Consumidor, Processo 024.06.061.487-2, considerou abusiva tal cláusula contratual justamente por limitar o uso privado dos consumidores, condenando as empresas de TV por assinatura a suspender a cobrança de pontos extras, a devolver os valores já pagos indevidamente pelos consumidores e a pagar multa diária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento da sentença.

3.2.3.1 O ilícito autoral

Concluindo, do acima exposto infere-se que as restrições legais e contratuais à utilização de obras intelectuais podem gerar duas modalidades diferentes de ato ilícito.

A primeira delas é o ato ilícito absoluto. Esse, na lição de Mello⁷⁸, é o definido pelo art. 186 do Código Civil⁷⁹, é, portanto, o ato que viola os direitos patrimoniais ou morais do autor.

Apesar de opiniões de peso sustentarem a tese da aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil à violação de direitos autorais, defendendo a aplicação das sanções legais em todas as situações em que o Direito Autoral for objetivamente violado, independentemente da aferição de dolo ou culpa do infrator⁸⁰, essa posição não parece ser a mais acertada.

Em nosso Direito, a teoria subjetiva da responsabilidade civil foi uma vez mais consagrada como cláusula geral de responsabilidade, a teor do que prescreve o art. 186 do Código Civil.

⁷⁸ MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico*. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 193

⁷⁹ “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (Código Civil)

⁸⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 537

A aplicação da teoria objetiva que se dá apenas em caráter excepcional, a teor do que preceitua o parágrafo único do art. 927 do Código Civil, se aplica apenas nos casos expressamente previstos em lei ou naqueles em que a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem.

Em outras palavras, a responsabilidade objetiva em nosso Direito ou decorre de lei (origem legal), ou decorre da natureza de risco da atividade desenvolvida pelo autor do dano (origem real).

Tendo-se em vista que da redação do art. 102 e seguintes da LDA não se pode colher elementos conclusivos suficientes para se afirmar, *a priori*, a aplicação da teoria objetiva ao ilícito autoral. A sua aplicação com base no risco da atividade desenvolvida pelo autor do dano só poderia ocorrer após a análise das circunstâncias do caso. Assim, a melhor hermenêutica parece ser a de se aplicar a cláusula geral subjetiva à responsabilidade civil por violação de direitos autorais, condicionando-se sua objetivação à análise casuística.

Nesse sentido, o art. 19 da Lei 496 de 1898, primeira Lei brasileira de Direitos Autorais, sancionada pelo então Presidente Prudente de Moraes, que considerava contração apenas a conduta dolosa ou fraudulenta (má-fé).

Assim, o ilícito autoral pressupõe não apenas a antijuridicidade da conduta como também culpabilidade (*lato sensu*), dano e nexo causal.

No mesmo sentido, o voto proferido pelo Relator e acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, em 6 de março de 2001 no julgamento da Apelação Cível n. 327.469-9, em que reconheceu ser do ECAD o ônus de comprovar contração a teor do art. 333 do Código de Processo Civil (CPC). Caso contrário estar-se-ia atribuindo fé pública aos fiscais de entes privados.

Na contramão, porém, o entendimento adotado pela Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 111105/PR, realizado em 21 de novembro de 2002, que considerou a legitimidade do ECAD para cobrar direitos autorais em nome de titulares das composições litero-musicais independente de prova de filiação e autorização respectivas. Inverteu-se, assim, o ônus da prova sem que haja o devido amparo legal, o que contraria o *due process of law*.

Retomando, tem-se que, via de regra, o ilícito absoluto pode ser caracterizado como contração de direitos autorais ou usurpação de obra alheia⁸¹.

A contração de direitos autorais é conceituada na LDA como a reprodução não autorizada de obra protegida⁸². A conceituação é, contudo, demasiadamente restritiva. O termo contração refere-se não somente à reprodução não autorizada, mas também a qualquer outra forma de utilização não autorizada da obra, nos termos do art. 29 da LDA. Assim, por contração entende-se a utilização não autorizada da obra por qualquer modalidade, incluindo-se aí o plágio⁸³.

A usurpação da obra consiste na sua divulgação sem indicação do nome do autor ou com falsa menção de autoria. Assim, trata-se de usurpação de obra tanto os casos em que se toma obra alheia para si ou para outrem (usurpação positiva) como os casos em que arbitrariamente se suprime a indicação de autoria (usurpação negativa).

Nos casos de usurpação negativa a LDA garante ao autor, além do direito à indenização por danos morais⁸⁴, o direito a ter sua identidade divulgada da seguinte forma:

⁸¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 538.

⁸² Art 5º, inciso VII.

⁸³ Há autores que não consideram o plágio como contração a exemplo de: ALGARDI, Zira. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 197.

⁸⁴ A indenização pela violação de direitos morais de autor, que é cumulativa à indenização por violação de direitos patrimoniais, independe

- a) tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
- b) tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;
- c) tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma acima.

Apesar de, aparentemente, a LDA ter-se referido exclusivamente aos casos de usurpação negativa, nada impede que o procedimento *supra* seja utilizado também nos casos de usurpação positiva.

A segunda espécie é o ato ilícito relativo. Esse é comparado por Mello⁸⁵ à culpa ou dolo contratual. Ou seja, é a impossibilidade culposa ou dolosa do cumprimento de determinada obrigação. É a prática do ato de que deveria ter-se omitido em decorrência de relação obrigacional. O ato ilícito relativo, por ser derivado de culpa contratual, enseja a instauração de procedimentos judiciais cabíveis para o descumprimento das obrigações em geral e não a aplicação das sanções previstas na LDA para a responsabilidade extracontratual.

Por fim, é importante ressaltar que o procedimento judicial cível previsto nas Leis 9.609/98 e 9.610/98 decorrem, exclusivamente, da violação dos direitos autorais, sejam eles morais ou patrimoniais. Assim, a causa de pedir há de ser o ato ilícito absoluto acima estudado.

de comprovação de efetivo prejuízo econômico conforme decidido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação Cível 590044657.

⁸⁵ MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico*, p. 193

Dessa forma, a responsabilidade será solidária de quem vende, expõe à venda, oculta, adquire, distribui, mantém em depósito ou utiliza a obra fraudulenta com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto para si ou para outrem⁸⁶.

A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, em julgamento da Apelação Cível 350.607-0 de 19 de dezembro de 2001, reconheceu à unanimidade a responsabilidade solidária do proprietário, bem como do locatário do estabelecimento onde se deu a contrafação, a teor do art. 68 da LDA.

A LDA prevê, além daquelas já transcritas, as seguintes sanções civis à violação de direitos autorais:

- Apreensão dos exemplares fraudulentamente reproduzidos, divulgados ou de qualquer forma utilizados.
- Indenização por perdas e danos. Há alguns casos de liquidação legal dos danos. Tratando-se de execução pública sem autorização do titular ou do ECAD ou sem pagamento dos *royalties* devidos, os responsáveis estarão sujeitos ao pagamento de multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago. Tratando-se de edição de obra, sem autorização do titular, a indenização englobará a perda dos exemplares apreendidos e o pagamento do preço dos que tiver vendido. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta pagará o transgressor o valor de três mil exemplares além dos apreendidos⁸⁷. Apesar

⁸⁶ Art. 104 da LDA.

⁸⁷ A legislação brasileira foi marcada por uma crescente rigidez no arbitramento legal do valor da indenização pela contrafação de direitos autorais. Inicialmente fixou a indenização mínima no valor de 50% do valor

dessa liquidação legal dos danos referir-se expressamente à edição fraudulenta, comporta aplicação também em situações análogas, ou seja, aquelas em que a contrafação se der por meio de reprodução mecânica e comercialização dos exemplares reproduzidos fraudulentamente, como sói acontecer nos casos de pirataria de *software*⁸⁸, fonogramas, etc., bem como nas situações em que o contrafrator:

- a) alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;
- b) alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados⁸⁹ destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia;
- c) suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos;
- d) distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações, execuções ou emissões, sabendo ter ocorrido uma das três situações anteriores.

venal da edição (Lei 496/1898), posteriormente, no valor da receita bruta (Decreto 4 790/1924), depois no valor máximo de 3.000 exemplares (Lei 5 988/1973) e, por fim, no valor fixo de 3.000 exemplares além dos apreendidos (Lei 9.610/1998)

⁸⁸ Não se aplica, porém, aos casos em que a pirataria de *software* não tem finalidade de comercialização, divulgação ou distribuição de exemplares conforme julgamento da Apelação Cível 360 929-4 pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais realizado em 7 de agosto de 2002.

⁸⁹ Sobre a regulamentação dos sinais de identificação de fonogramas ver Decreto 4 533 de 19 de dezembro de 2002

- Suspensão ou interrupção da utilização fraudulenta e cominação de multa diária para o caso de descumprimento. Havendo reincidência o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.
- Destruição dos exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito autoral civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim.

CAPÍTULO IV

LIMITAÇÕES AOS DIREITOS PATRIMONIAIS

4.1 USO PRIVADO

Conforme analisado acima, o direito patrimonial é instrumento que visa garantir ao autor a obtenção das vantagens econômicas decorrentes da utilização da obra. Assim, o exclusivo de exploração econômica incide apenas sobre utilizações públicas ou coletivas da obra.

Lipszyc¹ adota a concepção de uso pessoal ao invés de uso privado, situação em que a liberdade de utilização condicionar-se-ia às utilizações individuais da obra.

Tal concepção, porém, restringiria demasiadamente o uso privado que não se limita às utilizações individuais, mas se estende ao recesso familiar e ao círculo de amigos do usuário². Qualquer outro entendimento afrontaria o direito à vida privada em suas dimensões subjetiva e objetiva, ou seja, violaria o direito subjetivo do usuário como também a regra constitucional.³ É o caso, por exemplo, da decisão proferida pela Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 329860/RJ, realizado em 9 de novembro de 2004, que con-

¹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 222.

² Art. L. 122-5 1º do Código de Propriedade Intelectual Francês, D.n. 95-385/1995

³ SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito à intimidade e à vida privada*, p. 209

siderou que a simples disponibilização de aparelhos de rádio e TV em quartos de hotel e de demais locais de frequência coletiva sujeita-os ao pagamento de direitos autorais.

Isso porque o conteúdo do direito subjetivo à vida privada protege o indivíduo não apenas da divulgação de sua vida privada por terceiros, como também da intromissão alheia em sua esfera privada⁴. Assim, garantir-se ao autor uma suposta pretensão de determinação e controle do uso privado da obra, tratar-se-ia de ingerência ilegítima na esfera individual.

Com a massificação social decorrente da urbanização, industrialização e do capitalismo, o indivíduo, subliminarmente em alguns casos e ostensivamente em outros, vem perdendo seus espaços público e privado para o mundo corporativo. A saturação do espaço público gera a busca pela ocupação do espaço privado e o indivíduo passa a sofrer um ataque ostensivo em sua esfera individual, onde nem mesmo ao Estado seria permitido interferir, senão excepcionalmente⁵. É o que acontece com o critério de cobrança de direitos autorais feito diretamente ao usuário. O monitoramento da ação do usuário com a finalidade de se evitar que ela ultrapasse os limites do uso permitido pelo titular (correlato à remuneração recebida) e lhe assegure a devida indenização no caso de transgressões tem levado, ordinariamente, à invasão de seu espaço privado.

4.2 LIMITAÇÕES LEGAIS

Dizer que o direito patrimonial de autor da obra abrange apenas as formas públicas de utilização da obra não significa dizer que todas as formas públicas de utilização da obra estariam, necessariamente, alcançadas⁶.

Por essa razão, tanto a LDA como a LDS impõem limitações aos direitos patrimoniais de autor. Entende-se por limitações as situações em que a utilização pública da obra não estaria compreendida pelo conteúdo do Direito Autoral. Ocorre que, como já dito anteriormente, no rol de limitações foram inseridas impropriamente algumas situações que não limitam o Direito Autoral, mas, paradoxalmente, ampliam seu conteúdo, tendo em vista que acabam restringindo o uso privado.

Assim, são utilizações livres:

- A reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. É importante lembrar que a teor da Súmula 221 do STJ são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação, cabendo a este a ação regressiva contra aquele.
- A reprodução em diários e periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Verifica-se tanto nesta hipótese como na anterior a noção de que o direito à informação se coloca como limite ao Direito Autoral⁷.
- A reprodução de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feita sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles

ção de espetáculos, e sem comportar entradas pagas, é uma utilização pública – e todavia não está enquadrada na reserva estabelecida por lei. Nas mesmas condições estará uma representação de operários, ou uma apresentação em colégios ou asilos. Por isso não terão de ser remuneradas.”

⁷ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 273-274.

⁴ AULETTA, Tommaso Amedeo. *Riservatezza e tutela della personalità*. Milão: Giuffrè, 1978, p. 14.

⁵ KLEIN, Naomi. *Sem logo*. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 308-311.

⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 163: “A representação feita por amadores, em recinto aberto, mas não destinado à realiza-

representada ou de seus herdeiros. Nesses casos, a oposição poderá se dar quando a reprodução puder atingir sua honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.

- A reprodução das obras literárias, artísticas e científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou por outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários, a exemplo da gravação ou da digitalização de obras para serem por eles ouvidas. A LDA, nesse ponto, possui inegável contributo ao solidarismo social. Infelizmente, a efetiva inclusão intelectual do deficiente visual ainda esbarra na ausência de iniciativa política, pública e particular.
- A reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por esse sem intuito de lucro. A expressão pequenos trechos é de difícil definição. A melhor orientação é a de que a conceituação não deve se basear em um critério quantitativo, mas em um critério qualitativo que deve levar em consideração o grau de significância do trecho reproduzido em relação à obra de que foi extraído⁸. A questão, todavia, é de difícil solução, principalmente no que se refere à reprografia de obras literárias. Nesses casos, a solução mais eficaz parece ser a tributação sobre as máquinas copiadoras. Assim, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) tem buscado a realização de convênios com empresas distribuidoras de máquinas reprográficas, bibliotecas, faculdades e centros de reprografia para a cobrança

⁸ MANSO, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*, p. 274.

de direitos autorais sobre as cópias realizadas⁹. É importante frisar que a restrição legal aplica-se tão-somente aos casos em que o destinatário da cópia não for o possuidor do exemplar. No caso de legítimo possuidor de exemplar, a cópia para uso privado pode atingir a obra integral, pois tem a finalidade de salvaguarda¹⁰ e não afeta o exclusivo de exploração econômica. Por fim, é de se atentar para o fato de que a reprodução, mesmo em pequenos trechos, só é permitida se for para uso privado do copista, o que gera situações surreais. Consultada se o professor poderia copiar uma página de um livro para trabalhar com seus alunos, a resposta da ABDR foi negativa por extrapolar o conteúdo da permissão legal¹¹. A Lei 10.695/2003, contudo, dá novo rumo ao debate ao descriminalizar a cópia de obra intelectual em um único exemplar, mesmo que integral, para uso privado do copista desde que não haja intuito de lucro, direto ou indireto. A polêmica restringe-se, portanto, ao Direito Civil.

- A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. A con-

⁹ OLIVER, Paulo. *Direitos autorais da obra literária*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 152.

¹⁰ Nesse sentido, a LDS em seu art. 6º, inciso I, prevê que não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda.

¹¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS. *Perguntas e respostas mais frequentes*. Rio de Janeiro. [s.d.] Disponível em: <<http://www.abdr.org.br>>. Acesso em: maio 2005.

dicionante posta pelo legislador visa evitar que a passagem citada se torne a substância da obra que a cita. Em outras palavras, a obra que citá a passagem deve ter sua substância própria, conservando-se íntegra mesmo que a passagem citada fosse retirada. No mesmo sentido a LDS.

- O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, sendo, porém, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. É certo que tal permissão refere-se tão-somente à questão autoral, preservando-se a liberdade de cátedra em que a metodologia de trabalho adotada pode vir a excluir tal prática. Além disso, o que se permite é que o aluno tome notas das lições ministradas pelo professor e não que as copie, grave ou reproduza.¹²
- A utilização de obras literárias, artísticas e científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para a demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização.
- A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Nesse ponto, a LDA se mostrou excessivamente restritiva ao restringir a limitação apenas a obras teatrais ou musicais. O entendimento mais acertado parece ser o de se estender analogicamente a permissão a outras espécies de obras, como as

¹² ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 260.

cinematográficas e audiovisuais. Da mesma forma, há de se interpretar extensivamente as expressões recesso familiar e estabelecimento de ensino.¹³

- A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa.
- A reprodução em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.
- As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.
- A reprodução temporária com o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no uso devidamente autorizado da obra pelo titular. Trata-se dos casos de tratamento de sons e imagens e de digitalização de obras.
- As paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. É óbvio que a ressalva legal tem cabimento apenas no primeiro caso. Tratando-se de paródias, o grau de imitação da obra parodiada é irrelevante juridicamente¹⁴. Paráfrase é a explicação, tradução, desenvolvimento ou interpretação de um texto sem alteração das idéias originais. Paródia é a

¹³ MANSO, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*, p. 324.

¹⁴ MANSO, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*, p. 327.

imitação cômica ou irônica de obra literária¹⁵. Tratando-se de direitos autorais, a previsão legal alcança também as caricaturas. É de se ressaltar, porém, que a caricatura enquanto forma de representação da imagem pode ter sua divulgação proibida pela pessoa representada nos termos do art. 20 do Código Civil, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

- Tratando-se de programas de computador, não constituem ofensas a seu titular a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão, nem a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Há entendimentos de que as limitações dos direitos patrimoniais de autor estejam sujeitas a *numerus clausus*, devendo ser interpretadas e aplicadas de forma restritiva¹⁶.

Contudo, as opiniões nesse sentido não parecem ser as mais acertadas. Principalmente em um país que possui uma das legislações mais rígidas no que se refere à proteção autoral.

A legislação italiana, por exemplo, é mais flexível. No art. 68 prevê que é livre a reprodução integral da obra para uso privado do leitor desde que feita à mão ou com meios não-idôneos à difusão da obra ao público. É livre, também, a fotocópia das obras existentes em bibliotecas, feitas para uso privado ou para os serviços da biblioteca.

No mesmo sentido o art. 108 da Lei de *Copyright* dos Estados Unidos da América que permite a realização de até três cópias da obra existente na biblioteca para as finalidades de salvaguarda e preservação.

A Lei francesa também se posiciona de forma a garantir o uso privado. O art. 122-5 2º prevê que o autor não pode impedir as cópias ou reproduções exclusivamente destinadas ao uso privado do copista.

A DDASI (Diretiva Européia sobre Direitos de Autor e Afins na Sociedade da Informação) prevê também uma série de limitações e estatui, em alguns casos, a figura interessante da justa compensação. Isto é, apesar da utilização ser livre, independentemente de autorização do autor, não é gratuita, ou seja, o usuário deve pagar uma justa remuneração ao autor. O pagamento dessa justa compensação pode permitir uma maior liberdade do usuário sem privar o autor do recebimento de uma compensação.

Segundo Ascensão:

Não se pode deixar de lamentar a ganância dos inspiradores da lei na limitação destas faculdades, esquecendo finalidades sociais, culturais, humanitárias e outras que mereceriam ser acarinhadas. Fica assim a lei brasileira muito aquém de leis estrangeiras. Tudo proíbe, com a preocupação de evitar fraudes ou diminuição de lucros¹⁷.

É de se ressaltar que o comentário acima transcrito não se baseou na atual LDA, mas na anterior, Lei 5.988 de 14 de dezembro de 1973. A situação se torna mais gritante ao se perceber que a nova lei é ainda mais rígida que a anterior.

Invariavelmente o legislador brasileiro tenta combater a ineficácia de uma lei com outra ainda mais rígida¹⁸. As-

¹⁵ FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Dicionário Aurélio*. 6. ed. Curitiba: Positivo, 2004, p. 608-611.

¹⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 220.

¹⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 164.

¹⁸ Recentemente o legislador brasileiro elevou para dois anos de reclusão a pena mínima para a violação de direitos autorais com intuito de lucro (Art. 1º da Lei 10.695/2003).

sim só faz acentuar sua ineficácia. Quando se questionam as razões pelas quais a LDA é pouco observada na sociedade brasileira, não há como não incluir a excessiva rigidez da lei que quer proibir tudo e acaba não proibindo nada.

É importante que o legislador brasileiro atente para o fato de que se não assegurar ao indivíduo um mínimo de liberdade na utilização da obra não garantirá a eficácia da legislação autoral¹⁹, gerando a descrença e a incerteza do Direito. Fica a lição da União Européia (DDASI) que propõe a elevação do nível de proteção à propriedade intelectual pela adoção de mecanismos que gerem uma maior certeza do Direito, ao invés de elevar sua rigidez.

Não há como negar que, por natureza, a norma jurídica deva limitar a liberdade individual, essa é uma de suas mais importantes funções, o que leva a concluir que o contorno da liberdade é obra da própria lei²⁰. Mas quando a limitação é excessiva não se atenta para a noção fundamental de que a liberdade é a essência do homem²¹.

A atual sistematização do Direito Autoral não atinge sua finalidade de promoção da cultura inclusive por não garantir ao criador uma adequada compensação financeira pelo uso de suas obras. Essa ausência de autonomia financeira do criador desestimula a atividade criativa o que, conseqüentemente, obstaculiza o desenvolvimento cultural.

A considerável resistência diante da LDA revela uma reserva mental ou objeção de consciência que se apresenta como reação ao que se pode chamar de excessiva restrição da liberdade individual²².

¹⁹ KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 48.

²⁰ CRUET, Jean. *A vida do direito e a inutilidade das leis*. Lisboa: Ibero-Americana, 1908, p. 196.

²¹ RIBAS, Conselheiro Joaquim. *Direito civil brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1983, p. 253.

²² COSTA, Nelson Nery. *Teoria e realidade da desobediência civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 49-51.

Segundo Coelho²³, a legitimidade é a condição de aceitação da norma jurídica pelos membros da sociedade.

Essa delimitação excessiva do uso privado decorre diretamente de um critério de cobrança de direitos autorais que se baseia na cobrança direta e individual pela utilização da obra. É essa a razão que leva à busca pelo controle do uso privado da obra, para se garantir uma crescente remuneração autoral.

Apesar de o critério individual trazer a promessa de um eldorado autoral, ela nunca se concretizou. Os autores não dispõem de mecanismos hábeis para realizar o controle rigoroso do usuário final, imprescindível para se garantir a adequada remuneração autoral por este sistema. Segundo Cruet, a sociedade “está muito longe de ser uma massa à qual a cozinheira pode dar a forma que mais lhe agrada: a de pastel ou a de torta”²⁴.

Essa realidade que se tornou muito mais manifesta em decorrência da urbanização, da globalização, da massificação social e da tecnologia virtual tem transformado a remuneração autoral, em alguns casos, em mera quimera.

A verdade é que o critério individual não se mostra mais viável para garantir ao autor a devida remuneração como contraprestação às utilizações maciças da obra. A atenuação do problema da remuneração autoral pressupõe a adoção de novos meios e o aprimoramento dos existentes para a cobrança indireta dos direitos autorais. O critério indireto de cobrança garante a remuneração autoral junto ao intermediário (a exemplo do provedor, da central reprográfica, do produtor fonográfico, do promotor de eventos, etc.) e desonera o usuário ou destinatário final da cobrança direta, a exemplo

²³ COELHO, Luiz Fernando. *Teoria crítica do direito*. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 517.

²⁴ CRUET, Jean. *A vida do direito e a inutilidade das leis*, p. 229.

do que já é feito atualmente pelo ECAD e pela ABDR. Infelizmente a cobrança coletiva realizada pelos referidos órgãos ainda não alcançou o grau de transparência desejável em um Estado de Direito, passando à margem do dever legal de lealdade (boa-fé objetiva) tanto em relação ao usuário como em relação ao próprio autor.

Essa preocupação levou ao pedido de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados²⁵, a fim de apurar irregularidades na cobrança coletiva e distribuição de direitos autorais. O pedido que contou com a assinatura de mais de cem parlamentares amparou-se, basicamente, nas seguintes razões:

- os reiterados reclamos de autores e compositores acerca de irregularidades na distribuição dos direitos arrecadados;
- a coação sofrida pelos usuários que devem sujeitar-se ao arbítrio das entidades arrecadadoras na fixação dessas taxas;
- desproporção entre os valores arrecadados e os valores repassados;
- estatutos leoninos das entidades;
- falta de transparência financeira e patrimonial das entidades.

À parte essa questão, a utilização do critério coletivo de cobrança não é recente. Já em 1962, o Tribunal de Berlim decidiu que, no caso de reprodução magnética de obras musicais para uso pessoal, a responsabilidade indireta pelos danos decorrentes da contrafação seria dos produtores dos materiais necessários à referida prática: o gravador e a fita virgem.

²⁵ Resolução 36 de 1967 publicada no DCN de 27 de setembro de 1967, p 5885 e 5886.

Em 1965 foi promulgada a Lei Federal reconhecendo aos autores percentual de até 5% sobre o preço de venda dos referidos produtos. Em 1972, na conferência-geral da Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura (UNESCO), foi criado um grupo de trabalho para discutir a questão que terminou por concluir pela necessidade de acordos coletivos e medidas legislativas para permitir uma maior socialização dos produtos culturais, bem como uma justa remuneração aos autores.

Em 1976 foi criada, na França, uma lei que instituiu um ônus de 3% sobre os produtores e importadores de aparelhos de reprodução, denominado contributo sobre o uso da reprografia²⁶.

O legislador italiano desde 1988, busca garantir ao autor uma justa remuneração pelo critério coletivo. A Lei 93, de 5 de fevereiro de 1992, prevê percentuais que variam de 3% a 10% sobre o preço de venda dos aparelhos utilizados para reprodução de obras, como gravadores, videocassetes, etc.

Do valor arrecadado 50% é repartido entre os autores, 25% para os produtores e 25% para os artistas, intérpretes ou executantes.

É importante ressaltar que a simples modificação da lei não garante a transformação do direito, a exemplo do que ocorreu com a LDA que, apesar de recente – 19 de fevereiro de 1998 – sofreu grande influência do liberalismo e do *Copyright Act* estadunidense.

A influência norte-americana acaba gerando certo antagonismo, uma vez que a concepção continental do Direito Autoral visa garantir remuneração ao autor, e a concepção do *Copyright* visa garantir a comercialização da obra.

Assim, verifica-se a tendência em se garantir a exploração econômica da obra ao invés de se garantir uma ade-

²⁶ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 282.

quada proteção do autor, a exemplo do ocorrido na LDS. Nesse caminho, a proteção autoral beneficia cada vez mais ao “empresário da cultura ou tecnologia” e cada vez menos ao indivíduo que cria.

Trilhando tais caminhos não se poderá mais falar em proteção do autor, mas em proteção do fornecedor de bens culturais ou tecnológicos. A tutela deixa de ser estímulo à criação e se constitui estímulo à comercialização.

Desse modo, verifica-se que apesar da excessiva proteção ter sido justificada pela necessidade de proteção do autor enquanto parte frágil da relação, a inexistência de tratamento diferenciado entre autor e titular de direitos autorais, faz com que a proteção legal habitualmente beneficie o titular derivado, que não é, necessariamente, contratante débil. A questão se assevera ainda mais quando se constitui uma relação de consumo.

Além disso, essa excessiva proteção aos direitos patrimoniais, restringindo o uso privado, é prejudicial tanto aos interesses individuais quanto aos interesses sociais. Segundo Klein²⁷, graças à excessiva proteção, o abuso do Direito Autoral é uma indústria crescente.

São constantes os abusos praticados por titulares de direitos autorais, chamados de fanfarrões do *Copyright*. Klein²⁸ relata uma série de situações inusitadas como o caso em que a *Walt Disney Co.* exigiu que um grupo de pais em uma pequena cidade da Nova Zelândia retirasse seus desenhos do *Pluto* e do *Pato Donald* de um mural de *playground*.

A lesão aos interesses sociais se apresenta no momento em que a excessiva proteção gera uma espécie de censura privada: privatiza-se a linguagem, o discurso e a cultura.

É lamentável constatar a vocação colonial de nosso legislador que começa a infiltrar em nossa legislação a con-

²⁷ KLEIN, Naomi. *Sem logo*, p. 201-202.

²⁸ KLEIN, Naomi. *Sem logo*, p. 201

cepção comercialista do *Copyright* justo no momento em que ela começa a ser revista em seu país de origem (EUA), onde o instituto do *fair use*²⁹ ganha cada vez mais força.

Dessa forma, ao passo que o direito patrimonial do autor tem sido visto sob o prisma do liberalismo, como um poder ilimitado do autor sobre a obra, a enumeração legal de suas respectivas limitações tem sido interpretada restritivamente como se os casos ali previstos já implicassem ônus excessivo para o autor.

Ocorre que, cada uma das limitações previstas na LDA decorrem da recepção legal de um ou outro princípio constitucionalmente garantido, que em determinadas situações pode ser considerado o direito à intimidade e à vida privada, em outras a garantia do desenvolvimento nacional³⁰, ou o acesso à informação³¹, cultura, educação e ciência.³²

Assim, é de se indagar se as limitações aos direitos patrimoniais de autor realmente se restringem aos casos previstos na LDA. Em outras palavras, se a LDA realmente pode

²⁹ Trata-se de construção jurisprudencial estadunidense recepcionada na lei de *Copyright* (art 107) que garante a liberdade da utilização da obra protegida para crítica, comentários, jornalismo, educação ou pesquisa, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) uso não comercial;
- b) a natureza da obra;
- c) a originalidade da nova obra;
- d) ausência de desvalorização da obra utilizada ou prejuízo mercadológico;

³⁰ Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

II – garantir o desenvolvimento nacional; (Constituição Federal)

³¹ Art. 5º XIV É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

³² Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

restringir as garantias fundamentais constitucionais que a norteiam.

Segundo Habermas³³, a autonomia privada só pode ser entendida como elemento de um processo progressivo de efetivação das garantias constitucionais. Consequentemente, o exercício do direito subjetivo não se pode desvirtuar dessa finalidade.

Em face do paradigma do liberalismo-individualismo poder-se-ia justificar a interpretação restritiva. Porém, em face do paradigma do Estado Democrático de Direito, a interpretação extensiva se impõe.

Na lição de Perlingieri³⁴, as limitações ao direito subjetivo não devem ser consideradas como meras exceções previstas na Lei, mas como elementos estruturais do próprio Direito, que o definem e delimitam.

São as duas faces da mesma moeda, integram uma mesma situação jurídica e não podem, pois, se dissociar. O direito subjetivo não é atribuído a seu titular como forma de satisfação de seu interesse individual, mas como forma de atender ao interesse coletivo de tornar efetivas as garantias instituídas pelas normas constitucionais.

Dessa forma, o direito patrimonial do autor não pode mais ser visto sob o prisma exclusivo do interesse do autor, sendo certo que seu exercício deve harmonizar-se com a funcionalidade da propriedade intelectual³⁵.

Portanto, as normas constitucionais que asseguram o desenvolvimento nacional, o acesso à informação, à educação,

à cultura e à ciência não podem ser vistas apenas como limitações ao direito patrimonial do autor, mas como causas de sua atribuição. Assim, o exercício dos direitos patrimoniais do autor deve ser meio de garanti-las, não obstáculo a sua efetivação.

Tais garantias constitucionais limitam o direito patrimonial do autor, e qualquer forma de exercício deste que as obste deve ser vista como abuso de direito ou excesso de poder³⁶.

³³ HABERMAS, Jürgen. *Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy*. New Bakersville: MIT, 1996, p. 410.

³⁴ PERLINGIERI, Pietro. *Perfil do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 122.

³⁵ A função social não é mera limitação extrínseca à propriedade, mas, precisamente, a causa de sua atribuição (TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*, p. 281).

³⁶ PERLINGIERI, Pietro. *Perfil do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 122.

CAPÍTULO V

NATUREZA JURÍDICA DA TUTELA AUTORAL

5.1 O FATO JURÍDICO GERADOR DA TUTELA AUTORAL

A situação jurídica autoral surge com a exteriorização da criação do espírito¹. A tutela autoral pressupõe não apenas a existência da criação como também sua exteriorização. Assim, enquanto a criação permanecer no íntimo do autor, não receberá proteção.

Segundo Algardi², com o fato criativo, o autor pode buscar satisfazer-se intimamente, socialmente e economicamente. A criação é suficiente para alcançar a primeira finalidade, mas para alcançar as demais, faz-se necessário sua exteriorização. Se o autor buscar apenas uma satisfação íntima, não precisará exteriorizar a obra, mas, nesse caso, sua criação não produzirá efeitos jurídicos. A criação intelectual não é ato jurídico. A exteriorização da criação intelectual sim.

¹ Art. 7º da LDA: "São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:"

² ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 526

Segundo Ascensão³, exteriorizar a obra é manifestá-la por qualquer meio captável pelos sentidos humanos. Segundo De Sanctis⁴, se a exteriorização não se der por meio apreensível por terceiros, o Direito Autoral não se constitui.

A exteriorização não se restringe à idéia de divulgação da obra, que pode ser exteriorizada sem ser divulgada. O autor pode escrever uma poesia em uma folha de papel e guardá-la na gaveta. A obra é inédita porque ainda não foi divulgada, mas é protegida por ter sido exteriorizada.

A LDA considera como espécies de divulgação ou publicação, a distribuição e a comunicação ao público. Publicação ou divulgação é o oferecimento da obra ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de Direito Autoral, por qualquer forma ou processo.

Comunicação ao público é ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento, que não consista na distribuição de exemplares. Distribuição é a colocação à disposição do público do original ou cópia de exemplares da obra.

A exteriorização também não se restringe à idéia de fixação da obra. Há determinadas obras que só se exteriorizam pela fixação, como é o caso de obras de artes plásticas. Há obras, porém, que se exteriorizam sem ser, necessariamente, fixadas, como é o caso de uma obra musical ou de uma poesia que podem ser exteriorizadas em público, de improviso, sem serem gravadas, recebendo igualmente a proteção legal.

A exteriorização da criação intelectual independe da observância de qualquer formalidade⁵, podendo ser provada por confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, a teor do que dispõe o art. 212 e seguintes do Código Civil.

³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 30.

⁴ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 18.

⁵ Art. 18. "A proteção dos direitos de que trata esta Lei independe de registro" (LDA).

É lógico que, para segurança de seus direitos, é facultado ao autor da obra intelectual registrá-la, conforme sua natureza, em um dos seguintes órgãos:

- Biblioteca Nacional;
- Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
- Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
- Instituto Nacional do Cinema;
- Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia.

Se a obra, por sua natureza, comportar registro em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada naquele que for mais pertinente.

O registro não gera, todavia, prova plena da autoria ou titularidade da obra intelectual, podendo ser impugnado pelo verdadeiro autor ou titular. O registro, que tem natureza meramente declaratória do direito, gera apenas uma presunção relativa de autoria ou titularidade. Segundo Emery⁶, o registro é prova apenas da pretensão de propriedade do requisitante, e não um título de uma propriedade adquirida e oponível *erga omnes*.

5.2 A NATUREZA RELACIONAL DA TUTELA AUTURAL

A exteriorização da criação intelectual é fato voluntário que origina a situação jurídica autoral, que em seu aspecto subjetivo é tanto existencial como patrimonial⁷.

⁶ EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*, p. 57.

⁷ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 181.

A situação jurídica existencial consiste na tutela da personalidade do autor enquanto valor fundamental do microsistema autoral. Nesses casos não há que falar em *numerus clausus*, a proteção à personalidade do autor não se restringe a qualquer enumeração legal.

Os direitos morais de autor protegidos no art. 24 da LDA devem ser considerados como algumas de suas expressões consideradas mais relevantes pelo legislador (expressões típicas), o que não exclui a proteção de expressões atípicas. Segundo Perlingieri, as situações existenciais não assumem, necessariamente, a forma do direito subjetivo e não retiram a unidade do valor tutelado⁸. Dessa forma pode-se falar em um direito moral geral de autor.

As situações jurídicas patrimoniais são aquelas que tratam dos interesses econômicos do autor ou do titular de direitos autorais.

Essa situação autoral que surge com a exteriorização da criação autoral, tanto no aspecto patrimonial quanto no aspecto existencial, reveste-se de caráter absoluto, não no sentido de conferir ao autor um poder ilimitado, mas no sentido de que comportaria oponibilidade *erga omnes*, visto que a relação jurídica não estaria inicialmente individuada tendo em vista que o(s) sujeito(s) passivo(s) ou pólo de interesses⁹ contraposto ainda estaria por se determinar¹⁰.

É lógico que, em um contexto dinâmico, seu exercício constituirá novas situações jurídicas que poderão, por sua vez, ter eficácia relativa. Nesses casos, porém, o fato constitutivo do direito do autor não é a exteriorização da criação, mas o exercício de sua autonomia privada. Como o caso de

o autor celebrar um contrato de edição de sua obra. Os direitos daí decorrentes são oponíveis pelo autor ao editor e vice-versa.

Em outras palavras, em um aspecto estático, a exteriorização da criação atribui ao autor uma série de faculdades que ele pode optar entre exercer ou não. A partir do momento em que ele opta por exercê-las¹¹, no todo ou em parte, determinam-se novos pólos de interesses (correlação por identidade de referência objetiva), formando-se, assim, novas situações subjetivas.

É o caso, por exemplo, dos direitos conexos que poderão advir da interpretação, execução, produção ou radiodifusão da obra. A situação subjetiva autoral deve ser vista, portanto, como um dos elementos da relação jurídica que se constitui da ligação entre essas várias situações subjetivas contrapostas que a compõem.

É importante frisar que nem mesmo em uma contextura estática pode-se considerar o autor como único pólo de interesses relevante. Com o exercício da autonomia privada a questão da relativização de suas faculdades é mais facilmente apreensível pelo fato de o centro subjetivo da situação contraposta se determinar, ganhando visibilidade.

Mas, mesmo nas situações absolutas, em que o pólo subjetivo contraposto ainda não se encontra determinado, não se pode cair no equívoco de pensar que haveria aí um poder absoluto do autor ou um único pólo subjetivo. É bem verdade que o pólo contraposto ainda está indeterminado, exigindo um maior grau de abstração para ser visualizado, o que, contudo, não pode impedir a adoção de uma adequada concepção relacional das situações jurídicas daí decorrentes, e, conseqüentemente, das limitações e dos direitos subjetivos que a integram.

⁸ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 156.

⁹ Há quem prefira a noção de pólo de faculdades ou liberdades.

¹⁰ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 141.

¹¹ Em uma noção relacional o exercício da liberdade individual é, portanto, fonte de deveres. A autonomia privada baseia-se, assim, no binômio liberdade-responsabilidade.

Na verdade mesmo as situações absolutas exigem uma concepção relacional para serem bem compreendidas. É o que faz concluir que, mesmo em seu aspecto estático, a situação subjetiva autoral não se constitui por si ou para si, mas em função desta potencial contraposição de sujeitos ou pólos de interesses, mesmo que inicialmente indeterminados.

Assim, é importante atentar-se para o fato de que a atribuição de direitos ao autor corresponde à imputação de deveres a terceiros e ao próprio autor (perfil funcional normativo) o que faz com que os interesses autorais não possam ser vistos isoladamente, mas somente na medida dos deveres a ele correlatos. Sua exata relevância só pode ser determinada nesse contexto relacional ou funcional¹². É nesse sentido, por exemplo, que deve ser aplicado o parágrafo único do art. 89 da LDA, que assegura a preeminência do Direito Autoral sobre os direitos conexos.

Essa coexistência e conseqüente contraposição se impõem pela própria natureza relacional do direito subjetivo, que não é objeto de mera contemplação, mas instrumento (escudo e espada) de equilíbrio desta teia de situações subjetivas correlatas. Não há como dimensionar a situação jurídica do autor, senão em contraposição às demais situações que se correlacionam.

O indivíduo (autor) deixa de ser o centro do sistema jurídico autoral e cede vez à dignidade humana na posição central. O termo Direito Autoral deve deixar de ser entendido como direito do autor e passar a ser concebido simplesmente como direito decorrente da exteriorização da criação autoral, mesmo porque, na prática é crescente o número de situações jurídicas em que não se verifica a identidade entre autor e titular de direitos autorais.

¹² PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 120.

Segundo Alpa¹³, só se pode aferir a medida da situação jurídica autoral identificando-se todos os interesses que se pretende proteger com a atribuição do Direito Autoral.

Com a exteriorização da criação polarizam-se vários pólos de interesses, surgindo a necessidade de vinculação do autor à obra, de garantir a exclusividade de exploração econômica, mas também, de se estimular a criação, desenvolver a cultura, garantir o acesso ao conhecimento, etc.

A atribuição do Direito Autoral não se faz, portanto, unicamente com a finalidade de se satisfazer os interesses individuais do autor, mas também com a finalidade de se encontrar o ponto de equilíbrio entre esses vários interesses em questão, jamais como instrumento de desequilíbrio, seja contra o autor, seja a favor dele.

Sob esse prisma, o direito subjetivo autoral é visto como ferramenta atribuída ao indivíduo para participar da construção da norma jurídica concreta (decisão judicial), a que será submetido¹⁴.

Assim, sendo o direito subjetivo autoral um dos pilares em que alicerçar-se-á a norma jurídica individual, deve ser exercido dentro de determinados limites que lhe legitimam enquanto elemento de construção normativa.

O exercício do Direito Autoral dentro desses limites é pressuposto de legitimidade normativa, seja da norma legal, seja da norma judicial, seja da norma negocial.

Portanto, o Direito Autoral só encontra guarida se exercido dentro dos limites de sua função econômica, de sua função social, da boa-fé e dos bons costumes¹⁵.

¹³ ALPA, Guido. *Elogio dell'incertezza*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 199.

¹⁴ Kelsen, Hans. *Teoria geral do direito e do Estado*. Tradução Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 127.

¹⁵ Art. 187 do Código Civil: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

O exercício do Direito Autoral fora desses limites caracterizaria abuso de direito. Segundo Pontes de Miranda¹⁶, estar-se-ia diante de exercício lesivo do direito. Esse exercício não poderia ser considerado como elemento de construção normativa, pois uma vez viciado, viciaria também a norma que nele se alicerçasse.

Segundo Theodoro Junior,

o titular de qualquer direito para conservar-se no campo da normalidade não basta legitimar sua conduta dentro das faculdades reconhecidas pelas normas legais em face de sua individual situação jurídica. Haverá de cuidar para que o uso das prerrogativas legais não se desvie para objetivos ilícitos e indesejáveis, dentro do contexto social. O abuso de direito acontecerá justamente por infringência deste dever e se dará sempre que o agente invocar uma faculdade prevista em lei, aparentemente de forma adequada, mas para alcançar objetivo ilegítimo ou não tolerado pelo consenso social¹⁷.

Por essa razão o Código Civil de 2002 tratou o abuso de direito como ato ilícito que pode ter como efeitos não apenas a indenização (art. 927), mas também a anulação ou revisão do negócio jurídico (arts. 157 e 424, etc.).

¹⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao código de processo civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, t. I, p. 352.

¹⁷ THEODORO JUNIOR, Humberto. *Comentários ao novo código civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3, p. 113.

CAPÍTULO VI

TITULARIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS

6.1 AUTORIA E TITULARIDADE

Autor é a pessoa física criadora de obra intelectual, mesmo que menor, interditado, inabilitado ou inconsciente¹, podendo identificar-se por seu nome civil, completo ou abreviado, por suas iniciais, por pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

A utilização da obra mediante indicação ou anúncio de uma dessas modalidades de identificação gera presunção relativa de autoria, a teor do art. 13 da LDA².

Apesar de fixar a regra da autoria material, a questão se mostra um pouco confusa na LDA tendo-se em vista que o legislador adotou, em alguns pontos da lei, uma concepção de autoria formal, como é o caso do art. 29.

Assim, o termo autor na LDA pode significar tanto autoria material como autoria formal, e a distinção, como ensina Ascensão³, só se pode fazer casuisticamente.

Em uma concepção material, autor é a pessoa física criadora da obra intelectual. Não é, portanto, assim considerado

¹ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 19.

² No mesmo sentido o art. 8º da Lei italiana e o art. 113-I da Lei francesa.

³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 70.

o colaborador passivo, aquele que simplesmente auxiliou o autor na produção da obra revendo-a, atualizando-a, fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação e nem mesmo o cessionário de direitos.

Em uma concepção formal, autoria nada mais é que titularidade de direitos autorais, englobando não apenas o autor ou o titular originário, mas também o titular derivado ou atual.

Titular originário de direitos autorais é aquele que os adquire no momento em que a criação intelectual é exteriorizada. Titular derivado é aquele que adquire os direitos autorais do autor por atos *inter vivos*, *causa mortis* ou por disposição legal, a exemplo dos casos de cessão legal⁴, respeitados em todos os casos os limites previstos na LDA, quais sejam:

- a) intransmissibilidade e inalienabilidade dos direitos morais;
- b) temporariedade da transmissão *causa mortis*;
- c) forma, prazos e interpretação contratual.

A titularidade originária em nosso ordenamento, seja sobre os direitos morais, seja sobre os direitos patrimoniais, será sempre do autor. A carta de direito de autor elaborada no XIX Congresso da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC) fundamenta a adoção da referida regra no fato de que o direito de autor se funda no ato de criação intelectual que se radica exclusivamente na pessoa física de seu criador⁵.

As pessoas jurídicas não ficam, todavia, à margem da proteção legal. A LDA prevê que a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos ali previstos.

⁴ Como nos arts. 94 e 95 da LDA que atribui ao produtor fonográfico e às empresas de radiodifusão os direitos decorrentes da utilização do fonograma ou da transmissão radiofônica, respectivamente

⁵ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 124

A redação da LDA pode gerar certa confusão. A proteção concedida ao autor tem conteúdo dúplice, moral e patrimonial. A previsão de aplicação da proteção concedida ao autor à pessoa jurídica pode gerar, à primeira vista, a idéia de que também possa ser titular do Direito Autoral em ambos os aspectos.

Essa transposição mecânica não se mostra, contudo, admissível tendo-se em vista que os direitos morais de autor têm por substrato um valor existencial humano que difere do valor existencial atribuível ao ente abstrato⁶. Aquele é anterior à própria norma enquanto que este é por ela criado.

A atribuição de personalidade enquanto aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações reúne tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas como sujeitos de direito, partindo de uma premissa ontológica, isto é, tem a função de identificar os figurantes das relações jurídicas. Por outro lado, os direitos da personalidade partem de uma premissa axiológica: de tutela valorativa da pessoa humana⁷.

É de se reconhecer que há cada vez mais vozes defendendo a possibilidade de se reconhecer a titularidade originária às pessoas jurídicas e, conseqüentemente, a plenitude do Direito Autoral. Segundo De Sanctis⁸, da mesma forma que em relação à filiação admite-se a paternidade natural e a adotiva, muitas vezes a obra se ligará à personalidade da pessoa jurídica e não à de seu autor material.

Não se pode realmente negar que haja um valor jurídico a ser reconhecido à personalidade da pessoa jurídica, mas é de se reconhecer que tal valor é, porém, diverso do valor existencial humano, o que pressupõe construção jurídica di-

⁶ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 158

⁷ CORTIANO JUNIOR, Eroulth. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de personalidade. In: FACHIN, Luis Edson (Coord.) *Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo*, p. 41.

⁸ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 66-67.

versa e não simplesmente a efetivação de uma transposição mecânica de tutela⁹.

Isso porque a proteção jurídica aos direitos da personalidade parte da premissa de elevação da pessoa humana, e apenas ela, ao centro do ordenamento jurídico e a realização de uma transposição mecânica, por mais que na superfície aparentasse progresso jurídico nada mais seria que retrocesso. Trata-se de tutela da personalidade humana e não simplesmente de tutela da personalidade jurídica.

É de se ressaltar, por fim, que em nosso ordenamento a titularidade da pessoa jurídica será sempre derivada, razão pela qual não receberá os direitos autorais em sua plenitude. Assim, a titularidade de direitos autorais por uma pessoa jurídica restringe-se à titularidade dos direitos patrimoniais de autor, tanto nos casos de cessão voluntária como nos casos de cessão legal.

Por exemplo, a exceção contida no art. 4º da LDS refere-se à titularidade dos direitos relativos aos programas de computadores sem especificar que se trate de direitos morais, patrimoniais ou de ambos. Partindo-se da premissa de que a titularidade da pessoa jurídica é derivada, impõe-se a interpretação restritiva da expressão englobando apenas o conteúdo patrimonial do direito.

Além dessa restrição direta, a titularidade derivada submete-se a uma restrição indireta. Como já visto, os direitos morais de autor são preeminentes em relação aos direitos patrimoniais, o que limita a atuação do titular derivado. Como já foi dito anteriormente, a transmissão dos direitos

⁹ Ao que parece é essa a idéia do art. 52 do CC que prevê a aplicação às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Não se trata de mera transposição de tutela, mas de abertura para construção de um valor existencial da pessoa jurídica a quem poderão ser reconhecidos direitos análogos aos direitos da personalidade, mas que não terão, via de regra, o mesmo conteúdo.

patrimoniais de autor não rompe o vínculo existente entre a obra e seu criador.

Há, ainda, algumas situações a serem analisadas.

6.2 OBRAS CRIADAS PARA OUTREM

Há, em Direito Autoral, várias categorias de obras criadas para outrem, são elas: as obras subvencionadas, as obras por encomenda (prestação de serviços e empreitada) e as obras decorrentes de relação de emprego ou dever funcional. Nesses casos indaga-se se a titularidade dos Direitos Autorais pertenceria ao autor ou ao terceiro.

A LDA se manteve silente sobre essas questões, fixando a regra geral de que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais decorrentes da criação. O art. 36 da Lei 5.988/73 (Lei de Direitos Autorais anterior à 9.610/98) estabelecia uma espécie de co-autoria nos casos em que o contrato fosse silente. O art. 36 do projeto de lei que originou a LDA¹⁰ atribuía, salvo convenção em contrário, ao empregador ou comitente, exclusivamente para as finalidades pactuadas, os direitos patrimoniais sobre a obra produzida em cumprimento de dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Como a LDA, contudo, foi sancionada sem tal previsão a questão melhor se resolve pela autonomia privada, ou seja, o contrato deverá dispor se o autor permanecerá titular dos direitos autorais ou se os estaria cedendo ao terceiro.

No caso de cessão de direitos, que será sempre interpretada restritivamente e deverá ser por escrito se for total e definitiva, o prazo máximo será de cinco anos. Na cessão de obras de existência atual caberá estipulação contratual

¹⁰ PIMENTA, Eduardo. *Princípios de direitos autorais*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 87.

diversa. Na cessão de obras de existência futura o prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se na devida proporção, o preço estipulado.

Silente o contrato sobre a titularidade dos direitos, a solução deverá nortear-se pela boa-fé objetiva, pelos usos e costumes locais, pela natureza do contrato e pela regra da interpretação restritiva. Por exemplo, nos contratos meramente subvencionados, por sua natureza, em princípio não há cessão de direitos para o terceiro subsidiante¹¹.

Por outro lado, pela natureza do contrato de trabalho, ao empregador pertencem os frutos daí decorrentes. Mesmo nesses casos, contudo, haveria dificuldade em se atribuir a titularidade originária ao empregador tendo-se em vista a norma expressa na LDA que atribui ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou¹². O que não impediria que o contrato de trabalho previsse uma transferência imediata ou automática desses direitos para o empregador¹³.

Os países de *common law*, por outro lado, admitem a titularidade originária do empregador. Essa diferença de concepção fez com que no Projeto de disposições tipo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para leis em matéria de direito de autor (CE/MPC/I/2-I/1989) houvesse a previsão de duas variantes, uma para os países de *common law* e outra para os países de tradição jurídica latina¹⁴. Naquela a titularidade originária seria do empregador e nesta do empregado¹⁵.

¹¹ Art. 6º da LDA

¹² Art. 22 da LDA.

¹³ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 147.

¹⁴ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 147

¹⁵ A título exemplificativo podemos citar a Lei francesa, e seu art. 111-1: "L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier."

No julgamento do REsp 617130/DF, realizado em 17 de março de 2005, a Terceira Turma do STJ considerou que a simples ocorrência de criação de obra intelectual na constância de contrato de trabalho não implica cessão de direitos autorais, o que só ocorreria mediante autorização expressa por parte do autor da obra.

Há, também, em nosso ordenamento algumas previsões legais específicas. O art. 13 da Lei 6.533/78 prevê que não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais de artistas e técnicos em espetáculos.

O art. 4º da Lei 9.609/98 prevê que, salvo estipulação contratual em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços, ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato ou vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviços ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. Trata-se de uma hipótese de cessão legal de direitos, e, portanto, de titularidade derivada.

Já o § 2º do mesmo artigo, por outro lado, prevê que pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviços ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade respectiva. A LDS também não menciona o tratamento que será dado aos casos em que não se aplique em nenhuma das duas disposições supracitadas.

6.3 OBRAS ANÔNIMAS, PSEUDÔNIMAS E PÓSTUMAS

Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais de autor. Nesses casos, contudo, não se trata de titularidade de direitos, mas de representação legal¹⁶ até que o autor revele sua identidade e opte por exercer seus direitos pessoalmente¹⁷. Revelando-se o autor a representação legal estará automaticamente extinta, ressaltando-se os direitos adquiridos por terceiros até a data da extinção.

Tratando-se de obras póstumas (as que se publicam após a morte do autor) a titularidade originária dos direitos autorais será dos herdeiros. Caso ainda não tenha se expirado o prazo de proteção e, em caso afirmativo, de quem a publicar.

Não se equiparam às obras póstumas as obras psicografadas. Nesses casos, a titularidade dos direitos autorais pertence a seu criador mediúnico e não aos familiares do suposto autor espiritual.

Nesse sentido se posicionou a 4ª Câmara do Tribunal do Distrito Federal em acórdão proferido no Agravo de Petição 7.361/1944 negando a pretensão dos familiares do escritor Humberto de Campos de ver reconhecida sua suposta titularidade sobre os direitos autorais das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier) sob os seguintes argumentos:

I) Impossibilidade de o Poder Judiciário reconhecer a sobrevivência do espírito após a morte

¹⁶ O art. 113-6 da Lei francesa traz a exata noção ao prever que os autores de obras anônimas e pseudônimas são representados no exercício de seus direitos por quem editar ou publicar a obra originariamente

¹⁷ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 62.

II) Impossibilidade de o Poder Judiciário reconhecer a aquisição de direitos autorais pelo escritor após sua morte e consequente perda da personalidade jurídica.

III) Impossibilidade de se reconhecer a transmissão de direitos a seus familiares se eles não foram adquiridos em vida pelo falecido¹⁸

6.4 CRIAÇÃO INTEGRADA

A figura da criação integrada também denominada obra por colaboração merece especial atenção. Há criação integrada quando a obra resultar da contribuição criativa sincrônica ou assincrônica de mais de um autor.

A contribuição é sincrônica quando as várias contribuições individuais objetivam a integração à obra final, como é o caso das obras coletivas, e assincrônica quando a integração se dá ocasionalmente, como é o caso da obra derivada.

Podemos elencar as seguintes espécies de criação integrada: obra derivada, obra coletiva, co-autoria, conexão de obras e obra composta¹⁹.

6.4.1 A OBRA DERIVADA

A obra derivada é aquela que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária (criação anterior). É importante distinguir-se obra originária da obra original. A originalidade da obra é pressuposto da proteção autoral. Nesse sentido, a obra derivada deve ser original para merecer proteção. A obra derivada não pode ser mera cópia da obra originária.

¹⁸ TIMPONI, Miguel. *A psicografia perante os tribunais*. Rio de Janeiro: FEB, 1959, p. 244-245

¹⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 84-85

Cumpridos esses requisitos, a titularidade dos direitos sobre a obra derivada recai sobre seu criador, apesar de ele ter-se aproveitado da essência de obra preexistente. Também a LDS prevê que os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que os fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Contudo, se a obra originária não pertencer ao domínio público, sua transformação dependerá de prévia e expressa autorização. É importante frisar que a autorização do criador da obra originária não lhe atribui a titularidade dos direitos sobre a obra derivada, que caberão a seu respectivo criador.

Nesses casos, teremos duas obras distintas, conseqüentemente, dois distintos direitos de autor: um sobre a primeira e outro sobre a segunda²⁰, razão pela qual o autor da obra derivada também não terá direito de se opor a outras transformações da obra originária, salvo se for cópia da sua ou se houver estipulação contratual em contrário lhe garantindo a exclusividade de derivação.

Figura próxima da obra derivada é a da composição de obras. Em ambos os casos não se fala em co-autoria, mas em plúriautoria, tendo-se em vista que não há colaboração criativa do autor da obra originária na criação da derivada ou composta.

Obra composta é a que incorpora obra preexistente²¹, sem alterá-la (obra derivada) e sem a colaboração de seu autor (co-autoria). Essa obra também pressupõe a observância aos direitos do autor da obra originária, pois não é mera conexão de obras, tendo-se em vista que nela há incorporação de obras, o que lhes imprime um sentido de unidade, enquanto que nesta última há mera reunião para exploração

comum, mantendo cada qual sua individualidade, nada impedindo que pudessem ter sido exploradas individualmente ou em conjunto com outras. Por exemplo, a inserção em uma obra litero-musical do texto de um poema é exemplo de obra composta.

6.4.2 A OBRA COLETIVA

Obra coletiva é a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação criativa de diferentes autores que se fundem em uma criação autônoma.

Essa fusão das várias contribuições em uma única criação autônoma e a relevância dada à atividade criativa de seu organizador lhe garantem a titularidade dos direitos sobre o conjunto da obra coletiva. Nesse caso questiona-se estar diante de titularidade originária ou derivada. Pelo princípio já exposto da autoria material parece ser a mais acertada a tese de titularidade derivada por cessão legal de direitos autorais.

Por outro lado, é importante frisar que a LDA assegura a proteção às participações individuais em obras coletivas, o que não significa co-autoria. Os criadores das participações individuais têm direitos apenas sobre suas contribuições individuais, e não sobre seu conjunto.

Ao publicar a obra coletiva o organizador deverá mencionar, em cada exemplar, a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido conveniada. Qualquer dos participantes poderá, todavia, no exercício de seus direitos morais, proibir que se indique ou anuncie seu nome. Para valer-se desse direito deverá notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação.

²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 85.

²¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 99.

6.4.3 Co-AUTORIA

Obra em co-autoria é a criada em comum, por dois ou mais autores. Tem-se, nesses casos, unidade objetiva e pluralidade subjetiva. A co-autoria pressupõe contribuição criativa razão pela qual não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Dessa forma, apesar de haver participações de terceiros na realização da obra considera-se haver um único criador²².

A obra feita em co-autoria pode ser divisível ou indivisível. Será divisível se as contribuições individuais puderem ser utilizadas separadamente e indivisível se não puderem.

A indivisibilidade pode ter origem técnica ou real. A indivisibilidade técnica decorre da Lei ou de convenção das partes. É o caso previsto no § 2º do art. 15 da LDA, que proíbe a utilização separadamente da contribuição individual se puder acarretar prejuízo à exploração da obra comum.

Verifica-se a indivisibilidade real nos casos em que a impossibilidade de utilização isolada se der pela própria natureza das contribuições individuais. Essa indivisibilidade real aparece, via de regra, na co-autoria sincrônica²³.

Sendo indivisível a obra, o prazo de proteção autoral terá por termo inicial a morte do último dos co-autores sobreviventes. Se um deles falecer sem deixar herdeiros seus direitos acrescer-se-ão aos dos co-autores sobreviventes.

A co-autoria também pode ser classificada em legal ou fática. Será legal se decorrer da própria Lei, a exemplo da obra audiovisual em que são considerados co-autores o autor do assunto ou argumento e o diretor; e de desenhos ani-

²² ASCENSÃO, José de Oliveira *Direito Autoral*, p. 91

²³ SAVATIER, René *Le droit de l'art et des lettres*, p. 103.

mados, em que são considerados co-autores os criadores dos desenhos utilizados na obra.

Questiona-se se poderia haver a figura da co-autoria convencional²⁴, decorrente da vontade do autor. Devido ao princípio da identidade subjetiva autoral (autor é a pessoa física que cria) e, tendo-se em vista que a situação subjetiva autoral não decorre da vontade do autor, mas da exteriorização da criação, parece mais acertado considerar que o exercício de sua autonomia privada, nesse sentido, caracterizaria um modo derivado de aquisição dos direitos autorais e geraria, portanto, a co-titularidade de direitos e não co-autoria em sentido material.

Vigora nos casos de co-autoria o princípio da comunhão de interesses. Isso significa que os co-autores da obra intelectual exercerão os seus direitos, de comum acordo, salvo convenção em contrário. Havendo divergência os co-autores decidirão por maioria. Ao dissidente fica assegurado o direito de não contribuir para as despesas e o de vedar que se inscreva seu nome na obra. Agindo assim, porém, estará renunciando a sua parte nos lucros.

Há, contudo, situações em que poderá ocorrer a utilização individual da obra. É permitido a qualquer co-autor, individualmente, sem aquiescência dos demais, registrar a obra, defender seus direitos contra terceiros, inseri-la na coleção de suas obras completas e, se divisível, utilizar separadamente sua contribuição individual, desde que não acarrete prejuízo à exploração da obra comum.

²⁴ Savatier referia-se à co-autoria convencional nos casos em que houvesse um contrato regulando a realização da obra comum, tendo em vista a natureza contratual do acordo firmado entre os vários colaboradores. Nesse estudo, porém, esses casos foram classificados como co-autoria fática, tendo-se em vista que o fato gerador da co-autoria não é a existência de um contrato, mas a ocorrência de criação conjunta. O que se considera aqui como co-autoria convencional é o ato de vontade translativo da qualidade de autor a quem não tenha participado do processo criativo (SAVATIER, René *Le droit de l'art et des lettres*, p. 94)

Figura que se distingue da co-autoria é a conexão de obras, apesar de a LDA não o ter feito, aplicando-lhe as disposições relativas à co-autoria divisível. Conexão de obras é a reunião de duas ou mais obras para exploração comum²⁵. Na co-autoria os vários autores reúnem esforços criativos para obter resultado comum, enquanto na conexão de obras cada qual cria obra autônoma e resolvem explorá-la conjuntamente.

Por exemplo, se um músico e um compositor reunissem esforços para criar uma obra lítero-musical, estar-se-ia diante de co-autoria. Por outro lado, se as composições de letra e música fossem feitas individualmente por cada um deles e, simplesmente, reunidas posteriormente para exploração conjunta, estar-se-ia diante de conexão de obras.

Tem-se outro exemplo bem comum no campo jurídico que é a exploração de artigos elaborados por autores diversos reunidos em uma única obra. Nesses casos está-se diante de obra coletiva ou conexão de obras, dependendo da influência do organizador no conteúdo dos artigos, mas não de co-autoria como se costuma designar. Para haver co-autoria é necessário que haja participação conjunta na elaboração de cada um dos artigos.

A distinção entre as várias espécies de criação integrada não é, porém, pacífica e depende de avaliação casuística. Um exemplo disso é o caso da ópera que já foi considerada como co-autoria, conexão de obras, obra composta e até mesmo híbrida²⁶.

²⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 98.

²⁶ MANSO, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*, p. 359.

CAPÍTULO VII

A OBRA PROTEGIDA

7.1 A CRIAÇÃO DO ESPÍRITO

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito humano. A definição da LDA se mostra confusa e, em princípio, redundante uma vez que tenta justapor as nomenclaturas francesa (criação do espírito) e italiana (criação do intelecto).

Por outro lado, pode-se considerar existir uma sutileza na definição legal: a de que tudo o que é produzido pelo intelecto humano é obra intelectual, mas nem toda obra intelectual poderia ser considerada uma criação do espírito. Logo, só receberiam a tutela autoral as obras intelectuais que puderem ser consideradas criações do espírito.

O que é produzido pelo intelecto humano é uma obra intelectual, seja decorrente de atividade meramente mecânica, seja de atividade criativa ou inventiva. Nesse conceito inclui-se uma universalidade de bens que não serão necessariamente protegidos pelo Direito e, se forem, não serão necessariamente tutelados pelo Direito Autoral. Incluem-se aí as invenções, as idéias, os documentos oficiais, as informações de uso comum e até mesmo as obras plagiadas que podem conter certo trabalho mental.

A questão não denotava grandes esforços nas origens do Direito Autoral em que se tutelava eminentemente as obras artísticas e o trabalho se resumia a verificar se a obra em questão preenchia ou não os requisitos da proteção legal. Ocorre que, a proteção legal foi gradativamente estendendo-se, primeiro às obras literárias, depois às científicas, arquitetônicas, multimídias, programas de computador, bases de dados, etc.¹ Enfim, pode-se dizer que a obra intelectual é protegida independente do gênero a que pertença.

As obras protegidas são reunidas na LDA em três categorias básicas: as obras literárias, artísticas e científicas. É lógico que há um grande número de obras que possuem características de mais de uma dessas categorias fundamentais. Nesses casos, a classificação pode-se dar mediante a inclusão da obra na categoria que mais se aproximar de sua natureza ou finalidade, ou, segundo Algardi², poderiam ser incluídas em uma categoria mista.

Nesse sentido, a LDA busca elencar as obras que se consideram protegidas e as que não são. É lógico que o elenco deve ser meramente exemplificativo, tendo-se em vista a grande variedade de gêneros de obras e a multiplicidade de obras em cada gênero³, bem como a constante evolução tecnológica que gera novas espécies de obras.

Em nosso Direito, não há mais dúvidas, tendo-se em vista a redação dada pela LDA ao art. 7º *caput*, o que não ocorre em outros ordenamentos, a exemplo do italiano, em que ainda se discute o caráter exemplificativo ou taxativo do elenco⁴.

¹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 357.

² ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 560.

³ DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 15.

⁴ SANTILLI, Marina. *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, p. 182.

Assim, são exemplos de obras protegidas:

- textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- obras dramáticas e dramático-musicais;
- composições musicais e lítero-musicais;
- obras audiovisuais e cinematográficas, sonorizadas ou não;
- obras fotográficas;
- desenhos, ilustrações, pinturas, gravuras, esculturas, litografias e arte cinética;
- cartas geográficas;
- projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. A LDA adota posição polêmica de proteger os projetos científicos⁵. É de se ressaltar que os projetos matemáticos ficam excluídos da proteção, como será visto adiante.
- adaptações, traduções e outras informações de obras originais, desde que apresentadas como criação intelectual nova;
- cópia de obra de artes plásticas feita pelo próprio autor;
- títulos de publicações periódicas. Nesses casos, a proteção será de até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.
- programas de computador, cuja tutela observa lei específica (9.809/98);
- coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que por

⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 38/39.

sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo constituam uma criação intelectual.

Por outro lado, não são objeto de proteção como direitos autorais:

- As idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais. A proteção de idéias é antagônica à própria finalidade do Direito Autoral que é o estímulo à criação de obras. Além disso, mostra-se como obstáculo à individualidade criativa que possibilita uma quantidade inesgotável de obras sobre um único tema ou uma única idéia. A título exemplificativo tem-se que as obras dramáticas baseiam-se em trinta e seis situações dramáticas básicas. Nesses casos, se a proteção recaísse sobre a idéia e não apenas sobre sua forma de exteriorização, estar-se-ia criando um monopólio da arte e não da obra⁶. Recomenda-se, contudo, que a previsão legal seja interpretada extensivamente a outros elementos que possam ser encontrados nas obras intelectuais como o tema, o estilo literário, o vocabulário, a forma literária, a técnica artística, etc.⁷
- Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. A idéia para a ação não é objeto da tutela autoral. Assim fundamentando, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em acórdão proferido na Apelação Cível 5.731/95 de 17 de abril de 1996, rejeitou a acusação de que o programa “Você Decide” fosse plágio do programa “O povo é o Juiz”⁸.

⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 63

⁷ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 63.

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 29

- Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções.
- Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais.
- As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Trata-se de aplicação mecânica de informações de uso comum. Considera-se, assim, não haver criatividade quando há apenas uma única via para manifestação da idéia⁹.
- Os nomes e títulos isolados. Ao contrário da legislação francesa que considera o título uma obra intelectual autônoma merecedora da mesma proteção dada à obra em si¹⁰.
- O aproveitamento prático das idéias contidas nas obras, o que significa que o autor nada pode fazer se um terceiro colocar em práticas as idéias que defende ou revele em sua obra, a não ser que a mantenha inédita. Nem mesmo se esse aproveitamento se der de forma industrial ou comercial. Por exemplo, um advogado pode lançar uma obra sobre como triunfar na advocacia e pode se opor a qualquer contrafação da obra em que expõe suas teorias, mas não pode impedir que com as técnicas ali defendidas, os leitores obtenham o êxito propalado. A título ilustrativo tem-se cena do filme *O carteiro e o poeta*, em que o carteiro se utiliza de uma poesia do outro para seduzir a amada. O aproveitamento prático das idéias escapa à tutela autoral¹¹.

⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 39.

¹⁰ Art. L. 112-4.

¹¹ É lógico que, presentes os requisitos exigidos pela LPI, pode-se obter a exclusividade do aproveitamento industrial das idéias contidas nas obras, conforme previsto no art. 41 e seguintes da LPI.

É importante frisar que a ausência de tutela autoral não importa ausência de tutela legal, haja vista que a proteção poderá ocorrer em outro sistema legal, como é o caso da propriedade industrial, da proteção aos direitos da personalidade, etc. O § 3º do art. 7º da LDA prevê especificamente que no domínio das ciências a proteção recai exclusivamente sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

Por outro lado, tem-se que, mesmo as obras intelectuais elencadas, só se beneficiarão da tutela autoral se puderem ser consideradas criações do espírito. Para tanto é necessário que preencham alguns requisitos:

- a) criatividade;
- b) comunicatividade;
- c) exteriorização.

7.1.1 CRIATIVIDADE

O requisito da criatividade não é exigido de forma direta¹² na LDA, mas indiretamente pode-se verificar sua exigência. Por exemplo, quando a LDA prevê que a obra derivada para ser tutelada deve consistir em criação intelectual nova, ou que as obras intelectuais protegidas são as criações do espírito, ou que as bases de dados ou obras afins só recebem a proteção se forem criação intelectual, está-se claramente recepcionando a criatividade como pressuposto da tutela autoral.

É justamente no caráter criativo da obra que reside a justificativa da tutela autoral¹³. Como visto anteriormente,

a tutela autoral não se propõe a premiar o simples esforço mental, o ato mecânico de transposição de informações comuns. Se assim fosse, estaria simplesmente a serviço de interesses econômicos e seria nada mais que remuneração por um trabalho ou serviço prestado¹⁴. Para que a obra seja merecedora da tutela autoral não basta transpiração, é necessário um mínimo de inspiração.

Apesar do conceito não ser novo e desde a origem do Direito Autoral ser pacífica a idéia de que um mínimo de criatividade é indispensável não só à sua proteção, mas à sua própria constituição¹⁵, a dificuldade de se fixar um *quantum* criativo mínimo fez com que gradualmente o conceito de criatividade tenha-se tornado cada vez mais objetivo.

Inicialmente a noção de criatividade assemelhava-se à idéia de genialidade. A proteção autoral vinha concebida como um prêmio àqueles poucos detentores de uma espécie de dom transcendental que os fazia sobressair perante os demais, já que *spiritus ubi vult spirat*.

Como o domínio privado não poderia deixar de ser visto como um obstáculo ao acesso coletivo à criação intelectual, a atribuição de um direito subjetivo autoral a seu criador deveria justificar-se na medida de sua inspiração. Segundo Savatier¹⁶, a inspiração é a ocasião do gênio, daí sua volatilidade¹⁷.

O critério mostrou-se, porém, inaplicável haja vista que, invariavelmente, gerava discussões sobre o mérito da obra ou seu caráter estético¹⁸, questões atualmente consideradas

¹⁴ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 21.

¹⁵ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 375.

¹⁶ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 18.

¹⁷ "Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer eserever. No entanto ele está cá dentro, inquieto, vivo. . . e não quer sair" (ANDRADE, Carlos Drummond de. *Sentimento do mundo*. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 47).

¹⁸ A medida da obra pelo seu grau estético, além de ser relativa na maioria dos casos, mostra-se inviável naqueles em que a finalidade do artista é

¹² A Lei italiana (art. 1º) prevê expressamente a necessidade de a obra possuir caráter criativo para ser merecedora da tutela autoral.

¹³ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 373.

alheias ao Direito Autoral¹⁹. A tutela autoral não pode servir de instrumento de elitização cultural ou científica. A valoração do mérito da obra, ou de seu caráter estético podê-se dar no campo científico, cultural ou comercial, jamais no campo do Direito.

A objetivação do critério de concessão da tutela legal não tem o condão de gerar a banalização das artes ou da ciência, conforme muito apregoado, mas a finalidade de democratizar o acesso à proteção legal.

Passou-se, assim, a concebê-lo não mais como a expressão da genialidade, mas como a expressão da individualidade do autor. Assim, a proteção autoral prescinde do valor artístico ou cultural da obra e pressupõe, simplesmente, que a ela constitua forma de expressão original de seu autor, que haja identidade entre autor e obra.

Mesmo assim, o conceito de individualidade permaneceu carregado de subjetivismo exigindo-se que a marca de seu autor devesse estar impressa na obra para que essa fosse merecedora da proteção autoral. Nesse sentido, o conceito de individualidade confunde-se com o de personalidade, exigindo-se o reconhecimento da personalidade do autor na obra.

Esse subjetivismo conceitual é facilmente aplicável a algumas espécies de obras ou a alguns autores que possuem estilos marcantes como *Van Gogh* e *Dalí* ou *Picasso*, mas torna-se mais difícil aplicá-la a autores com estilos menos perceptíveis. Além disso, em algumas espécies de obras, pela digitalização ou codificação a elas inerente, é praticamente impossível aplicá-lo, a exemplo dos programas de computador e das bases de dados.

A defesa do subjetivismo conceitual baseia-se na idéia de que a finalidade do Direito Autoral seria premiar a cria-

tividade e não meramente reprimir a imitação²⁰. Sob o paradigma do Estado de Direito, porém, não parece coerente afirmar-se que a finalidade da atribuição do direito subjetivo possa ser simplesmente premiar seu titular. Fim do Direito Autoral é o desenvolvimento artístico, cultural e científico coletivo. Como negar a proteção a um trabalho científico, mesmo que não traduza a personalidade de seu autor, ou negar proteção a um autor que navegue por vários estilos ou a outro que pretenda ocultar-se. Não se pode negar, ainda, que a repressão à imitação é expressão da função econômica do Direito Autoral e faz parte de seu conteúdo.

É certo que o Direito Autoral foi inicialmente concebido de forma subjetiva o que justificou a concessão de uma proteção tão ampla. Porém, os avanços tecnológicos aliados aos fenômenos de ampliação e migração de obras protegidas exigem a releitura de seus institutos. A defesa da manutenção da tutela clássica ao novo objeto não passa de retórica reacionária. A amplitude da proteção autoral e a rigidez da dicotomia da propriedade intelectual, essas, sim, merecem reflexão.

Apesar dessa evolução ser considerada por alguns como um movimento de banalização do Direito Autoral²¹, parece mais acertada a aferição da criatividade não pelo grau de atividade intelectual do autor, mas pelo resultado alcançado. Se ele criou uma obra original o requisito da criatividade foi preenchido. O fenômeno talvez não seja de banalização, mas de deselitização.

Essa objetividade conceitual é garantia de igualdade e evita discriminações e arbitrariedades, excluindo, definitivamente do conceito de criatividade elementos como mérito, caráter estético ou destinação. Não é atribuição do Direito,

justamente a representação do feio (ECO, Umberto. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 131)

¹⁹ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 21

²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 52

²¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 51

do legislador e nem mesmo de seus aplicadores ou operadores definir o valor subjetivo da obra. Seu valor cultural é dado pela sociedade e seu valor financeiro pelo mercado. Ao Direito resta fazer uma valoração objetiva de originalidade, a fim de se evitar violações da Lei ou de direitos de terceiros²², e a utilização indevida de obras preexistentes²³ ou de conhecimentos de uso comum. Caso contrário abrem-se as portas à censura camuflada e à violação do direito de informação e da liberdade de expressão²⁴.

Assim, o conceito de criatividade é mais bem entendido como a paternidade de obra original. Autor é aquele que cria obra original. Nesse sentido, o atendimento ao requisito verifica-se não por uma aferição subjetiva da quantidade ou valor da inspiração do autor, mas por uma aferição objetiva do nexo causal, ou seja, da relação de causa e efeito entre o ato criativo e a obra criada.

Não se pode deixar de observar que a objetividade conceitual, ao mesmo passo que amplia a possibilidade de obtenção da tutela a limita, no sentido de que aumenta a pro-

²² Mesmo nesses casos ainda polemiza-se se a obra poderia ser objeto de censura prévia ou se se caracterizaria violação do princípio da livre manifestação do pensamento, cabendo ao lesado apenas a possibilidade de pleitear perdas e danos. Tratando-se de violação a direitos da personalidade é de se questionar se restariam subjugados ao princípio de manifestação do pensamento. As duas posições, vencedora e vencida, respectivamente, encontram-se no acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais no Agravo de Instrumento 0223100-7/00 de 27 de novembro de 1996.

²³ É o caso de pirataria, plágio ou mesmo de violação do direito exclusivo de edição, como no caso da família Shurmann que foi impedida de lançar novo relato da viagem marítima por ela empreendida antes de expirado o contrato com a editora Primigena. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 12.936 da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 16 de fevereiro de 1998.

²⁴ CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. *Direito de informação e liberdade de expressão*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 20.

babilidade de ocorrerem coincidências fortuitas na criação²⁵. Quanto menor o grau de subjetivismo exigido, maior a possibilidade de proteção de obras semelhantes.

A questão se mostra mais complexa se considerada a possibilidade de ocorrência fortuita de obras idênticas a outras preexistentes. Quando se trata de obra idêntica, é difícil de se pensar em proteção a todos os autores que a tenham criado, isoladamente, já que a obra é uma só²⁶.

Nesse ponto as opiniões são divergentes. Há os negativistas²⁷ que negam a possibilidade de haver coincidência fortuita na criação, para quem a utilização da obra coincidente configuraria violação aos direitos autorais do autor da obra originária; os objetivistas²⁸ que alegam que autor seria o primeiro a publicar ou divulgar a obra, para quem a coincidência poderia ser vista simplesmente como excludente de antijuridicidade da utilização inadvertida da obra coincidente; e os subjetivistas que admitem a atribuição de direitos autorais autônomos aos criadores de ambas.

Esta última, mais coerente com a concepção objetiva da criatividade visto que, no caso, haverá dois atos criativos distintos ligando-se às obras, apesar de serem idênticas. Nesse sentido, a criatividade assume um sentido subjetivo e outro objetivo²⁹. Subjetivamente, traduz a criatividade do autor. Objetivamente, a originalidade da obra.

²⁵ A LDS já se antecipou prevendo que não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para sua expressão (art. 6º, inciso III).

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 64.

²⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 63.

²⁸ LUCCHESI, Franco Voltaggio. *I beni immateriali*, p. 97.

²⁹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 50.

O sentido objetivo seria conexo ao subjetivo, ou seja, no sentido de que a verificação de originalidade da obra teria o caráter instrumental de se verificar a ocorrência do ato criativo, verdadeira causa de atribuição do Direito Autoral. Assim, comprovada a ocorrência do ato criativo e a coincidência fortuita não há porque não se conferir a tutela autoral.

É importante frisar, ainda, que a criatividade só toma relevância jurídica no momento em que é exteriorizada. Assim como a vontade humana³⁰, enquanto permanecer no íntimo do autor, não produz efeitos jurídicos. É por essa razão que a verificação da criatividade do autor se dá pela constatação da originalidade da obra.

Obra original é a criação única, aquela que se individualiza pela ação intelectual de seu criador. A obra é original se contém a visão de seu autor sobre seu objeto³¹ ou, em outras palavras, se o autor contrapôs seu pensamento à realidade. Dessa feita, a obra não será original se:

- for cópia de obra preexistente;
- consistir exclusivamente em informações de uso comum;
- representar modo de expressão vinculado;
- tratar-se de tradução ou descrição servil da realidade.

Alguns autores fazem distinção entre originalidade absoluta e relativa. A originalidade é absoluta quando a obra não deriva de outra preexistente. A originalidade é relativa quando a obra é criada a partir de outra preexistente³².

É lógico que a idéia de originalidade absoluta deve ser vista de modo flexibilizado. Originalidade absoluta não significa que o autor tenha que criar algo do nada. A inspiração

³⁰ AMARAL, Francisco. *Direito Civil*. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 381.

³¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 51.

³² COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*, p. 28.

do autor muito dificilmente estará livre de toda influência alheia.³³ Quintana³⁴ ilustra bem a idéia ao fazer referência às obras que haviam inspirado cada um de seus poemas afirmando que a ausência de referência em alguns não significa que estariam isentos de inspiração, mas que não lhe fora possível, até aquele momento, identificá-la.

Segundo Carnelutti³⁵, a construção do saber científico também passa pelas fases de intuição e imitação. Criar é transformar a realidade. Ninguém parte do nada. O mundo cultural inspira, condiciona e promove qualquer criação intelectual, seja em maior ou menor grau³⁶. Segundo Pêrsio³⁷, nada vem do nada.

É importante distinguir a originalidade, requisito de concessão da tutela autoral, com a novidade, requisito de concessão da tutela da propriedade industrial. Diferentemente do Direito Autoral, na propriedade industrial a tutela jurídica pressupõe um salto inventivo. Só se beneficiam da tutela as invenções e modelos de utilidade considerados novos, ou seja, não compreendidos no estado da técnica.

Considera-se estado da técnica todo o conhecimento técnico-científico tornado acessível ao público até 12 meses antes da data de reivindicação da patente ou prioridade³⁸. Em outras palavras, a tutela da propriedade industrial pressupõe o mérito da invenção ou modelo de utilidade, diversamente da tutela autoral, em que recebem igual proteção legal, por exemplo, tanto a obra científica inovadora como a débil.

³³ LIŚSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 67.

³⁴ QUINTANA, Mario. *Apontamentos de história sobrenatural*. São Paulo: Globo, 1987, p. 312.

³⁵ CARNELUTTI, Francesco. *Metodologia do direito*. Campinas: Bookseller, 2002, p. 20.

³⁶ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 138.

³⁷ RÓNAL, Paulo. *Não perca o seu latim*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 64.

³⁸ Hermenêutica dos arts. 11 e 12 do Código de Propriedade Industrial.

7.1.2 COMUNICATIVIDADE

A atribuição do Direito Autoral tem por finalidade o desenvolvimento científico-cultural da sociedade. O estímulo à criação pela proteção do direito subjetivo autoral é, assim, instrumento de consecução dessa finalidade.³⁹

Como a criação do espírito é elemento da fenomenologia científico-cultural e como essa se desenvolve pela ação comunicativa³⁹, pode-se deduzir que a tutela autoral visa proteger as criações dotadas de um caráter intelectual reflexivo, isto é, geradas pelo intelecto humano e por ele captáveis.

Assim excluem-se da proteção aquelas obras que apesar de captáveis pelo intelecto humano não tenham sido por ele criadas, ainda que de forma mediata, bem como aquelas que apesar de criadas pelo intelecto humano não se orientem para a compreensão.

Segundo Ascensão⁴⁰, só é relevante para o Direito Autoral a obra humana, criada e captável pelo intelecto humano.

Assim, a gênese do Direito Autoral pressupõe um fato humano. Fato natural não gera situação jurídica autoral. Dessa forma, as obras criadas pela natureza ou pelo acaso não são merecedoras da proteção autoral. O que não significa que não seja possível que essas obras possuam um valor econômico. Nesses casos, todavia, apesar de não se poder falar em Direito Autoral haja vista a inexistência da criação (fato gerador), pode-se estar diante do elemento objetivo de outras espécies de relações jurídicas (reais e creditícias).

Apesar de a LDA não ter a finalidade exclusiva de proteger o autor, haja vista que em grande número de casos os direitos autorais estarão a serviço de titular derivado, isso

³⁹ HABERMAS, Jürgen. *Théorie de l'agir communicationnel*. Paris: Fayard, 1987, p. 111-112.

⁴⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 27.

não significa que, em nosso Direito, se possa prescindir do ato criativo como pressuposto de atribuição da tutela, como no sistema de *copyright* em que o pressuposto da proteção legal é simplesmente a possibilidade de comercialização da obra: o que pode ser copiado deve ser protegido.

A necessidade de ocorrência do ato criativo não significa, contudo, que ele deva ser voluntário ou consciente, isto é, que o autor tenha a intenção de criar uma obra intelectual ou mesmo que saiba estar fazendo-o⁴¹. Apesar de haver dissenso, parece mais acertada a posição de se reconhecer a proteção às criações do espírito humano mesmo que fortuitas, involuntárias ou inconscientes⁴².

Por outro lado, é necessário que a obra seja instrumento de intercomunicação. Não basta que ela seja criada pelo ser humano. É necessário que seja também criada para ele. É nesse ponto que se baseou a separação tradicional da tutela da propriedade intelectual em Direito Autoral e Propriedade Industrial. Naquela busca-se a proteção das obras destinadas à promoção da intercomunicação humana e nesta a proteção das obras intelectuais que visem a satisfação de interesses materiais humanos.

Essa separação, porém, em um breve período de tempo se mostrou simples proposição teórica. Na prática observou-se um fenômeno de migração de obras da propriedade industrial para a tutela autoral, tendo-se em vista a amplitude da tutela e a informalidade de sua aquisição.

Dessa feita, a destinação da obra (se ao mundo da cultura ou da indústria) não pode mais ser considerada como excludente da proteção autoral⁴³. O que não significa que o

⁴¹ "A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse" (ANDRADE, Carlos Drummond de. *Sentimento do mundo*, p. 37).

⁴² DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 20.

⁴³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, p. 56.

requisito da comunicatividade não seja exigido para a concessão da tutela autoral. Pode-se dizer, por outro lado, que a comunicatividade pode ser direta ou indireta.

Em alguns casos, a exemplo das obras artísticas e literárias, essa comunicatividade é direta, tendo-se em vista que a obra destina-se diretamente à sensibilização ou à transmissão de conhecimentos. Em outros casos, a exemplo de obras científicas, geográficas e topográficas, essa comunicatividade é indireta, ainda que a obra se destine à satisfação de algum interesse de ordem prática não se pode negar que também exerça importante função no desenvolvimento cultural.

Em outras palavras, não significa que a obra contenha simplesmente um valor expressivo. A obra protegida pode ter também um valor útil. O que se exige é que a obra útil tenha também um valor expressivo para merecer a proteção autoral. Não se exige, assim, que ela se destine exclusivamente à comunicação, mas que ela tenha aptidão para tanto, que possa ser usada para tal fim⁴⁴.

7.1.3 EXTERIORIZAÇÃO

A exteriorização da criação do espírito é o fato gerador da tutela autoral. Enquanto a criação permanecer no íntimo do autor, não receberá proteção. É lógico que a exteriorização da criação é apenas a foz do processo criativo, mas é nesse momento que o pensamento se transmuda em obra de forma concreta, deixando de ser mera cogitação e atingindo a existência jurídica⁴⁵.

⁴⁴ SANTILLI, Marina. *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, p. 203.

⁴⁵ CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*. São Paulo: Saraiva, 1942, p. 402.

Na fase íntima do processo criativo, a obra não passa de um prelúdio⁴⁶. Para melhor compreensão, observa-se nesse caso o mesmo critério lógico da teoria natalista da personalidade e da teoria da declaração do negócio jurídico.

A Lei não exige forma específica para a exteriorização da criação do espírito, mas é importante ressaltar que a exteriorização deve-se dar de alguma forma, empregando-se o termo em sua acepção *lata*, enquanto aspecto da realidade que se revela⁴⁷.

Parte-se, assim, da idéia de que a nascente do processo criativo é a percepção da realidade pelo pensamento, o que se dá por meio dos sentidos humanos que são limitados e incapazes de apreender a realidade em sua integralidade. Segundo a lição de Carnelutti, nossos sentidos são "porta estreita na qual a natureza não penetra senão pouco a pouco. Estou tentado a dizer que nós vemos por fragmentos"⁴⁸.

Como na fotografia que, apesar de ser uma forma de expressão da realidade, estará sempre aquém da realidade retratada⁴⁹. Daí a necessidade de se reconhecer essa limitação de sentidos⁵⁰ para se fazer a distinção entre a forma e o conteúdo da criação.

A proteção autoral não incide sobre o conteúdo da criação, mas sobre sua forma. O processo criativo pode ser dividido, a grosso modo, nas seguintes fases⁵¹, não necessariamente nesta ordem, nem claramente separadas:

⁴⁶ SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*, p. 20.

⁴⁷ CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*, p. 21.

⁴⁸ CARNELUTTI, Francesco. *Metodologia do direito*, p. 51.

⁴⁹ CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*, p. 21.

⁵⁰ Limitação essa que a tecnologia busca constantemente atenuar como se pode verificar por inúmeras invenções como: o estetoscópio, o sonar, o microscópio, o telescópio, aparelhos de ultra-sonografia, tomografia, radiografia, *gps*, etc.

⁵¹ Debois se refere a apenas três fases: idéia, elaboração e exteriorização. A adoção neste trabalho da separação em quatro fases justificar-se-á mais adiante (DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*, p. 92).

- a) Fase de percepção: fase inicial em que os sentidos captam algum aspecto da realidade física ou psíquica.
- b) Fase de intuição ou inspiração: fase em que o autor reage intelectualmente ao estímulo contrapondo-lhe seu pensamento⁵².
- c) Fase de trabalho intelectual: fase em que o autor busca a utilização da técnica para expressar seu pensamento.
- d) Fase de exteriorização da criação: fase em que o autor manifesta seu pensamento de forma sensível (linguagem, imagem, etc.)⁵³.

O Direito Autoral surge apenas nesta última fase, pois se destina à proteção dessa forma representativa da idéia. Só está protegida a forma sensível de manifestação da idéia, e não a idéia em si⁵⁴. No tocante à proteção autoral, a idéia é refém da forma com que se reveste⁵⁵.

Várias são as razões que impedem que a tutela autoral incida sobre as idéias contidas nas obras:

- a) o Direito Autoral tem como uma de suas finalidades o estímulo à criação. A proteção da idéia obstaculizaria a consecução dessa finalidade, uma vez que o monopólio da idéia impediria a criação de novas obras originais partindo desse mesmo substrato intelectual⁵⁶;
- b) a realidade escapa ao Direito. O objeto do Direito será sempre uma porção de realidade delimitada no espaço, no tempo e na forma⁵⁷. Do mesmo jeito a idéia, enquanto realidade psíquica, escapa-lhe, ca-

⁵² Essas duas primeiras fases integram o ciclo criativo.

⁵³ As duas últimas fases integram o ciclo técnico ou instrumental.

⁵⁴ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 62.

⁵⁵ Ou de que se investe

⁵⁶ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 63.

⁵⁷ CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*, p. 26.

bendo ao Direito tutelar a forma de exteriorização da idéia (porção de realidade);

- c) é requisito de concessão da tutela autoral a comunicatividade. Assim, se a idéia não for representada de forma sensível, captável pelos sentidos humanos, não há proteção;
- d) o Direito Autoral tem como uma de suas finalidades o desenvolvimento cultural. A criação de um direito exclusivo sobre as idéias impediria que a sociedade aproveitasse as idéias contidas nas obras. Sua apropriação significaria a privatização da cultura. A finalidade do Direito Autoral é assegurar direitos subjetivos sobre a obra e não sobre a cultura.

Vê-se, portanto, que, para o Direito Autoral, as idéias são de domínio público: "qualquer idéia que te agrada, [...] é tua"⁵⁸. O que não significa que as idéias sejam despidas de qualquer proteção jurídica. Dentre os crimes de concorrência desleal há aqueles que se configuram justamente pela apropriação fraudulenta, utilização, exploração ou divulgação não autorizada de idéias alheias⁵⁹.

Essa busca pelo monopólio das idéias também não é recente como demonstra o seguinte excerto de lei editada pela República de Veneza, em 1454, que assim previa:

Se um trabalhador levar para outro país qualquer arte ou ofício em detrimento da República, receberá ordem de regressar; se desobedecer, seus parentes mais próximos serão presos, a fim de que a solidariedade familiar o convença a regressar; se persistir na desobediência, serão tomadas medidas secretas para matá-lo, onde quer que esteja⁶⁰.

⁵⁸ QUINTANA, Mario. *Apontamentos de história sobrenatural*, p. 291.

⁵⁹ Art. 195, incisos XI e XII, da LPI.

⁶⁰ HUBERMAN, Leo. *História da riqueza do homem*. Rio de Janeiro: Zahar, 1984, p. 67.

Questiona-se, por outro lado, se a proteção autoral incidiria exclusivamente sobre a superfície da forma de representação da idéia ou se atingiria, de certa forma, seu conteúdo. É a distinção que se faz entre forma interna e forma externa. A forma interna seria a composição ou estrutura da obra⁶¹.

Adotando essa posição estar-se-ia admitindo que a proteção autoral não se restringe à superfície da forma, mas tende a estender-se também à proteção do trabalho intelectual do autor⁶².

O trabalho intelectual do autor não basta para a concessão da tutela autoral, tendo em vista que a exteriorização da criação é condição essencial para dela beneficiar-se, mas, uma vez alcançada, proteger-se-ia também seu trabalho intelectual. A estrutura interna da obra (não a idéia propulsora) também estaria protegida. Mais uma vez é de se recorrer à analogia à teoria natalista da aquisição da personalidade. O nascimento com vida é condição para a aquisição da personalidade, mas uma vez adquirida, a Lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Dessa feita, a tutela autoral não seria simplesmente uma tutela da obra intelectual, mas também tutela do trabalho intelectual do autor.

A idéia de proteção da forma interna parece, porém, recair no mesmo equívoco das teorias subjetivas da criatividade. Não há como tutelar a realidade psíquica do autor ou a integralidade de seu trabalho intelectual, mas apenas na medida de sua exteriorização. Cabe ao Direito apenas a tutela do trabalho intelectual do autor exteriorizado na obra.

Daí a necessidade da proteção autoral restringir-se à forma de exteriorização. É lógico, contudo, que a proteção da forma abrange a estrutura palpável da obra (externa). Buscasse, assim, evitar a recaída no obscurantismo do subjetivismo

⁶¹ ASCENSÃO, José de Oliveira *Direito Autoral*, p. 34.

⁶² Referência à terceira fase do processo criativo já explanada.

autoral. Reconhecer a existência de uma forma interna é reconhecer a tutela do conteúdo da obra o que redundaria na proteção da idéia ou do pensamento do autor.

7.1.3.1 Plágio

Na defesa da forma interna utiliza-se o fato de que a violação de direitos autorais não se caracteriza apenas com a cópia servil da obra (usurpação), como também com o plágio, situação em que a obra original é retocada para parecer outra⁶³. A forma externa não é reproduzida, mas a interna teria sido.

Isso porque o termo plágio foi inicialmente empregado em Direito Autoral como sinônimo de furto intelectual, apropriação de obras ou de idéias alheias. Nesse sentido, o termo não caracteriza, necessariamente, um ilícito autoral, uma vez que as idéias nem são objeto da proteção autoral. Pode haver a apropriação de todos os conceitos de uma obra, reproduzindo-se o pensamento ou as sensações do autor ali exteriorizadas sem cometer-se plágio algum (paráfrases e paródias)⁶⁴.

A caracterização do plágio não parece ser bem definida com o recurso à reprodução da forma interna. Ao contrário, o plágio caracteriza-se como contrafação de direitos autorais justamente pelo fato de ocorrer a modificação da forma externa da obra sem a autorização prévia do autor.

Há opiniões⁶⁵ no sentido de que o plágio se caracterizaria simplesmente pela modificação não autorizada da forma externa de obra preexistente. O melhor entendimento, porém, parece ser o de que o plágio se diferencie das demais espécies de modificação não autorizadas de obras preexis-

⁶³ ASCENSÃO, José de Oliveira *Direito Autoral*, p. 34.

⁶⁴ ALGARDI, Zara *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 193-194.

⁶⁵ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 145.

tentes, pelo fato de que a atividade do plagiário não constitui, necessariamente, criação intelectual nova. Há espécies de modificação de obras (autorizadas) em que se verifica a existência de criação intelectual nova.

Há, ainda, situações em que a obra derivada recebe a proteção legal independentemente de autorização do autor da obra originária, como é o caso das paráfrases e paródias, o que não ocorreria no caso de plágio, visto faltar-lhe elemento essencial da tutela, a criatividade.

Segundo Algardi⁶⁶, no plágio pode-se identificar mera simulação de criatividade. O plagiário simula uma nova criação intelectual, e é justamente essa tentativa de simulação, atividade voluntária ou consciente, que distingue o plágio de outras figuras, como a abstenção ou a falsa menção de autoria em que se poderia constatar a boa-fé do agente.

Nesse ponto, fica a lição de De Sanctis⁶⁷ que caracteriza o plágio como a elaboração abusiva de obra ou o abuso do direito de elaboração de obras, cujo uso seria um desmembramento do direito à livre manifestação do pensamento. O direito de elaboração de obras compreende a faculdade do autor de se inspirar em obras preexistentes. O plágio, por outro lado, constituiria mera utilização de obra preexistente.

Portanto, haverá plágio quando houver a apropriação ilícita e dissimulada da individualidade de obra preexistente. É sempre bom ressaltar que há casos de apropriação lícita da individualidade de obra preexistente, como as paráfrases e paródias, citações, reproduções parciais, etc.

A licitude de tais ações ampara-se no princípio constitucional da livre manifestação do pensamento que garante a liberdade do debate científico-cultural. Nesses casos, a lici-

⁶⁶ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 213

⁶⁷ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 143-144

tude está no fato de que a apropriação da individualidade da obra preexistente não é fim em si mesma, mas, instrumento de exercício do direito de crítica⁶⁸.

A apropriação pode ser total ou parcial. O melhor entendimento é, contudo, no sentido de que o plágio parcial só é relevante juridicamente, se ocorrer a apropriação de um conjunto considerável de elementos da obra preexistente. O Direito não pode impedir a utilização de elementos singulares de obra preexistente⁶⁹.

O plágio não se configura pela simples coincidência de elementos entre duas obras, mas pela identidade criativa entre ambas. Há a possibilidade de haver coincidências fortuitas na criação, que se distinguem do plágio, justamente por não constituírem em ato de elaboração abusiva de obra⁷⁰.

7.1.3.2 Obra e exemplar

É importante ressaltar que a exteriorização não se restringe à idéia de divulgação da obra, que pode ser exteriorizada sem ser divulgada, nem à idéia de fixação da obra, uma vez que há obras que se exteriorizam sem ser, necessariamente, fixadas. Daí poder-se dizer que a proteção autoral incide sobre a obra em si e não sobre o exemplar.

Não se trata de dizer que a obra intelectual seja um bem puramente incorpóreo, que não possua corpo, mas de dizer que ela não tem que ter, necessariamente, um corpo material. Ocorre que, para receber a tutela legal a obra intelectual deve possuir, ao menos, um corpo imaterial (abstração formal), no sentido de que a idéia deve tomar forma para ser protegida.

⁶⁸ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 157

⁶⁹ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 337

⁷⁰ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 437

Vale dizer que inicialmente considerou-se que o objeto da proteção autoral seria o suposto corpo físico da obra, ou seja, o exemplar. Talvez pela dificuldade de se verificar, àquela época, a possibilidade de separação do corpo material do corpo imaterial da obra. A migração da proteção legal do corpo material para o corpo imaterial só iniciou-se após a invenção da imprensa, que possibilitou a sua multiplicação em exemplares e criou a necessidade de se compreendê-la como objeto distinto do suporte em que é fixada.⁷¹ Assim, as teorias materialistas cedem vez às teorias mistas que concebem a obra enquanto abstração formal fixada em um suporte material.

Essas teorias mistas defenderam a posição de que a obra intelectual é um conjunto composto por um corpo mecânico (material) e por um corpo místico (imaterial). Corpo místico seria a abstração formal, e corpo mecânico o suporte material em que a obra é exteriorizada.

Essas teorias preconizavam, contudo, a indissociabilidade entre o corpo mecânico e o corpo místico da obra, uma vez que a realidade da obra intelectual (materialidade e imaterialidade) deveria ser vista em sua unidade orgânica.⁷²

Essas teorias mistas cederam vez às chamadas teorias imaterialistas. Para as teorias imaterialistas, a obra seria a abstração intelectual formal. O corpo mecânico não seria elemento essencial da obra intelectual, mas instrumento de sua representação, circulação e distribuição, que teria existência e seria identificável independentemente de seu suporte.⁷³ O corpo mecânico, enquanto instrumento de representação da obra, é condicionado pelo avanço tecnológico. Quanto mais

⁷¹ CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*, p. 237.

⁷² ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 26.

⁷³ ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, p. 28.

limitada a tecnologia, mais limitada é a forma de representação da criação do espírito. A tecnologia digital proporcionou a separação da obra do suporte que tradicionalmente a receberia. A representatividade da obra não se limita mais a um corpo mecânico específico.⁷⁴

Sem o auxílio das teorias imaterialistas não se poderia explicar algumas situações que a realidade digital evidencia, são elas:

- a multiplicação da obra em vários exemplares não retira sua identidade;
- uma única obra pode ser exteriorizada em suportes materiais diversos;
- a obra pode ser fixada em suportes digitais intangíveis;
- qualquer espécie de obra pode ser representada por uma combinação digital o que favorece sua transformação, multiplicação e propicia sua fixação em suportes variados.
- a proteção autoral independe da fixação da obra em um suporte material;
- pode-se verificar a ocorrência de plágio mesmo em relação aos gêneros diversos que se utilizam de suportes materiais distintos (obra literária e obra cinematográfica).

Essa evolução não está, contudo, acabada. Enquanto no aspecto técnico, a obra desvinculou-se de seu suporte, teoricamente o Direito Autoral ainda se mantém atrelado à concepção material que o inspirara inicialmente. A licença de uso da obra é muitas vezes considerada, até mesmo pelo legislador, como mera licença de uso do exemplar, fazendo do usuário seu refém. Se se perder ou se deteriorar deveria o

⁷⁴ CHAVES, Antonio. *Direitos autorais na computação de dados*. São Paulo: LTr, 1996, p. 84.

usuário adquirir um novo exemplar. Essa concepção decorre da crescente concessão de proteção autoral a obras utilitárias, bem como da assimilação da lógica de mercado do sistema de *copyright* que considera a obra intelectual como simples produto.

Não se faz, assim, a necessária distinção entre conteúdo e continente, por razões meramente mercadológicas: a restrição dos direitos do usuário ao exemplar possibilita maiores lucros para a indústria da propriedade intelectual.

Assim, medidas de segurança que poderiam ser tomadas pelo usuário como microfilmagem, arquivamento digital, cópia de salvaguarda e cópia de uso, muitas vezes são consideradas como violações de direitos autorais, quando na verdade o usuário não tem o fim de prejudicar o exclusivo autoral, mas de prevenir-se de danos que poderia vir a sofrer em decorrência de falhas técnicas no caso de suportes eletrônicos ou virtuais, ou da ação do tempo no caso de suporte material, *tempus edax rerum*.

O debate merece tratamento dialético. Se por um lado é benéfico para o autor a redução da obra intelectual à natureza de produto por, à primeira vista, proporcionar-lhe uma tutela mais ampla do ponto de vista econômico, por outro, transforma o usuário em consumidor, aplicando-lhe a tutela legal consumeirista o que ampliaria as responsabilidades sobre o produto⁷⁵ disponibilizado no mercado. Essa responsabilidade poderia ser solidariamente imputada ao autor ou titular de direitos, a teor do art. 12 do referido diploma legal.

Nesses casos, as medidas de segurança retromencionadas não poderiam ser consideradas como violação de direitos autorais, já que o usuário estaria no exercício regular do direito⁷⁶

⁷⁵ O art. 3º, § 1º, do CDC considera como produto qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

⁷⁶ O art. 188 do CC considera lícitos os atos praticados no exercício regular de direito reconhecido.

à efetiva prevenção de danos garantido no art. 6º, inciso VI, do C.D.C. A aplicação da tutela consumeirista restringiria, ainda, o exercício da autonomia privada do autor ou titular de direitos que teria que se sujeitar às rígidas normas contratuais ali previstas.

Evidencia-se aqui a ponderação feita quando do tratamento da situação jurídica autoral da necessidade de relativização do Direito Autoral, tendo-se em vista que em seu aspecto dinâmico o autor não é o único centro de interesses a relevar-se. E mais, haveria casos em que os direitos autorais seriam exercidos por terceiros, e não pelo autor, o que polarizaria a hipossuficiência em prol do usuário.

Apesar de comumente considerar-se a obra intelectual como produto, a questão está longe de ser pacífica. Quando a obra intelectual tem finalidade direta ou indireta de satisfazer interesses práticos ou utilitários essa conclusão parece ser inevitável⁷⁷. Porém, nos demais casos, por não haver finalidade utilitária, é de se questionar se o corpo místico da obra estaria abarcado pela noção de produto. A posição mais acertada parece ser a de que, nesses casos, a noção de produto deva restringir-se ao suporte em que a obra for fixada.

7.1.3.3 Obras digitais

Questão derradeira no tocante à exteriorização da obra refere-se à utilização da tecnologia digital. Essa tecnologia baseia-se na utilização de um código binário, sequência de dígitos, para representar qualquer quantidade e espécie de informação.

Enquanto na tecnologia analógica era necessária sempre uma quantidade variável de dados para representar quanti-

⁷⁷ A LDS, arts. 7º e 8º, reconhece expressamente a natureza de produto do *software*.

dades e espécies variadas de informação, com a tecnologia digital, textos, sons e imagens podem ser fixados e transmitidos em uma mesma mídia (multimídia).

Em outras palavras, a tecnologia digital é uma espécie de codificação da informação. Sua decodificação pressupõe a utilização de um sistema informático (*computador lato sensu*).

A utilização da tecnologia digital produz uma transformação quantitativa e qualitativa no campo tecnológico, uma vez que não apenas diminui a quantidade de informação necessária para a representação (digital) da obra, mas também influencia sua qualidade, já que todas as cópias produzidas seriam idênticas⁷⁸.

A tecnologia digital produz várias conseqüências no campo dos direitos autorais, uma vez que proporciona:

- a) maior facilidade e velocidade na transmissão de informações e distribuição de obras;
- b) maior facilidade na manipulação e no tratamento da informação e conseqüentemente na reunião, utilização, fracionamento e transformação de obras;
- c) novas categorias de obras intelectuais, a exemplo da obra multimídia, dos programas de computador, das bases de dados eletrônicas, as obras geradas por computador, etc;
- d) nova técnica de criação ou exteriorização de obras;
- e) novas formas de utilização de obras como carregamento e armazenamento de dados, comunicação virtual, visualização, disponibilização em rede digital, transmissão digital, etc.
- f) possibilidade de interatividade do usuário com a obra;

⁷⁸ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 390

- g) arquitetura de rede descentralizada o que dificulta o controle sobre seu funcionamento e seu conteúdo, bem como sua internacionalidade, o que dificulta a verificação da jurisdição competente e também da legislação aplicável ao caso;
- h) imprecisão do significado dos atos informáticos relacionados com obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral;
- i) possibilidade de tornar a obra sensível em mídias diferentes.

A digitalização de obras, como acima visto, pode gerar questões relativas à utilização e à exteriorização das obras. É de se considerar, por agora, as questões relativas às criações informáticas, se podem ou não ser consideradas obras intelectuais, se são passíveis da proteção autoral, ou seja, se a tecnologia digital pode ou não ser instrumento de exteriorização das obras.

As questões relativas à digitalização enquanto utilização, devida ou indevida, de obras é atinente à parte especial do Direito Autoral, cabendo, portanto, apenas algumas considerações iniciais nesse sentido.

A digitalização das obras consiste em sua decodificação e fixação em um suporte digital, que pode ter a finalidade de exteriorizá-la ou de utilizá-la.

Assim, a digitalização pode ser superveniente ou originária. Uma vez digitalizada, a obra adentra no mundo informático e será utilizada de modos que escapam aos conceitos tradicionais do Direito Autoral.

O Direito Autoral clássico não foi elaborado para a tecnologia digital. Seus institutos e conceitos não se encaixam na tecnologia digital, o que leva comumente à aplicação de analogias que muitas vezes não são satisfatórias. Por exemplo, a simples fixação da obra em suporte digital tem sido

considerada como ato de reprodução da obra, o que não é. Da mesma forma, sua disponibilização em rede digital tem sido considerada como forma de comunicação pública da obra, o que também não é⁷⁹.

Não se pretende afirmar que a proteção autoral não se aplica à utilização digital da obra, mas que ela contém especificidades que exigem um tratamento diferenciado das demais obras, o que torna insuficiente o tratamento dado pela LDA à questão, que se restringe a estender a proteção autoral à utilização digital das obra a teor do art. 29, inciso X, da LDA.

Permanecendo assim, ou a propriedade tecnodigital permanecerá à margem do Direito Autoral, ou se consolidará a invasão da esfera privada do usuário pelo titular de direitos autorais.

Segundo Pereira⁸⁰, a aplicação dos conceitos tradicionais do Direito Autoral à propriedade tecnodigital afeta gravemente os princípios do Direito Autoral já que produzem um deslocamento do ato relevante da esfera intermediária ou pública, para a esfera do gozo da obra, íntima. Nesse sentido uma das alternativas mais plausíveis para a gestão de direitos autorais na *Internet* tem sido as *clearinghouses*⁸¹, que buscam controlar e taxar o acesso às obras disponíveis na *Internet* a partir do acesso ao banco de dados em que estiverem arquivadas e não pela perseguição ao usuário.

⁷⁹ A questão assume grandes proporções já que se não há reprodução, não haveria violação de direitos autorais. Nesse sentido Pereira (*Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, 2001, p. 394) e Ascensão (*Direito Autoral*, 1997). A LDA, por outro lado, parece ter adotado a analogia ao considerar ato de reprodução a fixação temporária com a finalidade tornar a obra perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória ou incidental. Entretanto, desde que ocorra no curso do uso autorizado pelo titular, não haverá violação de direitos autorais.

⁸⁰ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 427.

⁸¹ FERNANDEZ-DIEZ, Ignacio Garrote. *El derecho de autor en internet*. Granada: Comares, 2001, p. 65.

Há três correntes de autores que tentam solucionar os problemas decorrentes da utilização digital de obras, os neoliberais, os minimalistas e os ecléticos. Os neoliberais acreditam que o Direito de autor clássico é perfeitamente aplicável ao mundo digital, necessitando simplesmente de ajustes para reforçar as prerrogativas dos titulares de direitos autorais. Essa corrente é muito bem ilustrada em situação análoga retratada pela reportagem publicada na *Gazeta Mercantil* em 24 de março de 2004 que noticiou evento promovido no Ministério da Fazenda decorrente de parceria entre o Consulado Americano e a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e relata que os especialistas ali reunidos acreditavam que a pirataria de *software* deveria ser incluída no rol de crimes contra a humanidade.

Os minimalistas que acreditam que no ambiente digital seja mais importante assegurar o direito à informação do usuário do que o direito de autor, que teria suas prerrogativas reduzidas. Essa corrente é claramente influenciada pela crença popular de que a *Internet* seria terra sem lei.

E, por fim, os ecléticos que acreditam que se deva buscar um equilíbrio entre os interesses do autor e os interesses do usuário⁸². Esta última bem defendida por Pereira⁸³ que demonstra que o Direito Autoral pode ser o fundamento da propriedade tecnodigital sem se restringir a uma lógica de exclusão.

Retomando-se a questão acerca da exteriorização digital de obras, apesar de extenso o debate acadêmico⁸⁴, a resposta mais acertada parece ser a afirmativa. Não há como se negar que a tecnologia digital possa ser utilizada como ferramenta

⁸² FERNANDEZ-DIEZ, Ignacio Garrote. *El derecho de autor en internet*, p. 67-68.

⁸³ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 786.

⁸⁴ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 397-399.

ou técnica a serviço da criação. A tecnologia digital não altera o ato criativo em sua essência. Lembrando-se das fases do processo criativo, a tecnologia digital seria aplicada apenas na terceira fase: a fase técnica.

A obra intelectual, enquanto elemento da cultura, serviu-se, com o passar dos tempos, dos instrumentos de comunicação disponibilizados pela tecnologia de cada época. Inicialmente exteriorizava-se meramente pela via oral ou gestual. Posteriormente, passou a utilizar-se das formas de representação das idéias que foram paulatinamente surgindo: os desenhos, a representação gráfica, os hieroglifos, a transposição de imagens, a música, os símbolos⁸⁵, atualmente pela representação digital e no futuro sabe-se como.

Levy⁸⁶ critica justamente essa metáfora bélica do impacto da tecnologia digital como algo extraordinário e externo arremessado sobre a sociedade e não como algo que naturalmente tivesse dela brotado e lembra que o uso intensivo de ferramentas é um dos elementos que constitui a humanidade.

A metáfora da erupção talvez fosse mais adequada. A tecnologia digital é mais um recurso tecnológico disponível para a instrumentalização da linguagem e conseqüentemente das obras intelectuais, que contêm suas próprias peculiaridades, como a necessidade de codificação numérica das informações representativas da obra intelectual (código binário) e a necessidade de um sistema informático para processamento do respectivo código.

Por outro lado, a tecnologia digital quando utilizada como ferramenta de criação pode promover uma espécie de terceirização da fase de instrumentalização da obra, haja vista que nem sempre o autor terá o domínio das técnicas de computação de dados.

⁸⁵ GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à internet*. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 26

⁸⁶ LEVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 21-22

Surge assim acirrado debate acadêmico sobre a hipótese de se considerar o programador, enquanto operacionalizador da codificação, e até mesmo a máquina, nos casos de obras geradas automaticamente por computadores, como autores ou co-autores da obra.

A questão do programador de dados, enquanto prestador de serviços técnicos, não é de todo desconhecida do Direito Autoral clássico. Não são raros os casos em que o autor se utiliza de prestadores de serviços para executar suas obras, sem que com isso tenha que compartilhar a autoria da criação.

Um arquiteto e um paisagista elaboram os projetos de execução da obra que, na maioria das vezes, será feita por terceiros. A colaboração meramente técnica escapa ao conceito de autoria.⁸⁷ O que não impede que em alguns casos possa haver uma contribuição criativa por parte do programador o que poderá caracterizar a co-autoria, a obra coletiva ou mesmo a obra por encomenda.

Essa perda da autonomia do autor gera, contudo, uma espécie de despersonalização da obra, uma vez que a criação informática, por exigir a reunião de várias técnicas, dificilmente será individual⁸⁸.

As criações artificiais, por outro lado, escapam à tutela autoral. Já que nenhum autor humano pode ser designado não restarão preenchidos os requisitos da proteção legal.⁸⁹ Criações artificiais não são criações do espírito. Não se pode negar, porém, que essas criações artificiais possam ter um

⁸⁷ Art. 15, § 1º, da LDA

⁸⁸ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 409.

⁸⁹ Contrariamente ao sistema de *copyright* em que o valor comercial da obra é preeminente. No Reino Unido as obras geradas por computador geram direito exclusivo de exploração econômica para seu produtor (PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 407).

valor econômico tutelado juridicamente, seja pela propriedade industrial, seja como um direito *sui generis*.

Nesses casos ficaria o questionamento acerca do titular dos referidos direitos, se seria o criador ou fabricante do programa utilizado para a elaboração da obra ou o usuário respectivo. A solução do Direito inglês foi a de se considerar o usuário (produtor da obra) como titular dos direitos, haja vista que o programador ou fabricante não elabora a obra, mas tão-somente torna possível a sua elaboração pelo usuário⁹⁰.

⁹⁰ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 406.

CAPÍTULO VIII

TENDÊNCIAS FUTURAS

8.1 A CRISE DO DIREITO AUTURAL: A TRIPARTIÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pergunta-se se atualmente o Direito Autoral estaria em crise. A cristalização do Direito Autoral em sua concepção clássica acabou distanciando-o da realidade. Nada é para sempre. A estagnação teórica do Direito diante do avanço social e tecnológico o distancia de seu objetivo de representação da realidade.

O Direito, por conseqüência, se transforma em um fardo a ser carregado pela sociedade ao invés de ser instrumento de sua transformação. Em uma dimensão crítica o Direito está sempre em movimento, sempre em construção, sempre em crise¹.

É certo, contudo, que se verifica atualmente um grau de instabilidade maior no Direito Autoral, decorrente tanto de fatores de ordem tecnológica como de fatores de ordem jurídica. O Direito Autoral encontra-se em uma fase particularmente difícil de seu processo evolutivo, mas que contém algo de positivo, a oportunidade de superar-se.

¹ COELHO, Luiz Fernando. *Teoria crítica do direito*, p. 189.

Desde a Revolução Industrial verifica-se um fenômeno de massificação social com a massificação das cidades, da produção, das comunicações, das relações de consumo, da responsabilidade civil e do contrato².

A tecnologia digital além de acelerar³ esse fenômeno atinge definitivamente o Direito Autoral uma vez que massifica não só a utilização das obras como também o ato criativo e a criação. Dessa feita, fica cada vez mais difícil identificar a criação intelectual como instrumento de promoção cultural ao invés de ser vista simplesmente como instrumento de produção de riquezas⁴. Calcula-se que aproximadamente 5% do PIB da União Européia corresponda à exploração de obras intelectuais⁵.

Pode-se dizer, portanto, que essa evolução tecnológica gera uma crise nas instituições de Direito Autoral em decorrência de maior facilidade de fixação da obra em suportes materiais diversos, da possibilidade de fixação da obra em suportes intangíveis (digitais), da possibilidade de codificação de qualquer espécie de obra para sua representação digital, da maior facilidade e velocidade na transmissão das informações e distribuição de obras, da possibilidade de interatividade do usuário com a obra, da descentralização da arquitetura de rede e de sua internacionalidade, da imprecisão

² FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.) *Direito civil* – atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 26

³ A tecnologia digital não cria esse fenômeno, mas apenas o acelera. A transformação das condições econômicas de propagação e utilização das obras é uma constante histórica e já havia sido evidenciada com a aparição dos fonogramas, do cinema, da radiodifusão, da televisão, da reprografia, etc. (DOCK, Marie Claude. *Étude sur le droit d'auteur*, p. 5).

⁴ PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, p. 441

⁵ FERNANDEZ-DIEZ, Ignacio Garrote. *El derecho de autor en internet*, p. 211

do significado dos atos praticados por meios informáticos e do surgimento de novas categorias de obras intelectuais, de nova técnica de criação ou exteriorização de obras e de novas formas de utilização de obras.

Tendo-se em vista essas conseqüências faz-se necessária uma releitura conceitual das instituições de Direito Autoral no sentido de acompanhar a nova realidade tecnológica. As noções de criação, obra, fixação, reprodução, contrafação, etc. não têm mais o mesmo conteúdo com que foram sistematizadas, além disso, surgem novas noções como o armazenamento digital, a codificação, a visualização digital, o compartilhamento de informações, etc.

Nesse sentido é certo que a LDA não será suficiente. Não porque não seja aplicável à criação ou utilização de obras em meio digital ou em rede, mas porque suas concepções permaneceram cristalizadas impedindo que ela se abrisse ao enfrentamento das novas questões que lhe foram impostas⁶. Não que se pretenda defender a necessidade de se criar uma nova legislação de direitos autorais.

A LDA não pode pretender ser a Lei global do microssistema autoral, mas simplesmente sua Lei básica, o que já é. A adequação do Direito Autoral à tecnologia digital melhor se faria em legislação específica. A superação dos problemas trazidos pela tecnologia digital pressupõe o esforço legislativo de regulamentação das novas situações por ela criadas. Segundo a Diretiva européia sobre direitos de autor e afins na sociedade da informação (DDASI) o desenvolvimento tecnológico multiplicou e diversificou os vetores da criação, da produção e da utilização das obras intelectuais. Assim, mesmo que não se considere necessários novos conceitos em matéria de proteção à propriedade intelectual, deve-se adaptar e integrar a proteção autoral à nova realidade.

⁶ ROBERTO, Giordano Bruno Soares. *Introdução à história do direito privado e da codificação*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 90.

Para a solução de tais problemas e a reconstrução das instituições e conceitos de Direito Autoral é importante empreender-se a ressystematização do Direito Autoral, ou seja, a tripartição da propriedade intelectual em três ramos, propriedade industrial, Direito Autoral e propriedade tecnodigital, que comungariam das mesmas normas fundamentais.

Segundo a DDASI, como o Direito Autoral desenvolve importante função no contexto digital, uma vez que protege e estimula o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos e serviços, bem como possibilita a criação e a utilização de seu conteúdo criativo é importante que se busque uma harmonização entre a sociedade da informação e os direitos autorais.

8.2 A RESSISTEMATIZAÇÃO DO DIREITO AUTURAL

Além dessa evolução tecnológica que tem influenciado as instituições de Direito Autoral, a mudança paradigmática contida no texto constitucional provocou importantes transformações principiológicas que, em efeito cascata, alcançam todo o ordenamento jurídico brasileiro.

Essa mudança também atinge as instituições de Direito Autoral. Isso porque antes da CF/88, a teoria jurídica do Direito Autoral assentava-se nos dogmas da autonomia da vontade, no princípio da liberdade econômica, na dicotomia Estado e Indivíduo e em uma concepção formalista de igualdade e liberdade⁷.

Em contrapartida, em um Estado de Direito, a teoria jurídica do Direito Autoral deve ter por fundamentos a dignidade

⁷ FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito civil* – atualidades, p. 25.

da pessoa humana e a funcionalidade do direito subjetivo, respectivamente art. 1º, inciso III, e art. 5º, inciso XXIII.

Pode-se dizer que essa transformação tem por consequências a constitucionalização e a personalização do Direito Autoral.

A expressão constitucionalização do Direito Autoral pode ser vista em duas acepções distintas que podem ser traduzidas nas noções de Direito Constitucional-autoral e Direito Autoral-constitucional.

Na primeira noção trata-se do estudo da incorporação no texto constitucional de temas de Direito Autoral, a exemplo dos incisos XXVII e XXVIII da CF/88 que garantem ao autor o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, a transmissibilidade desses direitos a seus herdeiros, a proteção às participações individuais em obras coletivas e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem.

Na segunda, verifica-se uma tutela constitucional indireta que encerra a base da proteção autoral, formada por princípios como: o desenvolvimento da cultura, a liberdade de manifestação do pensamento, da arte e da ciência, a proteção ao trabalho, à livre iniciativa, à propriedade privada⁸, à dignidade humana, à livre expressão da atividade intelectual, artística e científica, etc.

Tratar-se-á, por ora, da segunda acepção, o Direito Autoral-constitucional que permite três abordagens distintas. A primeira vê na carta constitucional o centro de todo o sistema jurídico brasileiro; a segunda que vê na Constituição o centro do sistema jurídico e no Código Civil o centro do Direito Privado; já a terceira que considera o Direito Privado como sistema sem ponto central, gravitando em torno de normas fundamentais encontradas em todo o sistema.

⁸ DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*, p. 265.

Apesar dessas distinções, qualquer das três abordagens traz para a base do Direito Autoral os princípios constitucionais referidos. Em outras palavras, não se pode mais considerar que os princípios aplicáveis ao Direito Autoral se encontrem exclusivamente na legislação autoral. A necessidade de unidade do sistema jurídico faz com que as regras de Direito Autoral sejam interpretadas dentro do contexto principiológico em que se inserem, à luz dos princípios gerais da propriedade intelectual, do Direito Civil e do Estado de Democrático de Direito. O princípio aplicável ao caso concreto de Direito Autoral não estará, portanto, necessariamente contido na LDA. Pode estar na LPI, no CC ou na CF, por exemplo.

Além disso, as instituições de Direito Autoral passam por um processo de despatrimonialização e de funcionalização: a obra intelectual deixa de ser o centro gravitacional do Direito Autoral e seu lugar é ocupado pela dignidade da pessoa humana, com direito à promoção espiritual, cultural, social e econômica. Trata-se de uma correção do individualismo jurídico que é naturalmente excludente⁹.

Daí a necessidade de se interpretar o Direito Autoral na medida de sua funcionalidade, enquanto instrumento de promoção dessa dignidade. Não se propõe uma antítese à concepção liberal clássica, haja vista ter sido essa a proposta do estado social, mas uma síntese.

O centro gravitacional do ordenamento jurídico não é o indivíduo, mas a dignidade humana. Nesse sentido, o Direito Privado não é visto, simplesmente, como proteção do indivíduo, mas também como garantia de acesso a bens e como limite ao abuso de poder e de direito. Trata-

⁹ FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito civil – atualidades*, p. 29.

se da substituição da noção de sujeito isolado pela noção de sujeito situado¹⁰.

Seria, portanto, uma segunda fase no processo de humanização do Direito. A primeira fase foi empreendida pelo liberalismo jurídico, que direcionou a legislação para a proteção do indivíduo. Essa segunda fase busca a proteção do indivíduo inserido em um contexto histórico-social, e já se poderia, inclusive, vislumbrar uma terceira fase, ainda que embrionária, em que se pretende a proteção do indivíduo inserido em seu contexto ambiental. Essa evolução do antropocentrismo ao biocentrismo é essencial à sobrevivência da sociedade humana.

Nessa perspectiva, os direitos individuais do criador encontram limites não só temporais como também funcionais. O direito subjetivo deve ser concebido em razão de suas variadas funções, sendo elas: econômica, social, normativa, política e pedagógica. Essa aptidão funcional do Direito Autoral põe fim à “guerra fria” travada entre o interesse público e o interesse privado no campo do Direito Autoral e revela a ilegitimidade da tutela individualista do autor.

Essa pretensão de plena proteção jurídica aos interesses individuais do autor jamais se concretizou, haja vista a falta de aceitação pública da legislação autoral, o que demonstra que o modelo unidirecional de tutela dos interesses sobre a criação tende a ceder espaço a um modelo promocional da criação, que visa a garantir ao autor uma tutela satisfatória, seja pelo licenciamento, seja pela gestão coletiva, sem obstaculizar o desenvolvimento cultural¹¹.

O Direito Autoral deixa de ser visto como a tutela dos interesses do criador e passa a ser visto como a tutela das

¹⁰ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 83.

¹¹ Para Santilli a tutela deveria ser mínima (SANTILLI, Marina. *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, p. 94-95).

relações jurídicas decorrentes da criação, mesmo porque constantemente verifica-se que o beneficiário da tutela autoral não é o criador da obra, mas o titular derivado, herdeiro, editor, produtor, etc.

Há tempos que o termo direito autoral deixou de ser expressão da tutela do autor (sujeito) e transformou-se em tutela dos direitos subjetivos autorais (objeto).

A legitimação do Direito Autoral brasileiro pressupõe ampla participação de seus destinatários em seu processo de (re)construção política, legislativa e jurisdicional. Essa legitimação não virá simplesmente da adoção de novas medidas de repressão à pirataria, a exemplo do Decreto 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dispôs sobre a composição e sobre o funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.

A pirataria não é a causa da crise do Direito Autoral, mas sua consequência. A causa é sua sistematização, essencialmente excludente. Nessa perspectiva, a crise não é do Direito Autoral, mas de legitimidade da legislação autoral brasileira¹².

A constitucionalização do Direito Autoral pressupõe a aceitação do pluralismo jurídico, a admissibilidade das normas individuais e concretas no quadro geral das normas jurídicas, a preocupação com o conteúdo das normas, a repolitização do Direito e a legitimação da ordem jurídica¹³.

O pluralismo jurídico e a admissibilidade das normas individuais e concretas no quadro geral das normas jurídicas pressupõe, ainda, a modificação do método interpretativo do Direito Autoral.

Enquanto em sua concepção clássica o microsistema autoral era visto como um sistema fechado, pleno, que redu-

¹² PERLINGIERI, Pietro. Fonti normative e interpretazione. In: PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto privato futuro*. Napoli: ESI, 1993, p. 75-76

¹³ AMARAL, Francisco. Transformação dos sistemas positivos a descodificação do direito civil brasileiro. *O Direito*, p. 44-45

zia a atividade jurisdicional a ato mecânico de aplicação da Lei, em uma concepção constitucionalizada deve ser visto como um sistema aberto, que se alimenta também de sua interpretação, em que a atividade jurisdicional será também criadora.

O sistema jurídico não é dedutivo, mas dialético¹⁴. Assim, a lógica da interpretação jurídica não deve ser dedutiva, mas argumentativa¹⁵.

É lógico, contudo, que a dimensão normativa da interpretação jurídica pressupõe a legitimação da norma jurídica por ela criada, o que impõe limites à argumentação. A solução do caso não pode contrariar o sistema jurídico vigente.

Na lição de Leal¹⁶, a decisão na democracia juridicamente institucionalizada não pode preterir os direitos fundamentais. Nesse sentido, enquanto elementos legitimadores da decisão judicial, não são apenas instrumentos constitucionais de construção hermenêutica, mas também limites da atividade interpretativa.

Ainda na lição de Leal¹⁷, para tanto se faz necessária a transição da concepção de Estado como entidade para a concepção de Estado como espaço processualmente demarcado à discursividade: produção, recriação e aplicação dos direitos positivados.

¹⁴ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 79-81.

¹⁵ Sobre as teorias da argumentação jurídica e a interpretação civil constitucional: FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito civil – atualidades*, p. 33-58

¹⁶ LEAL, Rosemiro Pereira. *Teoria processual da decisão jurídica*. São Paulo: Landy, 2002, p. 148-149

¹⁷ LEAL, Rosemiro Pereira. Isonomia processual e igualdade fundamental a propósito das retóricas ações afirmativas. *Revista Jurídica Unijus*, Uberaba, v. 6, n. 1, p. 43-50, ago. 2003, p. 47.

Assim, os fundamentos jurídicos do Estado de Direito não podem ser vistos como meros valores ou “ideário de artifícios para decisões prodigiosas”, mas como princípios normativos, “meios lógico jurídicos positivados no instrumento constitucional” que não podem ser preteridos pela faticidade da atividade jurisdicional¹⁸.

Dessa forma, em um sistema aberto-problemático, a construção da norma se dá a partir dessa interpretação do sistema jurídico, de seus valores, princípios e regras, e sua conseqüente aplicação à realidade fático-jurídica¹⁹.

Não se trata, portanto, de retrocesso ao casuismo, mas de nova concepção de sistema jurídico que se reconstrói a partir do problema posto²⁰. Dessa forma, os conceitos de Direito Autoral, mesmo que aparentemente técnicos, só podem ser entendidos enquanto fixação de princípios de justiça na vinculação autor-obra-sociedade.

Assim, por exemplo, a regra que prevê a interpretação restritiva dos negócios de Direito Autoral deve, na verdade, ser entendida como a fixação do princípio de tutela do hipossuficiente, que considera o autor parte frágil na relação negocial e busca igualá-lo²¹.

Nesse sentido, não poderia ser aplicada a qualquer caso. Por exemplo, não poderia ser aplicada se não restasse verificada a hipossuficiência do autor, tampouco poderia ser aplicada para beneficiar o titular derivado de direitos autorais.

Vê-se, portanto, que a superação da crise institucional do Direito Autoral pressupõe a aceitação de que a interpretação normativa é instrumento de sua transformação, uma vez que pode ampliar seu conteúdo até transformá-la²².

¹⁸ LEAL, Rosemiro Pereira. *Teoria processual da decisão jurídica*, p. 149

¹⁹ SÁ, Maria de Fátima Freire de. *Direito de morrer*. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 159-172

²⁰ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 77.

²¹ VIEHWEG, Theodor. *Tópica e jurisprudência*. Brasília: Ed. UnB, 1979, p. 92

²² LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 78-79

Assim, nesta nova concepção de sistema jurídico autoral, que tem por força gravitacional suas normas fundamentais, os elementos estruturantes do juízo decisório encontram-se dissipados no sistema e não reunidos exclusivamente na LDA, podendo estar também na Constituição, no Código Civil, na Lei de Propriedade Industrial, etc. São todos fontes de Direito Autoral.

Essas normas fundamentais de Direito Autoral têm, portanto, função fundante, interpretativa, limitativa e integrativa, atribuem conteúdo e unidade ao sistema e orientam e delimitam as atividades de criação, interpretação e aplicação do Direito²³.

Exemplificando-se, tem-se questão de ordem prática originada de decisão dos autores e editores associados à Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) que a partir de abril de 2004 consideraram ilícita a cópia reprográfica, total ou parcial de qualquer obra de seus membros, salvo nos casos permitidos por Lei.

A decisão visou impedir, inclusive, a realização de cópias por professores para disponibilização a seus alunos. Assim, foram condenadas, dentre outras, tanto a prática conhecida por “pasta do professor”, em que o professor disponibiliza em uma central reprográfica determinados textos para serem copiados pelos alunos para estudo e debate, como também a prática usada por muitos professores de distribuir pequenas partes de obra (muitas vezes uma única página ou até parte dela) para trabalhar com os alunos dentro da própria sala de aula²⁴.

‘O argumento utilizado pela associação baseia-se em uma interpretação restritiva do inciso II do art. 46 da LDA que permite a reprodução, em um só exemplar de pequenos tre-

²³ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 281

²⁴ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS. *Perguntas e respostas mais freqüentes*. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <<http://www.abdr.org.br>>. Acesso em: maio 2005.

chos de obras, para uso privado do copista. A interpretação dada foi a de que o fato da finalidade da reprodução ser a utilização na atividade de ensino e não para uso privado do professor escaparia à permissão legal.

Por outro lado, partindo-se do pressuposto de que a regra do art. 46, inciso II, só pode ser entendida enquanto expressão de princípio de justiça aplicável ao Direito Autoral, a solução do problema tomaria outra direção.

Sob esse aspecto, a interpretação mais condizente com o princípio da funcionalidade do Direito Autoral seria a que mais se aproximasse de seu fim enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento cultural. Em outras palavras, em uma perspectiva funcional a solução jurídica do caso concreto deve atender a sua funcionalidade.

Assim, a referida regra pressupõe a ampliação de seu conteúdo com a dilação do conceito de uso privado, de forma a abranger as referidas práticas necessárias à atividade de ensino na realidade educacional brasileira. Excluídos estariam apenas os atos de publicação, (re)transmissão, emissão, distribuição, comunicação e reprodução que não se dirigissem aos destinatários das próprias lições.

Importante frisar-se que a interpretação da referida regra de forma a aproximá-la do princípio por ela fixado não se trata de mera opção, mas de pressuposto de legitimidade da solução jurídica.

Nessa abordagem, o princípio da funcionalidade do direito subjetivo é o elemento legitimador da própria regra. O que é explícito naquele é implícito nesta. Assim, o princípio deve ser observado pelo jurista, pelo juiz e pelo legislador²⁵.

Nessa perspectiva, contribui-se para a unidade do sistema jurídico, bem como para a identificação de regras que fixem o mesmo elemento legitimador o que propicia uma reconstrução sistêmica coerente.

²⁵ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 286

Por exemplo, no sistema jurídico brasileiro, o princípio da funcionalidade do Direito vem fixado como elemento legitimador de várias regras jurídicas. É o caso das regras da desapropriação, da resolução contratual por onerosidade excessiva, da licença compulsória da patente, da perda da propriedade *pro labore*, etc.

Nesses casos, experimenta-se a extinção ou suspensão do exercício do direito subjetivo em decorrência de seu elemento legitimador estar sendo preterido. Consta-se que a linha evolutiva desses institutos objetivou essa coerência com seu elemento legitimador, enquanto que a LDA caminha na contramão, distanciando-se dele.

Daí constatar-se que, enquanto nesses casos há na própria legislação a abertura para a aplicação do princípio da funcionalidade do direito, na LDA o legislador manteve esta porta semicerrada²⁶, o que não retira a eficácia do princípio que soe, enquanto orientador e limitador das atividades jurídica, jurisdicional e legislativa, também em relação aos Direitos Autorais.

Exemplo histórico dessa comunhão principiológica dos ramos da propriedade intelectual se deu durante a Segunda Guerra Mundial em que a legislação de guerra brasileira incorporou ao Patrimônio Nacional não apenas os direitos de propriedade industrial existentes no Brasil em nome de cidadãos alemães, como também seus direitos autorais, ainda que não houvesse previsão expressa na legislação autoral vigente à época acerca do licenciamento compulsório. Posteriormente, em 3 de julho de 1958 foi promulgado pelo Decreto 43.956 o acordo entre Brasil e Alemanha restaurando os direitos de propriedade industrial e os direitos autorais atingidos pela legislação de guerra.

²⁶ Talvez por essa razão ainda seja um tabu em nosso direito falar-se em usucapião de obras intelectuais.

Diante do exposto, é de se constatar que no Direito Autoral contemporâneo merece especial atenção o princípio da funcionalidade do direito subjetivo autoral.

Pelo princípio da funcionalidade a criação intelectual não é tutelada apenas pela força normogenética da autonomia individual de seu criador (situação subjetiva), mas também porque interessa à sociedade a tutela de suas consequências sociais, econômicas, políticas e normativas (situação objetiva).

Mesmo porque não se pode mais conceber a autonomia privada como um fenômeno de criação jurídica, propriamente dito, mas como fenômeno de recepção jurídica. O indivíduo incorpora ou reinterpreta o conjunto normativo existente, o que implica aceitação de seus pressupostos²⁷.

Essa funcionalidade do direito subjetivo autoral decorre da institucionalização da criação. A tutela da obra intelectual não mais se justifica exclusivamente na proteção dos interesses individuais do autor ou titular de direitos autorais, mas como instrumento de composição dos vários interesses envolvidos.

Assim, o princípio da funcionalidade do direito subjetivo promove uma revisão do conceito de autonomia privada, já que funciona também como limite à atuação individual, restringindo a esfera de liberdade de que o indivíduo dispõe.

A institucionalização da criação intelectual delimita o campo de atuação de seu titular uma vez que não é vista simplesmente como instrumento de satisfação dos interesses morais e econômicos do autor, mas também como instrumento de satisfação do interesse social de desenvolvimento cultural e do interesse político de legitimação da ordem jurídica.

A institucionalização da criação intelectual não tem, contudo, a finalidade de impor algum interesse externo à re-

²⁷ LORENZETTI, Ricardo Luis. *Fundamentos do direito privado*, p. 546

lação jurídica autoral, a exemplo da tese inicial do corporativismo nacional-socialista recepcionada pela constituição de *Weimar* e demais constituições facistas²⁸, em que os direitos individuais deveriam cair diante de um “interesse superior da nação”²⁹, que revelou-se como retrocesso autoritarista diante das conquistas liberais.

A institucionalização da criação intelectual é vista, aqui, como a busca pela composição dos interesses conflitantes decorrentes da relação jurídica autoral, de forma a se obter a solução jurídica que seja a mais legítima (ou convincente), dentre aquelas possíveis (pluralidade funcional), coerentes com seu elemento legitimador.

Para tanto, faz-se necessária a inversão tópica proposta por Viehweg³⁰: o desenvolvimento do Direito Autoral pressupõe a vinculação do sistema a partir do problema e não o contrário. O pensamento problemático da tópica de Viehweg³¹, bem como das demais teorias da argumentação jurídica, explicita uma realidade que o pensamento exegético tentou ocultar: há, habitualmente, mais de uma solução jurídica possível para o caso concreto.

Veja-se o exemplo de questão ocorrida no Brasil em caso afim ao Direito Autoral. Em decisão liminar movida em ação cautelar o Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia determinou a busca e apreensão de todos os exemplares do livro *Na toca dos leões* de Fernando Moraes, além de condenar os réus ao *silêncio* acerca do texto imputado como calunioso sob pena de pagamento de multa

²⁸ FERRAJOLI, Luigi. Il diritto privato del futuro: libertà, poteri e granzie. In: PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto privato futuro*. Napoli: ESI, 1993, p. 26.

²⁹ ROPPO, Enzo. *O contrato*, p. 56.

³⁰ VIEHWEG, Theodor. *Tópica e jurisprudência*, p. 99.

³¹ FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.) *Direito civil – atualidades*, p. 35-58.

no valor de R\$5 000,00 a cada violação da dita obrigação de não fazer.

Em síntese, por suposto atentado à honra do autor da ação, a obra foi censurada, negando-se a garantia fundamental de livre expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura ou licença.

Em outro caso, a 4ª Turma Superior do STJ reconheceu o direito das herdeiras de Manoel dos Santos (Garrincha) a serem indenizadas por danos morais e materiais por violação ao direito à imagem, ao nome, à intimidade, à vida privada e à honra paterna pela publicação do livro *A estrela solitária – Garrincha*³².

Em ambos, trata-se de soluções possíveis dentro do sistema jurídico brasileiro, haja vista que o Código Civil (art. 12) assegura, em linhas gerais, tanto o direito de exigir indenização pelos danos sofridos como que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade. A opção, portanto, deve recair sobre a decisão que se mostrar mais convincente.

A argumentação jurídica se mostra, portanto, essencialmente consequencialista. Os efeitos jurídicos produzidos pela decisão serão imputados na realidade fática. Assim, não basta que a decisão faça sentido dentro do sistema jurídico, deve fazer sentido em relação às consequências que irá produzir no mundo³³.

Retomando-se, então, verifica-se que a relação jurídica autoral não pode mais ser vista como uma relação de subordinação entre titular de direitos e usuário mas como uma relação de cooperação, em que titular e usuário devem co-

³² SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. *Informe*. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>> Acesso em: 27 fev 2006

³³ FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito civil – atualidades*, p. 55.

operar entre si para a consecução da finalidade da concessão da tutela autoral, que é a promoção do desenvolvimento cultural.

Daí, tem-se que o princípio da funcionalidade do Direito Autoral tem por consequências a relativização dos direitos autorais, a (re)integração do Direito Autoral ao sistema jurídico de Direito Privado e a legitimação do Direito Autoral, objetivo e subjetivo (legitimação da norma jurídica autoral e do direito subjetivo autoral).

Promove a relativização dos Direitos Autorais porque impõe limites ao seu exercício. Sob esse aspecto é instrumento de coibição do abuso de direito. O titular de direitos autorais que ao exercê-los exceder manifestamente os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito.

Assim, vê-se que o princípio da funcionalidade do direito desmembra-se nos princípios da tutela do hipossuficiente e da boa-fé objetiva. As consequências pelo abuso de Direito Autoral podem ser a invalidade do ato praticado, a revisão, a resolução e até mesmo indenização, a teor do art. 927 do CC.

Dessa forma, os limites ao Direito Autoral não são vistos mais como limites externos, exceções ao poder ilimitado do autor, como se o Direito Autoral fosse atribuído ao exclusivo interesse do autor. Esses limites representam seu aspecto qualitativo interno no sentido de que são elementos de sua própria conformação. O Direito Autoral não é reconhecido e nem tutelado se seu exercício desviá-lo de suas funções³⁴.

Promove também a integração do Direito Autoral ao conjunto do sistema jurídico brasileiro já que o direito subjetivo autoral é atribuído como instrumento de garantia de normas fundamentais ao redor das quais gravita todo o sis-

³⁴ PERLINGIERI, Pietro. *Perfil do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*, p. 122

tema jurídico. Aproximando-se delas, reaproxima-se do sistema. O direito subjetivo deve ser instrumento de efetivação das garantias constitucionais fundamentais.

Promove, por fim, a legitimação da norma jurídica pela participação de seus destinatários em seu processo de construção. Mostra-se, assim, como critério de ação para o indivíduo, para o legislador e para o aplicador do Direito, essencial à legitimação da norma negocial, da norma legal ou judicial.

O princípio da funcionalidade do Direito Autoral mostra-se, assim, como a expressão no Direito Autoral das normas fundamentais constitucionais a ele aplicáveis, contribuindo para a relativização da dicotomia público-privado e para o reconhecimento do caráter político do direito privado, concebendo-se o direito subjetivo como elemento construtor da norma jurídica, negocial ou judicial, se sujeitando, portanto, aos critérios de legitimidade da própria norma³⁵.

Assim, para que o princípio em questão não se transforme em artifício para imposição ideológica o que o resumiria a mero despotismo pretoriano, é, conforme lição de Leal, imprescindível o atendimento aos direitos fundamentais do cidadão para que ele esteja em condições de debater seus direitos, proceduralmente, em condições argumentativas isonômicas³⁶.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi delinear uma teoria geral para o Direito Autoral. Para tanto, foi analisada a relação jurídica autoral, seus elementos constitutivos e sua principio-logia. A parte especial do Direito Autoral não foi estudada por extrapolar a delimitação do tema proposto. Fica relegada à parte especial a análise dos direitos conexos, dos negócios jurídicos autorais, da responsabilidade civil (pirataria) e da propriedade tecnodigital (Direito Autoral na rede).

O critério distintivo adotado foi o de delimitar a parte geral do Direito Autoral à análise da estática autoral (situação jurídica absoluta) e, na parte especial, o estudo de sua dinâmica (situações jurídicas relativas).

A sistematização dada à parte geral do Direito Autoral buscou inspiração no movimento constante, tese, antítese e síntese, o que levou à tripartição deste estudo, dividindo-se nas fases de construção, desconstrução e reconstrução do Direito Autoral. Na primeira fase, verificam-se os fundamentos e valores que inspiraram, inicialmente, o Direito Autoral. Na segunda, verificou-se que a mesma transformação paradigmática, que possibilitou a ampliação do conteúdo do aspecto existencial do Direito Autoral, também delimitou seu aspecto patrimonial, o que gerou uma espécie de reação

³⁵ Kelsen, Hans. *Teoria geral do direito e do Estado*, p. 124-128.

³⁶ Leal, Rosemiro Pereira. Isonomia processual e igualdade fundamental a propósito das retóricas ações afirmativas. *Revista Jurídica Unijus*, p. 44-45.

autoral na defesa do monopólio conquistado. Na terceira, buscou-se a reconstrução do Direito Autoral, propondo sua ressystematização com a tripartição da propriedade intelectual, a elaboração de uma teoria geral da propriedade intelectual e sua reaproximação ao Direito Civil e às normas constitucionais fundamentais.

Assim, inicialmente buscou-se a análise do Direito Autoral *in erba*. Sua posição dentro da propriedade industrial, as várias acepções do termo, os fundamentos e valores clássicos e sua natureza jurídica.

Posteriormente, passou-se à análise da situação jurídica autoral existencial, analisando-se a corrosão natural de seus institutos e a ampliação da tutela com a ampliação do conteúdo desse valor existencial pela promoção da dignidade humana.

Nessa parte, foram estudados os direitos morais de autor, o direito de reivindicar a autoria da obra, o direito à autoria, o direito ao inédito, o direito à integridade da obra, o direito de modificar a obra, o direito de retirada, o direito de acesso a exemplar único e raro, bem como suas características, a extrapatrimonialidade, a eficácia absoluta, a indisponibilidade, a intransmissibilidade, a imprescritibilidade e a preeminência.

Depois, passou-se à análise da situação jurídica autoral patrimonial, a regulamentação legal em face das transformações sociais e tecnológicas e o acirramento da crise de legitimidade da legislação autoral.

Aí, foram analisados os direitos patrimoniais de autor, sua transmissibilidade, onerosidade, temporariedade e economicidade, bem como identificado o ato ilícito autoral.

Foram analisados também o uso privado e as limitações legais aos direitos patrimoniais de autor, superando-se a noção de exceção e adotando-se a posição de elemento qualitativo do Direito Autoral.

Foi estudado o fato gerador da tutela, sua natureza relacional e seus elementos estruturais: sujeito e objeto, analisando-se as distinções entre autoria e titularidade, obras criadas para outrem, obras anônimas, pseudônimas, póstumas e psicografadas, obras derivadas, coletivas e co-autoria.

Foram estudadas também a criação do espírito e os requisitos de criatividade, intercomunicatividade e exteriorização, abordando-se questões como o plágio e a obra digital.

Por fim, foi proposta a nova sistematização do Direito Autoral com a adoção do princípio da funcionalidade do Direito Autoral como pressuposto de sua legitimidade.

Assim, o presente estudo possibilitou, em linhas gerais, concluir que o Direito Autoral passa por um momento de grande instabilidade em decorrência de fatores de ordem tecnológica como de ordem jurídica.

A tecnologia digital massificou não só a utilização das obras como também o ato criativo e a criação. A evolução tecnológica gera uma crise nas instituições de Direito Autoral em decorrência de maior facilidade de fixação da obra em suportes materiais diversos, da possibilidade de fixação a obra em suportes intangíveis (digitais), da possibilidade de codificação de qualquer espécie de obra para sua representação digital, da maior facilidade e velocidade na transmissão das informações e distribuição de obras, da possibilidade de iteratividade do usuário com a obra, da descentralização da arquitetura de rede e de sua internacionalidade, da imprecisão do significado dos atos praticados por meios informáticos e do surgimento de novas categorias de obras intelectuais, de nova técnica de criação ou exteriorização de obras e de novas formas de utilização.

Faz-se necessária uma releitura conceitual das instituições de Direito Autoral no sentido de acompanhar a nova realidade tecnológica. As noções de criação, obra, fixação, reprodução, contrafação, etc. não têm mais o mesmo conteú-

do com que foram sistematizadas. Além disso, surgem novas noções como o armazenamento digital, a codificação, a visualização digital, o compartilhamento de informações, etc.

A LDA não pode pretender ser a lei global do microssistema autoral, mas simplesmente sua lei básica, o que já é. A adequação do Direito Autoral à tecnologia digital melhor se faria em legislação específica. A superação dos problemas trazidos pela tecnologia digital pressupõe o esforço legislativo de regulamentação das novas situações por ela criadas.

Para a solução de tais problemas e a reconstrução das instituições e conceitos de Direito Autoral é importante empreender sua ressystematização, ou seja, a tripartição da propriedade intelectual em três ramos, propriedade industrial, Direito Autoral e propriedade tecnodigital, que comungariam das mesmas normas fundamentais.

O Direito Autoral passa por um processo de institucionalização e personalização, o que pressupõe a despatrimonialização e a funcionalização de suas instituições.

O modelo unidirecional de tutela dos interesses sobre a criação tende a ceder espaço a um modelo promocional da criação, que visa garantir ao autor uma tutela mínima, seja pelo licenciamento, seja pela gestão coletiva, sem obstaculizar o desenvolvimento cultural.

O Direito Autoral deixa de ser visto como a tutela dos interesses do criador e passa a ser visto como a tutela das relações jurídicas decorrentes da criação, mesmo porque constantemente verifica-se que o beneficiário da tutela autoral não é o criador da obra, mas o titular derivado, herdeiro, editor, produtor, etc.

A legitimação do Direito Autoral brasileiro pressupõe ampla participação de seus destinatários em seu processo de (re)construção política, legislativa e jurisdicional.

A pirataria não é a causa da crise do Direito Autoral, mas sua consequência. A causa é sua sistematização, essencial-

mente excludente. Nessa perspectiva, a crise não é de legitimidade da legislação autoral brasileira.

O pluralismo jurídico e a admissibilidade das normas individuais e concretas no quadro geral das normas jurídicas pressupõem a modificação do método interpretativo do Direito Autoral.

Em uma concepção constitucionalizada, o Direito Autoral deve ser visto como um sistema aberto, que se alimenta também de sua interpretação, em que a atividade jurisdicional será também criadora.

Nessa nova concepção de sistema jurídico autoral, que tem por força gravitacional suas normas fundamentais, os elementos estruturantes do juízo decisório encontram-se dissipados no sistema e não reunidos exclusivamente na LDA, podendo estar também na Constituição, no Código Civil, na Lei de Propriedade Industrial, etc. São todos fontes de Direito Autoral.

A institucionalização da criação intelectual delimita o campo de atuação de seu titular, uma vez que não é vista simplesmente como instrumento de satisfação dos interesses morais e econômicos do autor, mas também como instrumento de satisfação do interesse social de desenvolvimento cultural.

O princípio da funcionalidade do Direito Autoral tem por consequências a relativização dos direitos autorais, a integração do Direito Autoral ao sistema jurídico de Direito Privado e a legitimação do Direito Autoral, objetivo e subjetivo (legitimação da norma jurídica autoral e do direito subjetivo autoral). (5)

O princípio da funcionalidade mostra-se, assim, como a expressão no Direito Autoral das normas fundamentais constitucionais a ele aplicáveis, contribuindo para a relativização da dicotomia público-privado e para o reconhecimento do caráter político do direito privado, concebendo-se o direito subjetivo como elemento construtor da norma juri-

dica, negocial ou individual, sujeito, portanto, aos critérios de legitimidade da própria norma.

Sob esse aspecto, a exata medida da situação jurídica autoral pressupõe a identificação de todos os interesses envolvidos na tutela autoral, não apenas o interesse do autor ou titular de direitos autorais. Não se trata, portanto, de mera tutela do autor, mas de tutela da situação jurídica surgida com a criação.

A identificação da tutela autoral com a tutela do interesse do autor é naturalmente excludente, uma vez que se não pretere, ao menos menospreza os demais interesses que gravitam em torno da criação.

A concepção de tutela autoral como tutela da situação jurídica estabelecida em torno da obra criada tem natureza inclusiva já que busca definir todos os interesses envolvidos no caso específico e ponderando-os busca a solução do caso que melhor atenda a sua funcionalidade.

Assim, a principal finalidade deste estudo foi demonstrar que a superação da crise do Direito Autoral pressupõe o debate participativo de todos os interessados na tutela autoral, para que ela seja instrumento de promoção da dignidade humana, ao invés de instrumento de exploração ou de segregação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A ARTE de furtar. Porto Alegre: L&PM, 2005.

ALGARDI, Zara. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*. Milano: Giuffrè, 1966.

ALPA, Guido. *Elogio dell'incertezza*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1991.

AMARAL, Francisco. *Direito civil* 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

AMARAL, Francisco. Transformação dos sistemas positivos a descodificação do direito civil brasileiro. *O Direito*, ano 129, v. I, n. II, 1997. Separata.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Sentimento do mundo*. Rio de Janeiro: Record, 2001.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS. *Perguntas e respostas mais freqüentes*. Rio de Janeiro, [s.d.] Disponível em: <<http://www.abdr.org.br>>. Acesso em: maio 2005.

AULETTA, Tommaso Amedeo. *Riservatezza e tutela della personalità*. Milano: Giuffrè, 1978.

BERTI, Silma Mendes. Fragilização dos direitos da personalidade. *Revista da Faculdade Mineira de Direito*, Belo Horizonte, v 5/6, p. 238-248, 1º e 2º sem. 2000.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Direito das coisas*. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Teoria geral do direito civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL (Constituição 1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Promulgada em 5 out. 1988. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Lei n. 9.279/1996. Código de Propriedade Industrial de 14 de maio de 1996. *DOU*, Brasília, 15 maio 1996.

BRASIL. Lei n. 9.609/1998. Lei do Software de 19 de fevereiro de 1998. *DOU*, Brasília, 19 fev. 1998.

BRASIL. Lei n. 9.619/1998. Lei de Direitos Autorais de 19 de fevereiro de 1998. *DOU*, Brasília, 20 fev. 1998.

BRASIL. Lei n. 10.406/2002. Código Civil brasileiro de 10 de janeiro de 2002. *DOU*, Brasília, 11 jan. 2002.

CARNELUTTI, Francesco. *Metodologia do direito*. Campinas: Bookseller, 2002.

CARNELUTTI, Francesco. *Teoria geral do direito*. São Paulo: Saraiva, 1942.

CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. *Direito de informação e liberdade de expressão*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

CHAVES, Antonio. *Direitos autorais na computação de dados*. São Paulo: LTr, 1996.

CICERO, Antonio. Guardar. In: MORICONI, Italo. *Os cem melhores poemas brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 337-338.

COELHO, Luiz Fernando. *Teoria crítica do direito*. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

COLOMBET, Claude. *Propriété littéraire et artistique*. Paris: Précis Dalloz, 1976.

CORTIANO JUNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de personalidade. In: FACHIN, Luis Edson (Coord.) *Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 31-56.

COSTA JUNIOR, Olimpio. *A relação jurídica obrigacional*. São Paulo: Saraiva, 1994.

COSTA, Nelson Nery. *Teoria e realidade da desobediência civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

CRUET, Jean. *A vida do direito e a inutilidade das leis*. Lisboa: Ibero-Americana, 1908.

DE SANCTIS, Vittorio M. *I soggetti del diritto d'autore*. Milano: Giuffrè, 2000.

DEBOIS, Henri. *Le droit d'auteur*. Paris: Dalloz, 1950.

DOCK, Marie Claude. *Étude sur le droit d'auteur*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1963.

ECO, Umberto. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2004.

EMERY, Miguel Angel. *Propiedad intelectual*. Astrea: Buenos Aires, 1999.

ENNECCERUS, Ludwig. *Tratado de derecho civil*. Barcelona: Bosch, 1944, v. 1, t. III.

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. *Crêterios de arrecadação*. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <<http://www.ecad.org.br>>. Acesso em: 23 ago. 2005.

FERNANDEZ-DIEZ, Ignacio Garrote. *El derecho de autor en internet*. Granada: Comares, 2001.

FERRAJOLI, Luigi. Il diritto privato del futuro: liberta, poteri e grazie. In: PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto privato futuro*. Napoli: ESI, 1993, p. 13-30.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Dicionário Aurélio*. 6. ed. Curitiba: Positivo, 2004.

FIUZA, César. *Curso avançado de direito civil*. São Paulo: Thompson, 2005.

FIUZA, César. *Direito civil: curso completo*. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

FIUZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito civil – atualidades*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 23-59.

GAGLIANO, Pablo Stolze. *Novo curso de direito civil*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. I.

GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à internet*. Rio de Janeiro: Record, 1997.

HABERMAS, Jurgen. *Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy*. New Bakersville: MIT, 1996.

HABERMAS, Jurgen. *Théorie de l'agir communicationnel*. Paris: Fayard, 1987.

HUBERMAN, Leo. *História da riqueza do homem*. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.

ITÁLIA. Lei n. 633/1941. Lei de direitos autorais italiana publicada em 22 abr. 1941.

KELSEN, Hans. *Teoria geral do direito e do Estado*. Tradução Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

KLEIN, Naomi. *Sem logo*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

LEAL, Rosemiro Pereira. Isonomia processual e igualdade fundamental a propósito das retóricas ações afirmativas. *Revista Jurídica Unijus*, Uberaba, v. 6, n. 1, p. 43-50, ago 2003.

LEAL, Rosemiro Pereira. *Teoria processual da decisão jurídica*. São Paulo: Landy, 2002.

LEVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Ed. 34, 1999.

LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Zavalia, 2001.

LISBOA, Roberto Senise. *Manual de direito civil*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, v. III.

LORENZETTI, Ricardo Luis. *Comercio electronico*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2001.

LEAL, Rosemiro Pereira. *Fundamentos do direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

LUCCHESI, Franco. *Voltaggio I beni immateriali*. Milano: Giuffrè, 1962.

MADALENO, Rolf. Do regime de bens entre os cônjuges. In: DIAS, Maria Berenice. *Direito de família e o novo código civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 191-224.

MANSO, Eduardo Vieira. *Direito autoral*. São Paulo: Bushatsky, 1980.

MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico*. São Paulo: Saraiva, 1991.

NADER, Paulo. *Curso de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I.

OLIVER, Paulo. *Direitos autorais da obra literária*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

PEREIRA, Alexandre Dias. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*. Coimbra: Coimbra, 2001.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1993, v. II.

PERLINGIERI, Pietro. Fonti normative e interpretazione. In: PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto privato futuro*. Napoli: ESI, 1993, p. 73-86.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de direitos autorais*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005.

POLI, Leonardo Macedo. *Direitos de autor e software*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

POLI, Leonardo Macedo. *Ato ilícito*. In: FIUZA, César. *Curso Avançado de Direito Civil*. São Paulo: IOB, 2004.

- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao código de processo civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, t. I.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, v. 1.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, t. XIX. * .
- PUGLIATTI, Salvatore. *Diritto civile* – saggi. Milano: Giuffrè, 1951.
- QUINTANA, Mario. *Apontamentos de história sobrenatural*. São Paulo: Globo, 1987.
- RIBAS, Conselheiro Joaquim. *Direito civil brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1983.
- ROBERTO, Giordano Bruno Soares. *Introdução à história do direito privado e da codificação*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
- RÓNAI, Paulo. *Não perca o seu latim*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
- ROPPO, Enzo. *O contrato*. Coimbra: Almedina, 1988.
- RUGGIERO, Roberto de. *Instituições de direito civil*. Campinas: Bookseller, 1999, v. 3.
- SÁ, Maria de Fátima Freire de. *Direito de morrer*. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
- SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito à intimidade e à vida privada*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.
- SANTILLI, Marina. *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*. Milano: Giuffrè, 1988.
- SAVATIER, René. *Le droit de l'art et des lettres*. Paris: Librairie Générale de Droit, 1953.
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. *Informe*. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 27 fev. 2006.
- TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- THEODORO JUNIOR, Humberto. *Comentários ao novo código civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3.

- TIMPONI, Miguel. *A psicografia perante os tribunais*. Rio de Janeiro: FEB, 1959.
- VIEHWEG, Theodor. *Tópica e jurisprudência*. Brasília: Ed. UnB, 1979.
- VILANI, Maria Cristina Seixas. Cidadania moderna: fundamentos doutrinários e desdobramentos históricos. In: *Caderno de Ciências Sociais*. Belo Horizonte: PUC Minas, 2002, p. 47-64.